Filosofia e diritto

A differenza delle altre scienze, che hanno un oggetto ben definito, la filosofia **non possiede un contenuto determinato**. La sua peculiarità non risiede nel suo oggetto, ma piuttosto nelle sue **domande**.

Essa è più propriamente **scienza del tutto**, e per questa ragione anche gli oggetti delle altre discipline rientrano, a loro volta, nel campo d'indagine filosofico.

Questa natura onnicomprensiva della filosofia è storicamente attestata all'inizio del IV libro della *Metafisica* di Aristotele, dove si legge:

> Ἔστιν ἐπιστήμη τις ἣ θεωρεῖ τὸ **ὂν ᾗ ὂν** καὶ τὰ τούτῳ ὑπάρχοντα καθ' αὑτό. αὕτη δ' ἐστὶν οὐδεμιᾷ τῶν ἐν μέρει λεγομένων ἡ αὐτή· οὐδεμία γὰρ τῶν ἄλλων ἐπισκοπεῖ καθόλου περὶ τοῦ ὄντος ᾗ ὄν, ἀλλὰ μέρος αὐτοῦ τι ἀποτεμόμεναι περὶ τούτου θεωροῦσι τὸ συμβεβηκός
>
> C'è una scienza che considera **l'essere in quanto essere** (ὂν ᾗ ὂν) e le proprietà che gli competono in quanto tale. Essa non si identifica con nessuna delle scienze particolari: infatti, nessuna delle altre scienze considera l'essere in quanto essere in universale, ma, dopo aver delimitato una parte di esso, ciascuna studia le caratteristiche di questa parte.

In modo analogo, la **filosofia del diritto** non si concentra su un aspetto specifico o parziale del diritto, ma abbraccia l'**intero** fenomeno giuridico. Questo approccio globale rende forse più agevole affrontare la nozione di **dovere giuridico**.

Sebbene l'affermazione "il diritto non è il dovere giuridico" possa apparire a tratti insufficiente o, al contrario, eccessiva, resta innegabile che il concetto stesso di **diritto non sia pensabile senza l'idea di dovere**.

Il dovere giuridico non è identificabile con una singola e delimitata porzione dell'esperienza giuridica, come:

- **Un particolare insieme di norme**: ad esempio, il contratto anziché le successioni.
- **Uno specifico ordinamento**: come un sistema di *civil law* rispetto al *common law*.
- **Un contesto temporale o storico definito**: come l'ordinamento attuale anziché lo *ius commune* dell'Europa continentale del X secolo.
- **Una specifica fonte di produzione**: come il diritto spontaneo e consuetudinario anziché il diritto codificato dal potere legislativo statale.
- **Un ambito normativo d'eccezione**: come il "diritto sovralegale" (*übergesetzliches Recht*) delle corti penali internazionali anziché le delibere dei consigli di amministrazione.

Il concetto di dovere giuridico, non si limita a una singola parte, ma è estendibile a una **molteplicità** di fenomeni.

Mentre gli altri saperi del diritto (costituzionale, civile, penale, amministrativo, canonico, internazionale, processuale e via dicendo) si concentrano esclusivamente su una *parte* del diritto, la filosofia del diritto ha il compito di interrogarsi su **che cos'è il dovere giuridico**.

L'oggetto della sua indagine non è questo o quell'insieme di doveri, né il dovere contingente di un certo momento storico, ma il **dovere giuridico in sé**, il **dovere in quanto dovere giuridico**, richiamando la metafisica che indaga l'essere in quanto essere (ὂν ᾗ ὄν).

Il dovere giuridico può essere studiato e suddiviso attraverso diversi criteri per poterne definire i nomi e le modalità di ricerca.

Una prima distinzione fondamentale è quella che riguarda la **forza** del dovere (ad intra). Chiedersi se esistano doveri **necessari** o soltanto **possibili** significa esplorare e definire la forza intrinseca del dovere stesso.

Una distinzione successiva è quella che si basa sull'**oggetto** del dovere (ad extra). Questa classificazione differenzia tra:

1. **Doveri di condotta:** Quelli che hanno la funzione di istituire e regolare i rapporti giuridici.
2. **Doveri di struttura:** Quelli il cui scopo primario è quello di organizzare un corpo di norme.

Avviare questa prima classificazione non è un compito inutile, ma costituisce una via essenziale per la conoscenza del mondo. "**Classificare**", infatti, implica la capacità di distinguere cose diverse tra loro.

L'importanza della classificazione è illustrata dall'esempio dei baci e dei fasci di fiori, elementi che, pur potendo essere accomunati in contesti di passione, appartengono a mondi sostanzialmente distinti.

È facile confondere questi due elementi, ma la scelta di preferire, i baci ai fasci di fiori deriva dall'aver imparato a classificarli, comprendendo appieno le azioni che si possono compiere con gli uni e non con gli altri.

Le differenze tra i due elementi sono profonde:

- I **baci** sono considerati *ex cogitans,* realtà soprasensibili e manifestazioni dell'anima.
- I **fasci di fiori** restano ancorati al mondo sensibile.

Questa differenza si manifesta chiaramente nel **linguaggio**. È corretto dire "Cara, ti dò un bacio" oppure "Ti dò un fascio di fiori", e si può dire "Amore, ti bacio". Tuttavia, non si può dire "Amore, ti fascio".

Le parole che si utilizzano sono le prime e più immediate testimonianze di ciò che è **spiritualmente tipico**. Studiare il dovere giuridico equivale, a compiere un'operazione di discernimento rigoroso, analogo al distinguere i baci dai fasci di fiori.

Uno dei significati fondamentali del dovere giuridico è l'**obbligo**. Il suo altro senso essenziale, il **permesso**, è tuttavia riconducibile all'obbligo stesso.

Questa riduzione è motivata dal fatto che un permesso, inteso come un'azione giuridica concessa, è tale solo se l'**impedimento del permesso è a sua volta impedito**. Di conseguenza, il permesso implica necessariamente un obbligo: il dovere di impedire che il permesso venga ostacolato. Se un fatto o un atto sono permessi, ne consegue l'obbligatorietà di non impedirli (ossia il divieto di ostacolo).

Ad esempio, alla norma del codice della strada che permette il sorpasso corrisponde la norma che vieta (obbliga a non) ostacolare tale sorpasso. In ogni permesso, si individua un obbligo: quello di **preservare il permesso dal suo impedimento**.

I permessi possono essere distinti in **"libertà"** e **"poteri"**, e la differenza risiede nel modo in cui sono protetti.

- Le **libertà** non richiedono un'iniziativa specifica dello Stato per la loro protezione. Le libertà individuali, come quella di opinione, non possono essere ostacolate (da cui deriva il divieto di impedimento), ma non sono necessariamente sostenute con mezzi straordinari.
- I **poteri**, invece, sono garantiti tramite **interventi mirati e risorse dello Stato**. Il diritto all'istruzione, per esempio, non è una semplice libertà, poiché lo Stato ne garantisce la fornitura attraverso risorse pubbliche, estendendosi oltre la sola "scuola dell'obbligo".

Sotto questo profilo, i poteri tendono a **condizionare le libertà**. Il riconoscimento di un diritto sociale all'istruzione, sostenuto economicamente dallo Stato, comporta una limitazione (non la cancellazione) della libertà dei cittadini di scegliersi la scuola. Ciò è necessario per garantire che le risorse disponibili siano sufficienti e non disperse.

Il legame tra obblighi e permessi si rafforza con la distinzione tra libertà e poteri:

- Se la **libertà** implica il divieto di impedirla (obbligo di non fare), il **potere** aggiunge l'**obbligo del suo adempimento** (obbligo di fare).
- In questo modo, il permesso risulta persino rafforzato dall'obbligo.

Questa analisi permette di risolvere la questione relativa a un eventuale primato dell'obbligo. Laddove c'è un obbligo, c'è anche un diritto, e viceversa; dove c'è un dovere, c'è un permesso, e dove si concede un permesso, si trova anche un dovere.

Si deve fare attenzione solo al caso in cui si instauri una **costrizione** al posto di un genuino obbligo. La differenza fondamentale risiede nella **direzione dell'obbligo**:

1. I **doveri *simpliciter*** (doveri *di*), sono più prossimi alle costrizioni e non presuppongono necessariamente un diritto.
2. I **doveri *verso*** qualcosa o qualcuno, sono quelli che presuppongono un diritto correlato.

Diritti e doveri sono, con un'immagine ricorrente, come il **retto e il rovescio della medaglia**. Quale sia l'uno e quale l'altro dipende unicamente dal punto di vista dell'osservatore. L'epoca attuale, che si è autoproclamata "età dei diritti" soprattutto a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, non deve dimenticare di essere, di conseguenza, anche un'**età dei doveri**.

Il **dovere** costituisce il tema centrale della **norma giuridica**. Per questa ragione, parlare di doveri e parlare di norme equivale alla stessa indagine. Il significato normativo del diritto è reso ancora più esplicito dall'idea di **"ordinamento"**.

L'ordinamento è comunemente inteso come l'insieme delle norme valide. Tuttavia, il termine **"insieme"** è considerato riduttivo se si tiene conto della sua complessità logica. D'altra parte, anche il termine **"sistema"** è ritenuto eccessivo.

L'ordinamento è infatti il risultato non solo della logica, ma anche dell'**azione** e si edifica attraverso decisioni che non sono necessariamente correlate tra loro, se non per il fatto di appartenere al medesimo ordine giuridico.

Nonostante queste complessità, l'ordinamento presuppone due condizioni essenziali:

1. Che **nessun'altra norma** esterna sia valida.
2. Che siano valide **tutte e sole** le norme che sono state validate secondo le **regole di formazione** (che danno origine a nuove norme) o che sono validabili secondo le **regole di trasformazione** (che convertono, ad esempio, norme di costume in norme giuridiche).

Entrambe queste categorie di regole concorrono a formare l'ordinamento nella sua interezza, poiché l'**esistenza giuridica (la totalità delle norme valide)** ne rappresenta la *quidditas* (l'essenza). Da questa prospettiva, non esiste nulla di giuridicamente rilevante al di fuori dell'ordinamento stesso.

Affermare la validità esclusiva delle norme appartenenti all'ordinamento implica anche **decidere ciò che è invalido**. Questa concezione è accostata alla proposizione 2.05 del *Tractatus logico-philosophicus* di Wittgenstein:

> La totalità degli stati di cose sussistenti [il mondo] determina anche quali stati di cose non sussistono.

La filosofia del diritto, in quanto scienza del dovere giuridico, si configura come la **scienza di una totalità di norme**: sia di quelle che *sono* (per ciò che sono), sia di quelle che *non sono* (perché escluse). Questa totalità non si riferisce al numero delle singole norme, ma alla loro **specie**, legandosi alla loro **possibilità** e alla loro **forma**, non al loro contenuto. Il pensiero, in questa prospettiva, rimane costantemente focalizzato sul dovere giuridico in sé e sull'universale.

Da un primo e generalissimo approccio, si possono distinguere almeno **due specie di norme**, basate sulla classificazione del dovere giuridico precedentemente discussa:

1. Norme secondo la **forza** del dovere.
2. Norme secondo l'**oggetto** del dovere.

Una delle classificazioni fondamentali delle norme è quella basata sulla **forza del dovere** che esse esprimono. Questa distinzione è essenzialmente tra **doveri necessari** e **doveri solo possibili** (o doveri non necessari).

Il criterio utilizzato per questa classificazione è la **relazione che la norma intrattiene con l'ordinamento giuridico** nel suo complesso.

Secondo questo approccio, le norme si distinguono in due specie:

1. **Norme necessarie (o norme forti):** Sono quelle norme la cui assenza renderebbe il diritto stesso **impensabile o inesistente**. Senza queste norme, l'ordinamento non potrebbe nemmeno sussistere.
2. **Norme non necessarie (o norme deboli):** Sono quelle norme la cui esistenza è contingente; potrebbero benissimo **non esserci** senza compromettere l'esistenza o la pensabilità del diritto in generale.

La discussione sulle norme necessarie si concentra sulla **"norma fondamentale"** (*Grundnorm*) di Kelsen: "Ci si deve comportare secondo la Costituzione effettivamente statuita ed efficace."

Risulta insolito partire da Kelsen, dato che per la sua dottrina le norme sono il "senso di un atto di volontà" (*Willensakt*). Tuttavia, si pone la questione di come conciliare la **necessità** con il **volere**. Se si considera l'assioma geometrico di Hilbert ("ogni coppia di punti di una retta individui tale retta"), la sua validità permane indipendentemente dalla volontà individuale e non può essere considerata un semplice prodotto del desiderio. La necessità vive dunque **irrelata dalla volontà**; si può, al massimo, amarla (*Amor fati*).

La norma fondamentale non è, pertanto, il senso di un atto di volontà, ma, semmai, il **prodotto della ragione**. L'ordinamento giuridico, per sua natura, non può che comandare il proprio adempimento. Sarebbe contraddittorio se un ordinamento, dopo aver promulgato un gran numero di disposizioni, giungesse a stabilire l'esatto contrario: "Non ci si deve mai comportare secondo la Costituzione e le leggi effettivamente statuite ed efficaci."

Una simile contraddizione (doveri su doveri senza permesso che introducono un dovere permissivo radicale: "Fate tutto quello che volete!") implicherebbe che ogni norma comanderebbe simultaneamente un dovere e la sua negazione. L'imperatività logica di questa condizione è suggerita dalla proposizione di Wittgenstein:

> Der Befehl befiehlt seine Befolgung
>
> L'ordine comanda la sua esecuzione.

È notevole che i doveri necessari siano spesso **muti**, comportandosi come veri e propri **crittotipi** (doveri nascosti) privi di una formulazione scritta. La norma fondamentale della *dottrina pura del diritto* (*reine Rechtslehre*) di Kelsen, ad esempio, non compare in nessuna parte del codice. Il motivo di tale assenza risiede nella sua stessa **forza**: la *Grundnorm* è così evidente da non necessitare di essere rappresentata per iscritto. La sua assenza nel codice non nega la sua natura di norma; anzi, è la "norma fondamentale". Da ciò si deduce che il diritto non si limita alle sole leggi scritte (diritto *praeter legem*).

Esistono tuttavia anche doveri necessari che mantengono un rapporto esplicito con il codice (diritto *secundum legem*). Ad esempio, è difficile concepire il passaggio di proprietà di beni immobili senza una scrittura privata o pubblica ai fini dell'accertamento. Tale obbligo, fondamentale per evitare una "Babele" di incertezze, è formalmente riconosciuto e codificato. Un esempio è l'Art. 1350 del Codice Civile italiano, che richiede l'atto pubblico o la scrittura privata, sotto pena di nullità, per i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili.

Un terzo e più problematico rapporto si verifica quando i doveri necessari entrano in **conflitto con la legge** (diritto *contra legem*).

Esempi:

- La nozione di **"crimini contro l'umanità"**, elaborata *ex post facto* dallo Statuto del Tribunale di Norimberga (1945), ha stabilito il principio secondo cui una condotta può essere definita antigiuridica anche se era stata ordinata dallo Stato (il Terzo Reich) e compiuta in obbedienza alle sue leggi.

- Più recentemente, la giurisprudenza dei Tribunali Penali Internazionali *ad hoc* per l'ex Jugoslavia e il Ruanda ha confermato che le leggi statali possono confliggere con doveri necessari superiori. Il fatto stesso che tali tribunali siano istituiti dopo la commissione dei fatti dimostra la contrapposizione tra la legge dello Stato e il **diritto sovrastatale** (*übergesetzliches Recht*[1], secondo Radbruch), il quale è illimitatamente valido.
- Nel 2006, la Corte Internazionale di Giustizia ha stabilito che il divieto di genocidio appartiene al **diritto internazionale cogente** e non può essere trasgredito da alcuno Stato.

In tal senso, il diritto è anche **diritto *contra legem***. La Corte Costituzionale tedesca, a proposito dell'Art. 20, comma 3, della Costituzione, ha dichiarato che "il diritto (*Recht*) non coincide con la totalità delle leggi scritte (*geschriebene Gesetze*)". Questa affermazione non si limita a ribadire l'esistenza di obblighi indipendenti dal codice, ma riconosce soprattutto il **primato del diritto sulle leggi**.

Non tutte le norme possiedono il carattere della necessità. Esistono norme che sono solo **possibili** (doveri solo possibili), la cui assenza o rimozione non compromette l'esistenza o la pensabilità del diritto in sé.

Un esempio significativo di norma solo possibile è l'**Art. 144 del vecchio Codice Civile italiano** relativo alla potestà maritale, abrogato con la riforma del diritto di famiglia del 1975.

La norma stabiliva che "la moglie [...] è obbligata ad accompagnare il marito dovunque egli crede opportuno di fissare la sua residenza". Questa norma era solo possibile, come dimostra il fatto che la sua abrogazione non ha generato contraddizioni nell'ordinamento. Si trattava di un obbligo legato al **retaggio storico dell'ideologia maschilista**, in parte speculare alla *manus maritalis* del diritto romano.

Il superamento di obblighi di questo tipo, come la discriminazione di genere, la schiavitù, il razzismo, il colonialismo e l'imperialismo, rappresenta un vero e proprio **errore teoretico della ragion pratica**.

Il superamento di questi errori è caratterizzato dall'**irreversibilità** dei processi che portano all'affermazione di istanze opposte. Non è neppure pensabile un ritorno a tali istituti. Questi passaggi non sono dettati dalla fortuna o dal caso; sostenere il contrario (come affermare che il bipedismo umano sia stato un "caso") sarebbe giudicato irrazionale.

Nel caso della potestà maritale, il superamento di un obbligo meramente possibile ha generato un **divieto necessario**. Sebbene il nesso tra la sola possibilità e la necessità non sia completamente noto, il percorso storico è andato in questa direzione. Similmente, l'ordalia non è la premessa sufficiente dei processi basati sulla terzietà del giudizio, ma la fase della sua negazione è stata comunque utile (il vecchio sistema non ha *creato* il nuovo, ma l'**abbandono del vecchio sistema** ha *permesso* lo sviluppo del nuovo. La sua negazione ha aperto la strada a concetti come la prova razionale e l'autorità imparziale del giudice.).

Un altro caso riguarda la restituzione dei doni. Dal punto di vista etico, è biasimevole che gli amanti si restituiscano i doni al termine di una relazione, poiché il **dono** e il **perdono** non implicano reciprocità e non si offrono a patto di essere corrisposti (la loro regola è l'assenza di regola).

---

[1] **Über-** (prefisso): Sopra, oltre, al di sopra di. **Gesetzlich** (aggettivo): Legale, relativo alla legge (*Gesetz*). **Recht** (sostantivo): Diritto, legge.

Eppure, l'**Art. 80 del Codice Civile** stabilisce che "Il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto." In tal modo, il codice introduce un **obbligo in più** (l'obbligo di restituzione), laddove si potrebbe ritenere inevitabile il suo opposto (il divieto di pretendere la restituzione).

Un ulteriore esempio di norma non necessaria è il divieto di mangiare le fave in vigore presso la comunità pitagorica di Metaponto. Questa astensione era legata a un antico tabù originato da un ideale di purezza, che associava le fave al mondo dei morti e della decomposizione. Questo sentimento non era né fatale né destinato a durare. Questo divieto è menzionato, tra gli altri, da Theodor Geiger nei Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts (Prolegomeni[2] ad una sociologia del diritto, 1947).

Le norme giuridiche si distinguono non solo in base alla **forza del dovere** che esprimono (come discusso precedentemente), ma anche in base al loro **oggetto**.

Per catalogare le norme secondo il loro oggetto, si può adottare la distinzione tra **"norme primarie"** (*primary rules*) e **"norme secondarie"** (*secondary rules*).

Questa terminologia e il concetto sottostante sono mutuati dall'opera di Herbert L.A. Hart, *The Concept of Law* (Il concetto di diritto, 1961).

Le **norme primarie** sono definite come **norme di "condotta"**. La loro funzione principale è quella di **istituire rapporti giuridici** stabilendo esplicitamente ciò che si deve fare o ciò che è vietato fare.

Un esempio emblematico di norma di condotta è quella che **vieta l'omicidio**. L'Art. 575 del Codice penale italiano, disponendo che "chiunque cagioni la morte di un uomo è punito", rientra pienamente in questa categoria per il solo fatto di prescrivere un comportamento (un non-fare).

Vi è una considerazione cruciale riguardo queste norme: è impossibile concepire un ordine giuridico che includa l'omicidio o una norma che autorizzi indiscriminatamente l'uccisione e la violenza contro l'innocente ("Ognuno è autorizzato ad uccidere..."). In assenza di tali divieti fondamentali, l'esistenza stessa del diritto e la sua funzione verrebbero meno.

Il passaggio da un ipotetico stato di natura pregiuridico a un ordine giuridico si giustifica proprio grazie all'esistenza delle norme di condotta, in particolare di quelle la cui negazione renderebbe impossibile l'idea stessa di **umanità**.

Per tale motivo, il **divieto di uccidere** occupa il **vertice** della gerarchia delle norme di condotta. Questo divieto non può essere considerato semplicemente come il "senso di un atto di volontà", andando oltre la stretta dottrina volontaristica (come quella di Kelsen).

Le **norme secondarie** sono definite come **norme di "struttura"**. La loro funzione essenziale è quella di creare, organizzare e rendere operativo l'ordinamento giuridico stesso.

Queste norme vertono **su altre norme** e, come già accennato in precedenza, esprimono **doveri su doveri**. Esse non si occupano direttamente dei comportamenti dei destinatari, ma assolvono a diverse funzioni organizzative:

---

[2] **προλέγω «dire prima»**: premessa introduttiva a un insieme di considerazioni preliminari che servono a preparare il lettore o l'ascoltatore alla comprensione di un'opera o di un argomento. Delinea i principi o i fondamenti di una trattazione più ampia.

1. Fissano gli organi legittimati alla produzione normativa a vari livelli (dalla legislazione alla giurisdizione).
2. Identificano gli autori (o i destinatari) sia delle norme di condotta che delle norme di struttura.
3. Stabiliscono direttamente i criteri di validità per tutte le altre norme.

Esempi di norme di struttura:

- L'Art. 70 della Costituzione italiana ("La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere") ne è un chiaro esempio. Questa norma **crea gli organi legislativi** (le due Camere del Parlamento), stabilendo chi è il soggetto legittimato a produrre le leggi. L'Art. 70 non prescrive una condotta specifica ai cittadini, ma definisce **chi decide come ci si deve comportare**.
- Rientra nella categoria delle norme di struttura anche la **"norma di chiusura"** dell'ordinamento: "Sono valide tutte e sole le norme dell'ordinamento, nessun'altra norma è valida." Questa regola, sebbene non scritta, riconosce la condizione di validità all'interno dello spazio geometrico dell'ordinamento. L'esistenza giuridica si attua sempre **in** *(par)* **e per** *(pour)* un ordinamento, escludendo l'esistenza di norme al di fuori di esso. Questa idea introduce il concetto di **architettura del diritto**.
- Sono norme di struttura anche quelle che fissano un ordine e un rapporto tra le leggi, come l'Art. 15 delle Preleggi (Disposizioni sulla legge in generale). Questo articolo disciplina l'abrogazione delle leggi, stabilendo che "le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori [...] per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti [...]". Si tratta di una norma che **verte su altre norme** e decide l'esito di un conflitto tra leggi: la legge successiva prevale e abroga la precedente (*Lex posterior derogat priori*).

Anche il vecchio Art. 144 del Codice Civile conteneva una norma di struttura laddove, al primo comma, ascriveva al marito il ruolo di capofamiglia: "il marito è il capo della famiglia". Questa disposizione non diceva cosa dovesse fare il marito, ma si limitava a sancire **chi era il "capo della famiglia"** (un ruolo strutturale).

La questione della relazione tra norme primarie (di condotta) e norme secondarie (di struttura) si collega direttamente al classico dibattito tra **positivismo giuridico** e **giusnaturalismo**.

Nella prospettiva del positivismo giuridico, le **norme di struttura** sono considerate condizioni sia **necessarie** che **sufficienti** per la validità di tutte le altre norme, comprese quelle di condotta.

Secondo questa visione, non esistono doveri giuridici auto-sussistenti. Ogni norma dipende esclusivamente da specifici **atti di produzione** (atti di "posizione") posti in essere dal legislatore. Le norme di struttura, a loro volta, qualificano tali atti, decidendo *chi*, *come* e *quando* ha il potere di fare le leggi.

In sintesi: **senza** questi atti di posizione non ci sono norme valide, e **bastano** questi atti perché le norme siano valide. Il diritto scaturisce necessariamente dall'attività del legislatore, ed è sufficiente stabilire con una norma chi sia il legislatore. Da qui deriva il **valore assoluto** attribuito alle norme secondarie o di struttura. Questo concetto è un punto chiave della *Reine Rechtslehre* (*Dottrina pura del diritto*) di Kelsen.

Tuttavia, l'esistenza giuridica non dipende esclusivamente e sufficientemente dagli atti di posizione del legislatore. Un argomento decisivo contro la sufficienza delle norme di struttura si desume dalla

storia degli ordinamenti giuridici stessi, in particolare dalla **giurisprudenza delle corti nella Germania post-nazista**.

In quel contesto straordinario, i giudici cercarono un **"diritto sopra le leggi"** (*übergesetzliches Recht*) per opporsi ai principi del giuspositivismo radicale quali "Un ordine è un ordine!" (*Befehl ist Befehl!*) e "La legge è la legge!" (*Gesetz ist Gesetz!*). La conclusione fu che la validità delle leggi viene **radicalmente compromessa "nel caso di ordini impartiti a scopi criminali"**.

Ciò dimostra che il diritto **resiste inappellabilmente all'"ingiustizia legale"** (*Gesetzliches Unrecht*).

Esempi:

1. Nel suo articolo *Ingiustizia legale e diritto sovralegale* (1946), Gustav Radbruch cita la sentenza del tribunale di prima istanza di Wiesbaden che dichiarò la **nullità, fin dalla loro promulgazione**, delle leggi naziste che avevano confiscato i beni degli ebrei. Nonostante fossero formalmente leggi dello Stato, furono dichiarate invalide.
2. Robert Alexy, nel suo *Concetto e validità del diritto* (1992), menziona la decisione della *Bundesverfassungsgericht* (1968) riguardante il § 2 del decreto n. 11 (25 novembre 1941), che privava gli ebrei emigrati della cittadinanza per motivi razziali. La Corte stabilì che un avvocato ebreo emigrato **non aveva mai perso la cittadinanza** tedesca, poiché il decreto n. 11 fu ritenuto **nullo *ex tunc*** (fin dall'inizio).

I casi storici citati da Radbruch e Alexy dimostrano che **non è sufficiente** un mero requisito formale di validità delle leggi, né la semplice circostanza che le norme siano state prodotte da norme di struttura. Ciò è osservabile da un punto di vista interno agli ordinamenti stessi.

Questa argomentazione sui "delitti di Stato" (come quelli del nazismo o l'orrore dell'"arcipelago Gulag" in URSS, descritto da Solženicyn) porta alla conclusione definitiva che le **norme di struttura non sono sufficienti** a garantire la validità o la giuridicità del diritto.

Il passaggio dal positivismo giuridico al **giusnaturalismo** comporta una messa in secondo piano delle **norme di struttura**. In questa prospettiva, il diritto procede essenzialmente da sé, come affermato, ad esempio, da Tommaso nella *Summa Theologiae*.

Ciò significa che i **doveri sono in sé sussistenti** e non necessitano a ogni costo di atti specifici di "posizione" (produzione normativa), atti che sono qualificati giuridicamente dalle norme di struttura. La validità del diritto si basa sull'**intuizione e sulla deduzione**, non sugli atti di produzione.

Le norme si comportano come l'enunciato del primo libro degli *Elementi* di Euclide sul Teorema di Pitagora: "L'area del quadrato costruito sull'ipotenusa... è equivalente alla somma delle aree dei due quadrati costruiti sui cateti." Il matematico non crea il significato di questa proposizione, ma ne spiega la ragione. Analogamente, alcuni doveri nella costruzione giuridica si manifestano con una necessità intrinseca.

La questione fondamentale è stabilire se il giusnaturalismo abbia ragione nel far coincidere tutto il diritto con un oggetto concepito in modo puramente geometrico e auto-sussistente.

In realtà, l'esistenza di doveri necessari **non sostituisce la funzione del legislatore** e, di conseguenza, la necessità di norme di struttura che qualifichino l'autore delle leggi.

Questo punto è chiarito attraverso le **regole tecniche** o il concetto di **"natura della cosa"** (*Natur der Sache*). Le regole tecniche seguono lo schema: "Se vuoi x, devi y" (imperativi dell'abilità, come definiti da Kant).

- Esempio: "Se vuoi guarire, devi prendere i farmaci."
- In questi casi, la volontà di attuare un fine implica necessariamente l'adozione di un mezzo specifico, e sarebbe contraddittorio volere il fine ma rifiutare il mezzo.

Non importa la bontà o la razionalità del fine (le prescrizioni di un medico per guarire e quelle di un avvelenatore per uccidere sono di valore uguale in quanto efficaci per il loro scopo), ma che a un fine segua un mezzo necessario.

Nel campo del diritto, esistono doveri necessari che sono conoscibili in modo chiaro e distinto attraverso regole tecniche.

- Ad esempio, Il testamento olografo presuppone di essere sottoscritto dal testatore. La regola tecnica è: "Se vuoi fare un testamento olografo, devi sottoscriverlo." Questo nesso sembra immutabile, poiché è difficile concepire un testamento "scritto per intero" che non sia anche "sottoscritto".

Tuttavia, affinché questa regola tecnica diventi una **norma giuridica** ("law in the book"), ha bisogno di trovarsi nel codice, come l'Art. 602 del Codice Civile italiano. L'assenza dell'Art. 602 non sarebbe indifferente: sebbene sia difficile immaginare un codice che vieti la sottoscrizione, è **necessario** che il dovere di sottoscrizione sia **rafforzato da una norma espressa** del codice. Del resto, un ordinamento potrebbe anche decidere di non prevedere affatto la forma testamentaria olografa, il che dimostra che essa non deriva dall'idea (*eîdos*) stessa di testamento.

- Analogamente, la regola "Se vuoi fare una donazione, devi stipulare un atto pubblico" sembra riflettere una necessità tecnica, come il giudizio pratico "Se vuoi far bollire l'acqua, devi scaldarla a $100^C". Entrambi i doveri sembrano necessari.

La differenza fondamentale è che, nella regola giuridica, la conseguenza o il fine sono sempre dedotti da una **norma dell'ordinamento**. La donazione giuridica non esiste al di fuori di esso. Pertanto, il rapporto mezzo-fine giuridico non è una mera conversione in regola di un rapporto di causa-effetto (come la pioggia e il bagnarsi), ma è la **trasformazione in regola di due fatti qualificati dall'ordinamento:** la condizione e la conseguenza (ad esempio, donare con un atto pubblico è un fatto qualificato dagli articoli del codice).

La differenza tra norme primarie e secondarie lascia aperto il problema della loro relazione. A un esame complessivo, esse sono solo **congiuntamente condizioni necessarie e sufficienti di validità giuridica**. Separatamente, non lo sono. Le norme di struttura non possono esistere senza quelle di condotta, e viceversa.

Il diritto è stato finora discusso come **"scienza del dovere giuridico"**. Sebbene le scienze abbiano tradizionalmente un oggetto definito, la filosofia è primariamente **"metafisica"**. Essa non riflette su tutti i doveri in modo indifferenziato, ma si concentra sull'**immutabile** e sull'**essenza del mondo**.

Il significato della filosofia come scienza riflette l'apertura **irresistibile** del diritto verso **doveri universali e necessari**. Si potrebbe perfino definire il diritto come **"filosofia del diritto"** per il semplice fatto che esso presuppone l'universale.

Il diritto non è dunque una totalità semplice composta da doveri semplici generati da volontà particolari. Esso contiene anche **doveri necessari**, senza i quali l'ordinamento cesserebbe di essere sé stesso.

Il Ruolo dell'Universale

- Il diritto è simultaneamente **filosofia** e **politica**. La parte "politica" include le scelte particolari o solo possibili, mentre la parte "filosofica" (il diritto come filosofia) è un compito coesistente con il diritto stesso.
- Se il diritto fosse interamente pervaso dalla politica e privo dell'elemento filosofico, sarebbe intrinsecamente **contraddittorio**, in quanto sfuggirebbe all'**incondizionato** dal quale ogni altra condizione dipende.

L'ordinamento giuridico non può prescindere da obblighi fondamentali e necessari. Ad esempio, è obbligatorio comportarsi secondo la **Costituzione effettivamente statuita ed efficace** (la *Grundnorm*).

Inoltre, non sono concepibili sistemi giuridici che legalizzino la **violenza nei confronti dell'innocente**. Un ordinamento che facesse ciò negherebbe l'**idea stessa di umanità** e, di conseguenza, il **diritto** medesimo. È proprio questa ineludibile necessità che rende il diritto principalmente **filosofia del diritto**.

L'orientamento della filosofia verso l'universale solleva interrogativi fondamentali: può esistere il diritto senza una **giustificazione**? Qual è la natura del rapporto tra diritto e **ragione**?

L'**universale** rappresenta la forma più alta di giustificazione. Si consideri la **"dimostrazione"** in senso stretto, che possiede un valore universale in quanto non ammette eccezioni di fronte al quantificatore "Tutti". Un esempio è la dimostrazione della trascendenza di e sul campo dei numeri razionali (Q), completata da Charles Hermite nel 1873.

Sebbene la ragione giuridica fatichi a eguagliare il rigore dell'algebra, l'elemento cruciale è la **proporzione** tra il **grado di verità** e l'**universale**:

- Quanto più il diritto è giustificato, tanto più si apre all'universale.

Questo principio può essere riformulato specificando la sua relazione con l'umanità:

- Quanto più il diritto è giustificato, tanto più trova nell'**umanità** il suo inizio e il suo compimento.

Non è l'umanità a liberarsi attraverso il diritto, ma è il **diritto ad avere bisogno dell'umanità**. Senza l'umanità, il diritto non è nemmeno pensabile, né tantomeno può sussistere.

Questa conclusione fondamentale verrà spiegata attraverso due prospettive: una **"epistemica"** e una **"politica"** in senso lato.

La validità delle norme giuridiche presuppone la loro **giustificazione** per via della loro stessa definizione. Per definire la norma giuridica, si ricorre al metodo di Aristotele: individuare il **"genere prossimo"** e la **"differenza specifica"**.

La norma giuridica appartiene al genere prossimo delle **"norme"** (come l'uomo appartiene al genere degli "animali razionali"). Il diritto, tuttavia, non è l'unico tipo di norma esistente; esistono anche le norme morali, come l'imperativo evangelico "Ama il prossimo tuo come te stesso", che non sono regole giuridiche.

Per distinguere la norma giuridica dalle altre, come le norme morali, si identificano almeno due importanti **differenze specifiche**:

- **Dovere Giuridico:** Implica essenzialmente un'azione **esterna** del soggetto. La regola giuridica della fedeltà, ad esempio, non giudica i propositi interni, ma richiede azioni specifiche (come il pagamento del prezzo nel contratto o la fissità della dimora tra coniugi). È **bilaterale-attributivo**. A ogni dovere corrisponde l'**autorizzazione** dell'altro soggetto a esercitare la propria pretesa, se necessario, tramite la **coazione** (ad esempio, l'inadempimento di un negozio giuridico suppone i mezzi per essere risarciti).
- **Dovere Morale:** Si concentra sull'impulso **interno** del soggetto. Nella morale, la fedeltà è un fatto dell'anima; gesti interni (come la distrazione o l'insofferenza) *sono* l'infedeltà, ma non costituiscono fatti rilevanti per il diritto. Manca di bilateralità attributiva. Espressioni come "Mi devi amare a tutti i costi!" sono paradossali, poiché la carità (*gratia gratis data*) scompare con la pretesa, e la compassione soccombe alla costrizione.

Un ordine totalmente immorale, come "O la borsa o la vita", non è considerabile una norma giuridica. Esso esprime un dovere, ma è una **norma delinquenziale** la cui essenza è l'interesse prioritario per la "borsa" (la costrizione, l'uso assoluto della forza, il semplice arbitrio, la fisica e non la metafisica).

Ciò che manca alla norma delinquenziale e, in definitiva, a una norma che si basa solo sulla forza, è la **giustificazione**. Chi proferisce l'ordine "O la borsa o la vita" non intende dare alcuna ragione, ma mira solo a effetti pragmatici (ottenere la borsa senza discutere). La richiesta di motivazione da parte della vittima risulterebbe ridicola. L'azione fondata sulla "mistica del potere senza autorità" annulla la verità e con essa l'essere.

La **differenza specifica** della regola giuridica risiede dunque nella sua **giustificazione** per ogni possibile destinatario.

Chi crea o applica il diritto non può limitarsi a dire cosa si deve o non si deve fare, ma deve offrire una **motivazione**, possibilmente una **ragione universale**. Il diritto, per definizione, non è sufficientemente espresso dal solo "senso di un atto di volontà" (*Willensakt*) di Kelsen; esso necessita dell'aggiunta del **senso di un atto di ragione** (*Vernunftsakt*).

La seconda spiegazione del rapporto tra diritto e ragione è di ordine **politico in senso lato** e afferma un principio di proporzionalità: una norma quanto più è **giustificata**, tanto più è **efficace**; viceversa, una norma assolutamente ingiustificata perde efficacia e finisce per negare sé stessa.

Un esempio di norma inefficace è la **norma inesigibile** fin dall'inizio. Kant, nella *Metafisica dei costumi*, affronta il "diritto di necessità" (*Nothrecht*), citando il caso di una norma penale che condanni a morte chi, in un naufragio, si salva a discapito di un altro in pari pericolo.

Kant sostiene che una simile disposizione sarebbe **praticamente impossibile**: nessuno la prenderebbe sul serio, ed è difficile che qualcuno scelga liberamente un danno certo (la morte per naufragio) anziché un male solo probabile (un'eventuale condanna).

Implicazioni Politiche:

- Non è politicamente opportuno (*corretto*) che le norme siano inesigibili.
- Un potere al quale si obbedisce solo per forza ha una durata limitata.
- Il legislatore ha un interesse primario a emanare leggi che siano **rispettate** e non aborrite dai destinatari.

Un'ipotesi ancora più radicale, che comprometterebbe l'intero ordinamento, è il caso della **"legge impossibile"** teorizzata da Lon L. Fuller in *La moralità del diritto* (1964).

Si immagini una legge che liberi tutti i membri del Parlamento da ogni limitazione legale, autorizzandoli a rubare, uccidere e violentare senza sanzioni penali. In un caso del genere, i destinatari avrebbero **più rischi a obbedire che a disobbedire**. Inoltre, tale legge neutralizzerebbe l'intero ordinamento: il Parlamento potrebbe continuare a emanare norme, ma nessuno le osserverebbe.

Dal punto di vista politico, **non ha senso costringere l'ordinamento a una sua inevitabile ineffettività**. La cura per questa inefficacia è la **giustizia**, nella quale sussistono la giustificazione e la ragione fondata di un dovere necessario. Come espresso nel brocardo: "Non videtur esse lex quae iusta non fuerit" ("Non si reputa essere legge quella che non sia stata giusta").

Quando l'argomento politico giunge alla conclusione che non **"conviene"** a nessun legislatore (traducendo così la categoria politica dell'interesse pubblico) fare leggi non giustificate perché inefficaci, si torna inevitabilmente all'argomento epistemico della definizione.

Ciò che qui "conviene" è, ancora una volta, il **significato stesso del diritto**: le leggi prive di efficacia, o che mascherano la costrizione da obbligo giuridico, **non sono autentiche leggi**.

Questa verità è riassunta dalla conversazione tra il Re e il Piccolo Principe:

> "Se ordinassi a un generale di volare da un fiore all'altro come una farfalla... e se il generale non eseguisse l'ordine ricevuto, chi avrebbe torto, lui o io?" "L'avreste voi", rispose il Piccolo Principe. Il Re conclude: "Esatto. Bisogna esigere da ciascuno quello che ciascuno può dare... L'autorità riposa, prima di tutto, sulla **ragione**. Se tu ordini al tuo popolo di andare a gettarsi in mare, farà la rivoluzione. Ho il diritto di esigere l'ubbidienza perché i miei ordini sono **ragionevoli**".

La piena autorità e il diritto di esigere obbedienza si basano sulla **ragionevolezza** e sulla possibilità di esecuzione degli ordini.

Politica e diritto

Il diritto è intrinsecamente connesso sia alla **filosofia** che alla **politica**.

La **filosofia** è definita come la scienza dell'universale, in netto contrasto con la **politica**, che si concentra sul particolare. La filosofia si dedica allo studio della **possibilità** dei fenomeni, mentre la politica si occupa dei fenomeni che sono *solo* possibili. Attraverso l'analisi della possibilità dei fenomeni, la filosofia è in grado di cogliere l'universale del diritto.

Inoltre, l'analisi della *possibilità* (e non di ciò che è semplicemente possibile) permette di discernere se il possibile sia tale in modo meramente contingente, se sia impossibile o, al contrario, se sia inevitabilmente possibile e quindi **necessario**.

D'altra parte, il diritto è anche **politica**, poiché si concretizza attraverso le decisioni particolari prese dal giurista.

Nonostante la filosofia e la politica non siano la stessa cosa, la politica ha un legame con la filosofia, almeno in quanto ne diviene **oggetto di studio**. La politica è infatti considerata un momento ineludibile e inevitabile del processo giuridico; il diritto non è concepibile senza la politica.

Tuttavia, anche in questo contesto (in cui si studia la politica come parte del processo giuridico), la filosofia si riconferma nella sua natura di **scienza dell'universale**.

L'ordinamento giuridico non costituisce un sistema immutabile e statico, paragonabile all'aritmetica peaniana o all'Essere parmenideo, identico e uniforme in ogni suo punto. Al contrario, esso è in un perpetuo **divenire**, ripudiando la fissità. Si configura, piuttosto, come una concatenazione potenzialmente illimitata di atti ed è, essenzialmente, **dýnamis**, ossia azione e attività, in netta opposizione all'Essere di Parmenide.

L'attività giuridica si articola in due grandi ambiti distinti strutturalmente:

1. **Atti che creano nuovo diritto oltre il diritto esistente (Legislazione):**
    - Il **legislatore** emana le leggi.
    - Prevalgono i **giudizi di valore**.
    - Lo scopo è rispondere all'insistente necessità di regole negli spazi privi di regolamentazione della realtà sociale; si legifera, quindi, per l'**assenza** e non per la presenza di norme.
    - Si richiede che le leggi prodotte siano **giuste**. Il legislatore **pone** (*setzen*) le leggi.
2. **Atti che producono diritto dal diritto esistente (Giurisdizione):**
    - Il **giudice** non crea le leggi.
    - Non si spinge oltre il diritto vigente, ma dà vita a norme per lo più individuali (le sentenze) derivanti dall'applicazione delle leggi.
    - Si fonda sulla **validità** delle leggi all'interno dell'ordinamento, non sulla loro giustizia; l'attività giudiziaria dipende unicamente dalle leggi esistenti.
    - Il giudice **presuppone** (*voraussetzen*) le leggi. L'attività è definita *iuris dictio*, ovvero "dire il diritto".

La differenza tra i due ambiti è illustrata anche dal tipo di giudizio: al legislatore spetta il **giudizio di valore** ("La legge è giusta"), mentre al giudice compete il **giudizio di validità** ("La legge è valida") ed è chiamato ad applicare le norme, non a crearle.

Un'ulteriore distinzione riguarda il "numerus motus," cioè il numero di azioni possibili. Il legislatore può intervenire in modo potenzialmente illimitato sullo stesso problema socio-politico, fornendo risposte multiple, talvolta opposte, e creando potenziali conflitti tra norme (antinomie), come testimoniato dall'abrogazione implicita prevista dall'art. 15 delle Preleggi.

Al contrario, l'attività del giudice deve pervenire a una **soluzione unica** e definitiva per non vanificare la certezza del diritto e l'efficacia delle norme. Le risposte possono cambiare con i gradi di giudizio, ma si deve giungere a una sentenza **inappellabile** e **definitiva**, oltre la quale non è più ammessa sostituzione (fatti salvi mezzi straordinari di impugnazione).

Infine, la giurisdizione implica l'**obbligo formale di motivare** le sentenze (Art. 111, comma 6, Costituzione), un requisito che, almeno nella forma esterna, non sussiste per l'attività legislativa.

L'ipotesi che la legislazione possa sostituirsi alla giurisdizione, creando tante norme quanti sono i fatti della vita, è ritenuta un'impresa irrealizzabile. Tale tentativo, come quello di un cartografo che disegni una mappa grande quanto il territorio da rappresentare, si scontra con l'illimitata molteplicità dei fatti, non solo in un singolo momento ma nel corso di infiniti eventi storici (due infiniti). L'esempio storico del *référé législatif* in Francia (1790) dimostra la pratica impossibilità di tale approccio, avendo causato la paralisi dei processi e la violazione del principio di separazione dei poteri.

L'ordinamento giuridico è in **continuo divenire** (differenza, non identità) poiché è intrinsecamente legato al **mondo** e a tutto ciò che in esso accade. L'ordinamento serve al mondo, così come il mondo serve al diritto, e la sua funzione è aderire al mutare continuo della realtà sociale e rispondere ai suoi bisogni tramite le regole.

Esiste un problema pressante: le regole non sono mai sufficienti a coprire tutti i fenomeni. L'ordinamento si trova in una condizione simile alla mano che cerca di toccare il polso al suo interno: non vi riesce mai completamente. Di conseguenza, nascono incessantemente **spazi vuoti** (lacune) che devono essere colmati per evitare l'inefficacia dell'intero sistema.

Si distinguono due principali tipi di lacune:

1. **Lacune Ordinamentali (o Sistemiche):**
    - Sono quelle in grado di investire e minacciare la tenuta dell'intero sistema giuridico ed economico.
    - Un esempio storico è l'inflazione catastrofica del marco nella Repubblica di Weimar (1923), un "aleph[3]" che conteneva tutti i problemi del sistema.
    - A queste lacune risponde tipicamente il **legislatore** (ad esempio, introducendo una nuova valuta).
2. **Lacune Locali:**
    - Sono casi non previsti che non implicano di per sé una modifica strutturale del sistema.

[3] l'aleph rappresenta l'Unità primordiale, il Principio che contiene in sé il tutto come un seme l'intera pianta

- Di queste si occupa il **giudice** attraverso i procedimenti della logica giuridica, come l'**interpretazione** o gli argomenti per **analogia** e *a contrario*. Il giudice colma queste lacune senza dover scomodare il legislatore. Un esempio è il caso dell'orso in una stazione che vieta l'ingresso ai cani (di Jhering).[4]

Alcune dottrine, in particolare il **"legalismo giuridico"** (secondo cui "la legge è tutto il diritto"), sostengono che l'ordinamento non sia affatto incompleto.

Il pilastro di questa tesi è la norma sulla **tassatività della fattispecie penale** (Art. 1 Codice penale: "Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge...").

- Secondo questa visione, ogni caso non previsto (lacuna) in diritto penale riceve una **previsione indiretta**, ossia un **"permesso"**. La norma si riformula: "Ciò che non è previsto è permesso."
- In questo modo, l'ordinamento è solo **apparentemente incompleto**, perché la non previsione è condizione sufficiente per determinare una precisa qualificazione deontica.
- Logicamente, in assenza di obbligo o divieto, il permesso è l'unica possibilità: sarebbe illogico trattare un caso non previsto come vietato o obbligatorio.

Vengono mosse diverse obiezioni al legalismo giuridico e al principio di tassatività esteso a tutto l'ordinamento:

1. Il principio di tassatività e la conseguente regola generale di permissione o libertà valgono **solo in diritto penale** e non sono efficaci per completare l'intero ordinamento.
2. Per il diritto civile (e non solo), l'**Art. 12 delle Preleggi** prevede espressamente l'esistenza di "controversie che non possono essere decise con una precisa disposizione" e affida la soluzione al giudice tramite il ricorso a norme che regolano **"casi simili o materie analoghe"**. Non vi è alcuna conversione automatica del non previsto in permesso.
3. Non è semplice trovare fatti "espressamente previsti", poiché le norme non possono prevedere le infinite differenze tra i fatti della vita. Le leggi sono soggette a interpretazione e possono risultare ambigue.
4. Le lacune non sono solo *praeter legem* (mancanza di norme), ma anche ***intra legem*** (le norme ci sono, ma non sono chiare e richiedono interpretazione). Questo "scarto" tra ciò che è previsto e i casi della vita crea continuamente spazi vuoti, anche in diritto penale.
5. Dal punto di vista del senso comune, è illogico dire che è "permesso" ciò che non si conosce. Il giudizio valutativo richiede la conoscenza dell'oggetto; un caso non previsto è, per definizione, ignorato, rendendo il giudizio di permissione totalmente infondato (sebbene questa obiezione sia meno pertinente per un codice penale mirato alla certezza della responsabilità).

---

[4] **La Norma:** In una stazione ferroviaria, è affisso un cartello o un regolamento che stabilisce: **"È vietato l'ingresso ai cani"** (*Hunden ist der Eintritt verboten*).
Il Fatto: Un viaggiatore si presenta alla stazione accompagnato non da un cane, ma da un **orso** (un animale selvatico e di solito più pericoloso di un cane domestico).
Il Dilemma: Le autorità della stazione si trovano di fronte al problema: possono impedire l'ingresso al viaggiatore con l'orso basandosi sul regolamento che vieta solo i *cani*?
Argomentazione: Il regolamento vieta espressamente solo i "cani". Un orso non è un cane.
Risultato: Non essendoci un divieto esplicito per gli orsi, il viaggiatore **dovrebbe essere autorizzato** a entrare con l'orso.

In conclusione, il principio di tassatività non occupa tutto l'ordinamento, e almeno nel diritto civile, i casi non previsti non si risolvono con una regola generale di libertà, ma con il meccanismo di **analogia** del giudice.

Si ripropone la distinzione tra le due funzioni di creazione del diritto: se le lacune sono **ordinamentali** (sistemiche), spetta al **legislatore** fare nuove leggi; se sono **locali** e riguardano l'applicazione della legge, il **giudice** ricava nuovo diritto da quello esistente.

Mentre il ruolo **politico** del legislatore è facilmente riconoscibile (ad esempio, nelle leggi finanziarie o di stabilità), non è altrettanto immediato attribuire questa natura all'attività del giudice. Tradizionalmente, la giurisdizione viene descritta come una funzione **"per *conclusionem atque determinationem*"** (per conclusione e determinazione), modellata sul sillogismo aristotelico.

> Ad esempio, nel sillogismo "Tutti gli uomini sono mortali" (premessa maggiore), "Socrate è un uomo" (premessa minore), la conclusione "Socrate è mortale" non aggiunge contenuto, ma lo esplicita, poiché il termine 'Socrate' è già implicito nel quantificatore universale 'Tutti'. Il compito del giudice sarebbe, in modo analogo, **deduttivo**, con il diritto vigente a fare da premessa.

In realtà, anche la **giurisdizione è politica**. Il giudice non si limita a dare l'unica risposta possibile, ma opera una **scelta** tra risultati alternativi. Pur non trattandosi della politica dei partiti, essa è espressione del **mondo delle decisioni** e delle **visioni parziali** del soggetto giudicante, posizionate nel suo "punto zero" (*Nullpunkt*), dal quale non può ammettere indifferentemente tutte le possibili interpretazioni o visioni.

Il senso politico della giurisdizione risiede nei presupposti stessi della logica giuridica, in particolare nella **plurivocità del linguaggio giuridico**:

- È difficile, forse impossibile, trovare fatti **"espressamente previsti"** dalle norme. I casi reali sono unici e irripetibili, marcati dalla *haecceitas* (questaità, individualità), mentre le norme sono **generali e astratte**.
- Le norme non possono nominare in sé tutto ciò che accade e sono inevitabilmente ambigue. Esempi di espressioni vaghe sono 'ordine pubblico', 'interesse generale', 'pubblica necessità' o 'urgenza'.
- Termini come la **"doverosa diligenza"** (*due care* nel diritto anglo-americano) non hanno un significato preciso se non in relazione alle singole circostanze concrete, potendo risultare inutile o persino dannoso applicare la regola generale in determinate situazioni.
- Anche termini all'apparenza semplici, come la parola **"fatti"** nell'Art. 2621 del Codice civile (false comunicazioni sociali), generano ambiguità: sia il fatturato che la giacenza in magazzino sono "fatti", ma non sono interscambiabili. Ci si interroga su *quali* e *quanti* fatti si parli, evidenziando che la previsione non è "espressa" nel senso di univoca e determinata.

Le norme giuridiche (salvo le sentenze che sono norme individuali e punto di arrivo) non regolano fatti singoli ma la loro **generalità**. Di conseguenza, il giudice è costantemente chiamato a **colmare gli spazi vuoti** della legge, eseguendo operazioni che sono contemporaneamente **semantiche** (interpretazione) e **sintattiche** (derivazione di nuovo diritto dal codice). L'esame del livello sintattico aiuta a comprendere anche l'interpretazione.

L'Art. 12 delle Preleggi stabilisce che se una controversia non può essere risolta con una disposizione precisa, si deve ricorrere a **"disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe"**. Questo introduce il procedimento fondamentale per colmare le lacune: l'**analogia** o argomento *a simili*.

Esempio dell'Orso e del Cane:

- **Norma N^1 (letterale):** "È vietato l'ingresso ai cani".
- Il caso dell'orso non è incluso in N^1 secondo il "significato proprio delle parole".
- Il giurista ricorre all'**interpretazione teleologica** (secondo il fine o *ratio*) per comprendere lo scopo di N^1, che è impedire un danno alle persone.
- Questa interpretazione conduce a una **nuova norma (NN)**: "È vietato l'ingresso ai cani e a tutti gli animali che come i cani possono arrecare danno ai viaggiatori in sala d'aspetto".
- Infine, da NN si deriva la **norma N^2**: "È vietato l'ingresso agli orsi", poiché l'orso, come il cane, rientra nella *ratio* di arrecare danno.

Il procedimento per analogia richiede un **tertium comparationis** (terzo termine di paragone) che fondi l'essenzialità delle somiglianze tra il caso previsto (il cane) e quello non previsto (l'orso). L'Art. 12 delle Preleggi stabilisce l'argomento *a simili*, ma suppone implicitamente l'uso di una forma di interpretazione (in questo caso, quella teleologica) per individuare il *tertium*.

Il *tertium comparationis* non deriva solo dall'interpretazione teleologica, ma anche da quella **dogmatica**, che si basa sui concetti fondamentali della dogmatica giuridica.

- Ad esempio, se si deve stabilire una garanzia della volontà per il testamento, si può usare il concetto di **"negozio giuridico"** come *tertium comparationis*.
- Poiché il contratto (per cui tali garanzie sono previste) e il testamento sono entrambi **specie** del **genere** "negozio giuridico", le garanzie che valgono per il negozio e, di conseguenza, per il contratto, devono valere anche per il testamento.
- In questo modo, la relazione dogmatica tra i concetti permette di interpretare una norma sul testamento alla luce di una norma sul contratto. L'Art. 12, pur non menzionandola, suppone anche l'interpretazione dogmatica.

L'argomento *a simili* si basa sulle somiglianze, ma l'esistenza di una somiglianza implica sempre anche una **differenza**. Quando, invece delle somiglianze, prevalgono le differenze, si applica l'**argomento *a contrario***.

Esempio di Differenza:

- Se un poliziotto con un cane antidroga o un cieco con il suo cane guida cercano di entrare, pur essendo cani (somiglianza), il fine pubblico (interesse generale) o l'esigenza personale prevalgono. In questo caso, l'interpretazione teleologica porta a una norma NN più complessa: "È vietato l'ingresso ai cani e a tutti gli animali che... possono dare fastidio... **salvo i casi in cui si configuri al contrario un interesse generale**". Da questa nuova norma si deriva la **norma N^3** che ammette l'ingresso del cane del poliziotto o del cieco (esclusione dal divieto).

L'argomento *a contrario* non è esplicitamente previsto nel codice, ma è introdotto dalla logica stessa del procedimento per analogia, poiché dove non contano le somiglianze, prevalgono le differenze. Il codice che stabilisce l'analogia dispone implicitamente anche l'argomento *a contrario*.

Gli argomenti **per analogia** (*a simili*) e **a contrario** sono strumenti interpretativi che si basano, rispettivamente, sulle **somiglianze** o sulle **differenze** tra un fatto noto (previsto dalla norma) e un fatto non previsto. La loro applicazione dipende dal giudizio di rilevanza assegnato a tali somiglianze o differenze rispetto a un *princeps analogato* (il caso normato).

Un esempio storico è la successione: se un'antica legge stabiliva benefici per i figli maschi eredi per salvaguardare il patrimonio familiare, si tendeva a privilegiare le differenze, escludendo le figlie dall'estensione di tali disposizioni. Oggi, il contesto è cambiato e l'estensione alle figlie risulterebbe più probabile.

La necessità di ricorrere a questi argomenti è indubbia, dato che la regola di trattare casi simili in modo simile e casi differenti in modo differente è un criterio di **giustizia formale**. Tuttavia, la questione principale riguarda il significato logico di tali procedimenti.

In realtà, non esistono criteri rigorosamente logici né per scegliere tra un tipo di interpretazione (analogia o a contrario), né per ottenere un unico risultato da un'unica interpretazione. Inoltre, **manca un confine certo** tra la regola che tratta i casi simili e quella che tratta i casi differenti.

Per poter applicare gli argomenti *a simili* o *a contrario*, il giudice deve adottare un'interpretazione diversa da quella **letterale**. Se, ad esempio, la norma vietasse letteralmente "l'ingresso ai cani" (N^1), interpretata secondo il "significato proprio delle parole", il divieto riguarderebbe solo ed esclusivamente i cani (escludendo un orso) e tutti i cani, inclusi quelli di servizio (del poliziotto o del cieco).

È necessaria, pertanto, l'**interpretazione teleologica** (basata sullo scopo) o un'altra interpretazione che consenta di fissare un termine di paragone oltre il significato letterale per includere o escludere un caso non previsto (N^2).

L'**Art. 12** delle preleggi stabilisce la priorità dell'interpretazione letterale: "Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse [...]".

Tuttavia, l'interpretazione letterale è insufficiente quando una controversia "non può essere decisa con una precisa disposizione". La difficoltà risiede nello stabilire quando l'interpretazione letterale non sia più solo il punto di partenza, ma diventi insostenibile.

Alla fine, la determinazione se manchi una "precisa disposizione" spetta al **giudice**. Questo sposta la questione dalla logica alla **politica** della giurisdizione.

- Nello "Stato di diritto" prevalgono gli argomenti **semantici** (applicazione letterale).
- In visioni come la "giurisprudenza degli interessi" o le dottrine sulla *Natur der Sache* (natura della cosa), prevale lo **scopo della legge** rispetto al mero significato delle parole.

Anche adottando l'interpretazione teleologica, sorgono ulteriori problemi sul significato del termine "**scopo**" di una norma. Se ne possono intendere almeno tre:

1. **Il motivo soggettivo del legislatore (Intenzione):**

    - L'art. 12 menziona l'intenzione del legislatore, ma è difficile definirne il soggetto esatto (non è solo la maggioranza parlamentare, ma include opposizioni, burocrazie, parti sociali, ecc.).
    - Si pone il problema di quale intenzione considerare: quella del legislatore storico che ha emanato la legge, o quella dei legislatori successivi.
2. **Gli effetti reali della norma:**
    - Si riferiscono a ciò che le norme perseguono nella realtà, al di là della volontà di chi le ha poste. Ad esempio, il mutamento sociale (come il maggiore inserimento delle donne nel sistema produttivo) ha portato a nuove applicazioni e limitazioni di norme, come quelle sui fondi patrimoniali della famiglia in Inghilterra.
    - Questo approccio richiede comunque un **giudizio soggettivo** da parte del giurista per stabilire quando le conseguenze reali sono accettabili e quando no.
3. **Gli effetti ideali della norma (Scopo ideale):**
    - Non sono le intenzioni o gli effetti reali, ma lo scopo **obiettivo** per cui un istituto giuridico esiste.
    - Ad esempio, il diritto penale societario, nato per tutelare il patrimonio delle società, ha visto una crescita del potere societario che ha messo a rischio la libertà dei mercati. Per questo, il nuovo diritto societario ha assunto profili pubblicistici, concentrandosi sul **bene dei mercati** prima che sull'interesse privato dell'impresa.

In conclusione, anche stabilendo un tipo di interpretazione, la scelta del concetto di "scopo" (intenzione, effetti reali o scopo ideale) è parziale e implica la **valutazione soggettiva** e la decisione del giurista.

La terza osservazione riguarda il confine tra i procedimenti di logica giuridica. La **somiglianza** implica sempre la **differenza**, poiché la somiglianza non è identità.

- Si procede per **analogia** quando le somiglianze sono considerate **essenziali**.
- Si procede **a contrario** quando prevalgono le differenze.

Il problema risiede nel calcolare questa "essenzialità" e stabilire il criterio. Poiché somiglianze e differenze sono astrattamente giustificabili come essenziali a seconda dei punti di vista, in concreto è difficile stabilire la prevalenza dell'una o dell'altra. La presunta certezza di un procedimento rispetto all'altro non è applicabile nella pratica (*Praxis*), come ricordava un detto kantiano.

Esempi di ambiguità:

- Un cane poliziotto indisciplinato che causa danni nell'area di attesa: dovrebbe essere escluso dal divieto solo perché è un cane di servizio, o incluso per il suo comportamento?
- I bacilli della tubercolosi: sono "animaletti pericolosi" da escludere, analoghi al cane pericoloso, o no?
- Il divieto di sfilare con bandiere rosse (Germania guglielmina): è esteso alle bandiere lilla (argomento a contrario per la differenza di colore) o no (analogia per lo scopo politico)?

In un contesto di **Common Law**, la difficoltà è ancora maggiore, come nel caso del commerciante che vince un contratto violando i limiti di velocità. Sebbene il suo comportamento non sia un illecito contrattuale, un concorrente sconfitto potrebbe tentare l'analogia tra la condotta e un illecito generale. Data l'estrema generalità della responsabilità extra-contrattuale, non è detto che il concorrente vinca la causa.

In ultima analisi, in tutti i casi citati, l'esito dipenderà in gran parte dalla **decisione soggettiva del giudice**.

La giurisdizione non è affatto immune dalla politica. L'uso dei procedimenti della logica giuridica (come gli argomenti per analogia o a contrario) dimostra chiaramente il **ruolo politico del giudice**.

Questo significato politico non è da ricercare in condizionamenti esterni (come l'influenza di partiti di governo/opposizione o *lobbies*). Al contrario, il senso politico risiede negli **interstizi della decisione giuridica stessa**, emergendo ben prima di qualsiasi influenza di partiti o gruppi di interesse.

La domanda cruciale è se il processo possa liberarsi dal potere politico esercitato dal giurista. La risposta è negativa.

Il giudice è vincolato a decidere per un duplice dovere, che rende inevitabile la dimensione politica della sua azione:

1. **Dovere come Obbligo (*Sollen*)**

La decisione giuridica, e di conseguenza la politica, scaturisce innanzitutto da un **obbligo formale**.

- Nelle moderne codificazioni, il giudice è soggetto all'obbligo di decidere.
- Il **Codice di Napoleone** (1804), modello per le principali codificazioni europee, stabilisce espressamente all'Art. 4 il **divieto di denegare giustizia** (*déni de justice*).
- In base a questo divieto, il giudice non può rifiutarsi di emettere una sentenza adducendo come motivo o pretesto l'oscurità o l'insufficienza della legge.
- Questo divieto formale costituisce, per sua natura, una fonte inevitabile di decisioni e, quindi, di politica.

2. **Dovere come Necessità (*Müssen*)**

La decisione giuridica, e quindi la politica, è anche la conseguenza di una **necessità intrinseca**.

- L'astensione dalla decisione, o il **non liquet** (la dichiarazione di non poter decidere a causa di lacune o oscurità normative), si configura essa stessa come una forma di decisione.
- Scegliere di non decidere equivale a **scegliere di non scegliere**.
- Colui che dichiara di non decidere sta, di fatto, prendendo una decisione (la non-decisione) con tutte le conseguenze che ne derivano.

In sintesi, la politica non viene annullata, ma **trasformata** e inglobata nel processo decisionale stesso.

Una sentenza o un'interpretazione giuridica, se fosse priva della benché minima giustificazione – come interpretare la Costituzione alla stregua di "orari dei treni" – non sarebbe considerata un atto giuridico valido. È impensabile che una sentenza possa concludersi con la dichiarazione di essere "sotto ogni aspetto priva di qualsiasi motivazione"; un'azione del genere equivarrebbe a disfare l'atto nel momento stesso in cui viene compiuto.

Per comprendere la funzione della giustificazione, occorre distinguere due tipi di linguaggio:

1. **Linguaggio Performativo:** Il soggetto **fa** (*to do*) ciò che dice in virtù del suo stesso atto di dire. Esempi includono la dichiarazione di guerra o il "Sì" nuziale.
2. **Linguaggio Constatativo:** L'enunciato si limita a **descrivere** il mondo, il quale esiste prima e indipendentemente dalle parole. Ad esempio, dicendo "Oggi c'è il sole" non si provoca il sorgere del sole; l'enunciato può essere falso e non basta pronunciarlo perché la realtà cambi.

Così come si possono fare cose con le parole, si può anche **disfare** (*to undo*) ciò che si sta dicendo. Se si dice "Insinuo che P", l'atto di enunciazione disfa l'insinuazione stessa, trasformandola in una denuncia aperta.

Questo fenomeno di "disfacimento" si pone al centro del rapporto con la sentenza del giudice e la sua **motivazione**.

La motivazione è una condizione essenziale della decisione giudiziale, stabilita sia dalla legge che dalla natura stessa dell'atto:

- **Condizione Formale (Obbligo Legale):** L'ordinamento italiano impone espressamente l'obbligo di motivazione.
    - L'**Art. 111 della Costituzione** stabilisce che "tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati".
    - La motivazione è fondamentale per il **controllo** sul rispetto della legge da parte dei giudici e per la possibilità di **ricorso in Cassazione**.
    - L'**Art. 527, comma 2, del Codice di procedura penale** richiede ai giudici di "enunciare le ragioni delle loro opinioni" durante la deliberazione collegiale.
    - Anche in ambiti privati, come il **diritto contrattuale**, gli atti devono essere interpretati in modo che siano ragionevoli e conformi al senso (Art. 1367 c.c.).
- **Condizione Trascendentale (Necessità Ontologica):** Al di là della legge, la motivazione è una regola **"trascendentale"** (nel senso kantiano), ovvero una condizione **indispensabile** per l'esistenza giuridica stessa della sentenza. Una sentenza immotivata agisce come l'enunciato inglese *to allege* ("affermare qualcosa come un fatto, ma senza una prova").

Se un soggetto afferma "Io asserisco P, ma senza una prova", vanifica il valore logico della sua asserzione. Allo stesso modo, se un giudice dichiara: "Sentenzio che P, senza un briciolo di spiegazione", o emette una decisione arbitraria ("Assolvo Arsène Lupin per i suoi irresistibili baffi"), il **verdetto esiste** materialmente, ma si va a **disfare il suo valore giuridico** e la sua legittimità *de iure*.

Questa azione viene definita una **nuova controperformatività**: la sentenza immotivata non è più l'atto di un giudice legittimo, ma è degradata a un mero "ordine di briganti".

Il giudice, quindi, deve rendere conto delle sue decisioni non solo in forza della legge positiva, ma soprattutto per la **natura delle cose** (oltre la legge). La necessità di fornire una motivazione logica e razionale è l'unico vero ostacolo e limite al potere politico del giurista.

Diritto e parola

Habent sua fata verba[5]

Il diritto, sebbene non sia *esso stesso* un linguaggio, ne possiede certamente uno. La forma di **atti linguistici** è assunta da innumerevoli atti giuridici, come decreti, sentenze, testamenti o negozi tra acquirente e venditore. Questi sono definiti "Speech acts", come teorizzato da John R. Searle.

Verbi come 'decretare', 'assolvere', 'promettere' e 'dichiarare' sono usati per l'esecuzione di questi atti. Tuttavia, l'esistenza di tali atti linguistici è condizionata dall'esistenza di **menti disposte a crederci e ad afferrarli**. A differenza dei fenomeni naturali (come le nevi o le montagne), che esistono indipendentemente dalla percezione umana, gli atti linguistici hanno bisogno di un soggetto che li colga.

Vi è poi una distinzione dei verbi utilizzati per l'esecuzione linguistica di atti giuridici effettuata dal filosofo Austen:

- **verbi verdittivi**: quando il soggetto esprime una sentenza (assolvere, condannare)
- **verbi espositivi**: quando il soggetto non giudica una cosa, ma prende una posizione rispetto al mondo (dichiarare, affermare)
- **verbi esercitivi**: sono quelli mediante i quali il soggetto non giudica ma esercita il potere, verbi quindi utilizzati dal legislatore (disporre, decretare)
- **verbi commissivi**: corrispondono alla coerenza del soggetto a compiere determinati atti in futuro (promettere, giurare)
- **verbi comportativi**: esprimono la dimensione sociale della vita del soggetto (salutare)

Risulta incomprensibile un diritto totalmente **muto**, assorbito in una sorta di "armonia prestabilita" leibniziana, dove mondi soggettivi diversi operano silenziosamente nello spazio pubblico del diritto senza linguaggio. Se mancasse il linguaggio, probabilmente mancherebbe anche il diritto.

Il diritto si ammutolisce o diventa superfluo in contesti come la **Civitas Dei agostiniana** o la Chiesa trionfante. In una Gerusalemme di santi, i codici che contengono divieti (come quelli di uccidere, rubare o truffare) perderebbero il loro senso. In questo scenario, non è il diritto a essere senza parola, ma la Civitas Dei rappresenta piuttosto la sua **lontananza o la sua sterilità**.

Ci si può chiedere cosa preceda il linguaggio nel diritto. Un'idea **archeologica** è rappresentata dagli scambi tra portoghesi e nativi sulle coste dell'Africa occidentale nel Quattrocento: i portoghesi lasciavano merci e i nativi le sostituivano con altre. A concludere l'accordo non serviva una dichiarazione verbale.

Simili negoziazioni si vedono ancora oggi (ad esempio, le strette di mano in un suk arabo). Questo suggerisce che il linguaggio non è solo verbale[6]. Molti fatti sociali possiedono un **linguaggio di gesti elaborato** in sostituzione delle parole:

---

[5] **Habent sua fata verba:** Il significato o l'impatto delle parole può cambiare nel corso del tempo o a seconda delle persone che le utilizzano o le interpretano. L'origine della frase è attribuita allo studioso latino **Terenziano Mauro**. Le parole non sono **statiche** e possono evolvere o acquisire nuovi significati a seconda di come vengono comprese e usate.

[6] Esiste un diritto non codificato, non scritto, muto, ma decisivo per rendere efficace ciò che è scritto

- Il saluto militare rigido.
- Il taglio dei nastri nelle cerimonie.
- L'imposizione delle mani nelle consacrazioni canonistiche.
- L'innocenza di uno sguardo nel lessico amoroso. Si arriva all'ipotesi che il riconoscimento e il consolidamento dell'appartenenza a un gruppo, come l'azione reciproca di spulciarsi tra gli uomini del neolitico, possa essere considerata **l'alba del diritto**.

Il diritto ha bisogno del linguaggio. Il quesito può essere ribaltato: esistono **enunciati normativi senza norme** corrispondenti? La domanda è se esista un linguaggio normativo slegato dalle norme.

Il diritto non ha senso senza un linguaggio, perché esso ha di certo a che fare con il diritto. Vi è una relazione anancastica (necessaria) tra norma e parola.

L'esempio della massima **"È vietato mangiare le fave"** è un enunciato normativo. Non è un articolo dei codici attuali, ma esprimeva un divieto valido per la comunità pitagorica oltre duemila anni fa. Il fatto di notare enunciati normativi al di fuori del codice implica che il **linguaggio non implica necessariamente il diritto**, ma non dimostra l'inverso, ossia che il diritto possa esistere indipendentemente dal linguaggio.

Il linguaggio giuridico è distante sia dalle "parole duellanti" di una discussione (come quella tra il lupo e l'agnello, dove la ragione non conta nulla) sia dalle **conversazioni innocue** (come i saluti tra colleghi, che non preannunciano azioni come l'uccisione).

Il linguaggio giuridico va **al di là** di essere semplicemente offensivo o inoffensivo. La sua funzione non è tanto quella di giudicare il mondo esistente, quanto quella di **costruirlo**.

Il linguaggio giuridico è caratterizzato da una chiara natura **"performativa"**. Questo concetto deriva dalla filosofia analitica sviluppata da John L. Austin, influenzato dal "secondo Wittgenstein" negli anni Trenta.

Il linguaggio performativo è quello attraverso cui il soggetto **fa ciò che dice in forza del suo stesso dire**. L'opera fondamentale di Austin, *How to Do Things with Words* (1962), tradotta in francese come *Quand dire c'est faire*, spiega questo fenomeno.

Per mezzo di queste enunciazioni performative, il soggetto non compie un'azione qualsiasi, ma realizza **esattamente l'azione che sta enunciando**, grazie alle parole stesse. Ad esempio, nel momento in cui si pronuncia "Ti prometto", nasce contestualmente la promessa; essa non esiste né prima né dopo le parole, ma **con esse**. È proprio con tali parole che si promette realmente qualcosa a qualcuno.

Un esempio chiaro nel contesto giuridico è la formula pronunciata dal Presidente della commissione di laurea: "In nome della legge La proclamo dottore in Giurisprudenza". Subito dopo la pronuncia di questa formula, e non prima o dopo, l'individuo **diventa effettivamente "dottore in Giurisprudenza"**.

Questo processo non si verifica, invece, con enunciati che descrivono un'azione, come "Mangio la mela". Affermare verbalmente di "mangiare la mela" non equivale di per sé a eseguire l'atto del mangiare; in caso contrario, i problemi della fame globale sarebbero risolvibili con facilità.

L'attività principale umana non è, come spesso si crede, limitata ai **giudizi che descrivono il mondo**. L'essere umano compie molto di più: promette e giura, assolve e condanna, firma contratti, saluta, dispone e nomina le cose.

L'attività umana è coinvolta nella **"costruzione della realtà sociale"** attraverso il linguaggio. Il precetto morale "Noli iudicare" (Non giudicare) viene superato e non è neanche preso in considerazione come passione meramente teorica, poiché la **realtà sociale non esisterebbe senza l'inevitabile *performance* delle parole** che si fondono con il mondo stesso.

Gli enunciati performativi, in sintesi, non sono la semplice descrizione di un fatto; essi **sono il fatto stesso che viene enunciato**.

Questo principio si applica sia al linguaggio ordinario che al **linguaggio giuridico**. Quando un legislatore pronuncia un'enunciazione tipica del diritto, ad esempio, "Si dispone che Op", egli compie un atto di "**disposizione**", che è il tema stesso dell'enunciato.

Questo concetto era già presente nel pensiero di Leonardus Lessius, che in *De justitia et jure* (1608) scriveva: *"Promissio, donatio efficiunt quod significant"*, ovvero **"La promessa, la donazione fanno ciò che dicono"**.

La performatività è considerata un fenomeno **intrinseco** al linguaggio, dove la parola è posta al principio e si espande performativamente.

Questo concetto si riflette nel Prologo al Vangelo di Giovanni: "In principio era il Verbo [Λόγος Logos, Verbum], [...] e il Verbo si fece carne". Qui, il *lógos* si fa carne, non limitandosi a produrre qualcosa da qualcos'altro, ma creando **ex nihilo**, dal nulla. Se Dio non creasse dal nulla, non sarebbe *causa sui* (causa di sé stesso), e ci sarebbe qualcosa prima di Lui.

Il senso di ciò si ritrova nella promessa: gli uomini scoprono l'idea di promessa (come la fede o la compassione) nelle proprie viscere, ma non sono anteriori a essa. Dio, invece, è prima del Tutto ed è l'origine dell'idea stessa di promessa.

La parola conserva un'**anima performativa** anche negli enunciati cognitivi. Affermazioni come "Mangio la mela" presuppongono implicitamente un'enunciazione performativa, ad esempio "Affermo che mangio la mela".

Nel primo caso ("Mangio la mela"), non c'è una *performance* dell'azione descritta (il mangiare). Nel secondo caso ("Affermo che mangio la mela"), il verbo performativo è "affermare" e la *performance* è una **dichiarazione solenne** che nasce con le parole, stabilendo una posizione irrevocabile sulle cose. Il passaggio tra il primo e il secondo enunciato è quasi diretto.

Attraverso il linguaggio, il soggetto tende sempre a **eseguire un'azione**, che scaturisce dai vari atteggiamenti intenzionali (come informare, giudicare, promettere, disporre, salutare). La parola è l'esecuzione di questi atteggiamenti assunti di fronte al mondo. Per tale motivo, la parola è **sempre performativa**, sia implicitamente che esplicitamente.

Ogni volta che il soggetto parla, sta mettendo in atto uno dei modi in cui prende posizione rispetto al mondo. La parola (*word*) diventa atto, e il dire non è solo un dire *su* qualcosa, ma è **questo stesso qualcosa**: gli atti con cui il soggetto dispone del mondo e, di conseguenza, il mondo stesso (*world*). Si può affermare che **Word è world**. Richiamando l'idealismo tedesco, il concreto è il concetto (la luce

che illumina la parola), mentre l'astratto e l'irreale sono il concreto. Il mondo che conosciamo, in sostanza, non esisterebbe senza il concetto, e quindi senza di noi.

Affinché la performatività si realizzi, sono necessarie precise condizioni:

Un elemento fondamentale è il dire, l'espressione vocale o scritta.

- Alcune espressioni (come "Queste lezioni di filosofia sono noiosissime") mantengono il loro senso anche se restano nell'animo; proferirle può alterare la pragmatica (es. i sospetti del professore), ma non il loro carattere descrittivo. La lezione non diventa noiosa per il fatto di essere detta.
- Al contrario, atti linguistici come "Ti ordino di non aprire bocca" o "Giuro di tacere" **non esisterebbero** se le parole fossero tenute rigorosamente dentro di sé. Pensare di sposarsi o dichiarare guerra non è sufficiente; è necessaria una **dichiarazione formale** (come il "Sì" nel matrimonio).
- Il dire implica un **atto individuale di appropriazione della lingua**, un passaggio dalla *langue* alla *parole* (secondo Ferdinand De Saussure).

Non è sempre necessario che le enunciazioni performative siano ricevute direttamente dal destinatario. Le dichiarazioni di guerra, per esempio, non sono pronunciate al cospetto del nemico (Mussolini informò gli ambasciatori e si rivolse al popolo dal balcone). Inoltre, non è sempre un **soggetto intenzionale** a produrre direttamente gli *speech acts*. Esempi ne sono le multe elevate dall'autovelox, dove il procedimento sanzionatorio (equivalente a "Ti infliggo una sanzione...") è avviato da un apparato elettronico, senza il pathos o la coscienza intellettuale e morale di un io intenzionale.

Le "condizioni di felicità" (*felicity conditions*) degli atti linguistici riguardano la grammatica:

- **Tempo Verbale:** Il verbo deve essere al **presente indicativo**. Un enunciato come "Ti *ho promesso* di incontrarti..." non è una promessa, ma la notizia di una promessa passata. È una promessa solo se si dice: "Ti **prometto** che...".
- **Persona:** L'enunciato deve essere alla **prima persona singolare** ("Giuro che servirò la pace..."). Un giuramento alla terza persona ("Oreste giura...") non ha forza performativa. Al limite, può essere alla prima persona plurale (nel giuramento solenne delle reclute).
- **Motivazione:** Le azioni del soggetto sono sempre al **presente qui e ora**. Compierle al passato (*in quanto passato*) è un controsenso; non si può eseguire un'azione passata o l'azione di un altro.

Una condizione finale, che connota gli atti giuridici in particolare, è la necessità di **lasciare tracce** per evitare che le parole siano sterili.

- Nel rito civile del matrimonio, l'ufficiale di stato civile chiede ai testimoni: "Avete udito?". Questo fatto corrisponde alla **redazione dell'atto di matrimonio**.
- Il termine "**atto**", usato per denotare gli effetti illocutivi del linguaggio performativo, indica anche il **documento**che registra tali effetti.
- Platone riteneva che la "tabula rasa" (il supporto per la registrazione) non dovesse essere né troppo fragile (per non perdere l'impronta) né troppo rigida (per poter ricevere i segni).

Il linguaggio giuridico distingue almeno **due categorie di enunciazioni performative**:

1. **Enunciazioni che esprimono un discorso costitutivo** di *status deontici* (obblighi[7], divieti[8], permessi[9]). Questa è la **θεσις (*thésis*),** ovvero la posizione, l'atto di porre qualcosa. Con la *thésis*, **il mondo si adatta alle parole**.
2. **Enunciazioni che appartengono a un discorso cognitivo** di *status deontici*. Questa è la **ρησις (*rhesis*),** ovvero il discorso, l'atto di parlare su qualcosa. Con la *rhesis*, **le parole si adattano al mondo**.

Si consideri l'esempio di un enunciato di obbligo (Op):

Tipo di Enunciazione	Soggetto	Formula	Verbo Performativo
Costitutiva (*thésis*)	Il legislatore	"Si dispone che Op"	"Disporre"
Cognitiva (*rhesis*)	Il giurista studioso	"Affermo che Op"	"Affermare"

Nonostante l'enunciato innestato ("È obbligatorio p") sia lo stesso in entrambi i casi, i due tipi di enunciazioni sono chiaramente differenti.

La distinzione è stata analizzata in modo approfondito da Amedeo G. Conte. L'enunciazione del legislatore ("Si dispone che Op") può essere etichettata come **"enunciazione performativa thetica"**, mentre quella del giurista studioso ("Affermo che Op") come **"enunciazione performativa rhetica"**.

Le enunciazioni performative thetiche **pongono deonticamente la deonticità** dell'enunciato innestato.

- **Potere Costitutivo:** Quando il legislatore decreta "Si dispone che 'È obbligatorio p' ", l'obbligo di p **nasce effettivamente**. Il *status deontico* (obbligo, divieto o permesso) è **costituito** proprio grazie all'enunciazione del legislatore. Il "porre deonticamente" è il risultato di questo potere costitutivo.
- **Auto-Verifica:** L'obbligo di p è costituito in forza dell'enunciazione performativa "Si dispone che Op". Di conseguenza, le enunciazioni thetiche **pongono la verità** dell'enunciato innestato. Lo *status deontico* descritto da "È obbligatorio p" nasce con l'enunciazione stessa, il che lo rende un enunciato che **si verifica da sé** (o si autoverifica) e non può che essere vero.

Le enunciazioni performative rhetiche, al contrario, **pongono soltanto cognitivamente la deonticità** dell'enunciato deontico[10] innestato.

- **Funzione Cognitiva:** Quando il giurista dice: "Affermo che Op", l'obbligo di p non nasce in virtù di questa enunciazione. Chi afferma che è obbligatorio p si limita semplicemente a **porre una cognizione** sull'esistenza di un obbligo all'interno di un dato ordinamento.
- **Indipendenza dalla Verità:** Non è in gioco la costituzione dello *status deontico*. L'obbligo, se esiste, è **già presente** prima e indipendentemente dall'enunciazione del giurista.
- **Vulnerabilità alla Falsità:** Le enunciazioni performative rhetiche **non sono in grado di porre la verità dell'enunciato** innestato. Quando il giurista dichiara "È obbligatorio p" (con

[7] OP
[8] O¬P
[9] ¬OP
[10] **Deontico (τό) δέον -οντος «il dovere»:** ciò che è necessario (obblighi, permessi, proibizioni e regole normative).

l'intenzione di comunicare le leggi dello Stato), compie un'affermazione che può essere **eventualmente falsa**. L'enunciato "È obbligatorio p" è falso se l'obbligo corrispondente non esiste realmente nell'ordinamento.

Ogni norma giuridica presuppone un'enunciazione performativa che crea o modifica l'ordinamento, formulata concettualmente come: "**Si dispone che il sistema S contenga la determinazione D**". In pratica, quando il legislatore pone una norma, modifica l'ordinamento (il "sistema S") introducendo una determinazione (D) che prima non esisteva.

Secondo Gaetano Carcaterra, la norma espressa dall'enunciato "Si dispone che il sistema S contenga la determinazione D" ha una duplice natura:

1. È una **"norma costitutiva"**.
2. È un vero e proprio **presupposto di tutto l'ordinamento**, poiché è grazie ad essa che ogni altra norma entra nel codice (dunque, deve esserci sempre una disposizione del legislatore del tipo: "D'ora innanzi vige la norma D").

Inizialmente, Carcaterra aveva adottato una visione "mista" (l'ordinamento conteneva sia norme prescrittive, le *Soll-Normen* kelseniane, sia costitutive). Successivamente, subentra la tesi **"unitaria"** del primato assoluto delle norme costitutive: tutte le norme, sia costitutive che prescrittive, presuppongono la forza costitutiva dell'enunciazione fondamentale "Si dispone che il sistema S contenga la determinazione D".

Ogni norma giuridica presuppone un'enunciazione performativa che crea o modifica l'ordinamento, formulata concettualmente come: "**Si dispone che il sistema S contenga la determinazione D**". In pratica, quando il legislatore pone una norma, modifica l'ordinamento (il "sistema S") introducendo una determinazione (D) che prima non esisteva.

Secondo Gaetano Carcaterra, la norma espressa dall'enunciato "Si dispone che il sistema S contenga la determinazione D" ha una duplice natura:

1. È una **"norma costitutiva"**.
2. È un vero e proprio **presupposto di tutto l'ordinamento**, poiché è grazie ad essa che ogni altra norma entra nel codice (dunque, deve esserci sempre una disposizione del legislatore del tipo: "D'ora innanzi vige la norma D").

Inizialmente, Carcaterra aveva adottato una visione "mista" (l'ordinamento conteneva sia norme prescrittive, le *Soll-Normen* kelseniane, sia costitutive). Successivamente, subentra la tesi **"unitaria"** del primato assoluto delle norme costitutive: tutte le norme, sia costitutive che prescrittive, presuppongono la forza costitutiva dell'enunciazione fondamentale "Si dispone che il sistema S contenga la determinazione D".

Le norme costitutive sono definite come quelle norme che **eseguono se stesse** nell'istante in cui sono validamente poste, **senza la mediazione di un agente** destinatario dell'ordine.

Si differenziano da un semplice ordine come "Si aprano le porte", perché agiscono su un **fatto istituzionale** (come la chiusura di una seduta):

- L'enunciato "La seduta è tolta" porta a termine i suoi effetti esclusivamente in forza delle parole pronunciate dal Presidente, non perché si attende la condotta di un agente. Appena il Presidente lo dichiara, la riunione è **formalmente conclusa** e non si può aggiungere altro.
- Le porte non sono sensibili a questo stesso potere costitutivo (salvo nei contesti favolosi come "Apriti Sesamo").

Le norme costitutive sono un fenomeno diffuso in tutti i livelli dell'ordinamento.

Esempi:

- **Art. 10 della Costituzione:** "L'ordinamento giuridico si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute". Con l'entrata in vigore della Costituzione, tutte le norme di diritto internazionale riconosciute sono diventate parte del nostro ordinamento **senza bisogno di ulteriori disposizioni**.
- **Art. 1 del Codice civile:** "La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita". La capacità giuridica è determinata dal **fatto esterno della nascita**, in forza della validità dell'articolo stesso, e non per una condotta irreprensibile del neonato.
- **Norme Abrogative:** Sono norme costitutive in quanto **abrogano una determinata norma** per effetto unicamente della loro validità, senza l'azione di un agente. L'esistenza di una norma abrogativa produce **di per sé l'invalidità**della norma abrogata.

L'enunciato "Si dispone che il sistema S contenga la determinazione D" è una norma costitutiva perché il suo schema è simile a quello di una norma abrogativa, ma senza il segno di negazione.

- **Norma Abrogativa:** Tipicamente si formula come: "Si dispone che il sistema S **non contenga** la determinazione D". In forza di essa, si fissa immediatamente l'**esclusione** di una norma dall'ordinamento.
- **Norma Costitutiva:** "Si dispone che il sistema S **contenga** la determinazione D". Si **include** una norma nel sistema S, ovvero nasce una nuova determinazione, senza l'ulteriore adempimento di un agente e grazie esclusivamente alla validità della norma che pone nuovi obblighi, divieti o permessi.

Le norme che prescrivono al legislatore di abrogare altre leggi non sono costitutive, ma **prescrittive**, poiché richiedono l'adempimento da parte del legislatore con nuove misure.

A differenza delle norme costitutive, le **norme prescrittive non eseguono se stesse** in forza della sola validità.

- **Esempio:** L'Art. 624 del Codice penale, che vieta il furto, non impedisce automaticamente il crimine. Se potesse produrre i suoi effetti solo per il fatto di esistere nel codice, non ci sarebbero furti e non servirebbe il diritto penale.
- **Requisito dell'Adempimento:** L'esecuzione di una norma prescrittiva richiede **atti di adempimento** da parte dei destinatari. Poiché tali atti sono potenzialmente infiniti, le norme prescrittive **non sono mai compiutamente eseguibili** (non esiste un atto che esegua una volta per tutte il divieto di fumare, ad esempio).

Ciò porta al **paradosso dell'esecuzione** delle regole.

Il paradosso di Wittgenstein, espresso nella proposizione 201 delle *Ricerche filosofiche* era: *"Il nostro paradosso era questo: una regola non potrebbe determinare alcun modo d'agire, poiché ogni modo d'agire potrebbe essere messo in concordanza con la regola"*.

Adesso, il paradosso è se si possa **eseguire** una regola. Non ha senso dire che le regole sono eseguite:

1. O perché sono **costitutive** e non necessitano di atti di adempimento.
2. O perché, se sono **prescrittive**, la loro esecuzione richiede un numero infinito di atti.

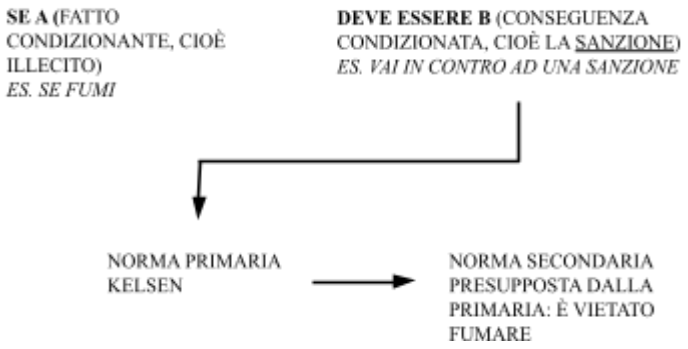
Neanche il concetto di "**seguire** una regola" è sostenibile, a causa del paradosso di Wittgenstein, per cui ogni modo d'agire può essere messo in concordanza con la regola stessa.

La teoria della costitutività non marginalizza la funzione prescrittiva del linguaggio giuridico; al contrario, riconosce la presenza contemporanea nell'ordinamento di due tipologie di norme:

1. **Norme prescrittive:** Esigono **atti di adempimento** (es. "La moglie è obbligata ad accompagnare il marito dovunque egli crede opportuno di fissare la sua residenza").
2. **Norme costitutive:** Non richiedono atti di adempimento (es. "Il marito è il capo della famiglia").

Risulta falsa la tesi di Kelsen che vede il diritto esclusivamente come un insieme di norme prescrittivo-sanzionatorie.

- Per Kelsen, le "norme primarie" imputano a un **fatto condizionante (l'illecito)** una **conseguenza condizionata (la sanzione)**.
- Lo schema kelseniano è: "Se A deve essere B", dove A è l'illecito e B è la sanzione. Questo schema incorpora chiaramente i due elementi tipici della prescrittività: l'obbligo di adempimento e la sanzione in caso di inadempimento.



Per la teoria della costitutività, lo schema kelseniano è **insufficiente**. Non tutte le norme sono prescrittive e non tutte sono munite di sanzione.

Le norme che si eseguono senza bisogno di adempimento (le costitutive) **non sono munite di sanzione**.

- Dove manca l'adempimento — poiché non è in gioco la condotta di un agente — è **illogico prevedere una sanzione**.

- La sanzione è la conseguenza giuridica di un comportamento illecito. Tuttavia, nelle norme costitutive, l'illecito non è neanche pensabile, dato che esse non attendono nulla che vada oltre la loro vigenza.

Esempio: Nel momento in cui vige la norma che stabilisce la maggiore età a diciotto anni, tutti i diciottenni **sono immediatamente maggiorenni**. Non hanno bisogno di distinguersi per particolari virtù o per un agire specifico, né ha senso parlare di illecito in relazione a questa condizione.

Tra le norme costitutive, spicca l'enunciato fondamentale in cui si traduce ogni singola norma del legislatore, sia essa costitutiva o prescrittiva: "**Si dispone che il sistema S contenga la determinazione D**".

- Come per Kelsen tutte le norme presuppongono la norma primaria (che lega l'illecito alla sanzione), similmente, per la teoria della costitutività, tutte le norme sottintendono il **primato della norma che dispone ciò che è valido o invalido per il sistema**.
- La conclusione è che **tutte le norme implicano almeno una norma costitutiva**.

La teoria della costitutività **non implica una riduzione** del carattere essenzialmente prescrittivo del diritto, per diverse ragioni.

La performatività del linguaggio giuridico (come nell'enunciazione "Si dispone che Op") non può né verificare né falsificare una teoria prescrittivista.

- Il verbo performativo "**disporre**" (che produce gli effetti costitutivi) si colloca su un **piano meta-discorsivo**rispetto all'enunciato innestato "Op" ("È obbligatorio p"), che è su un piano discorsivo.
- L'obbligo di p non si costituirebbe senza la *performance* del verbo, ma ciò non significa che l'enunciazione performativa condizioni il **senso** dell'enunciato innestato. Ha solo la forza di fissare la sua determinazione in modo costitutivo.
- Mediante il verbo performativo **viene al mondo qualcosa che prima non esisteva**, ma ciò che nasce è comunque un **obbligo** o una **prescrizione**. Anche se il verbo performativo crea uno *status* anziché un obbligo (es. "Si dispone che il marito sia il capo della famiglia"), la norma costitutiva (primaria) va a costituire un'altra norma costitutiva.

Il linguaggio giuridico è, quindi, sia costitutivo sia prescrittivo.

Quando si osserva l'**intero ordinamento** anziché le singole norme, è facile invertire il primato tra costitutività e prescrittività.

- L'ordinamento giuridico, visto nel suo insieme, appare principalmente come un **sistema di obblighi, divieti e permessi** (prescrizioni), e non solo come un mondo di regole isolate.
- Le norme costitutive servono a porre le **condizioni necessarie per la produzione di prescrizioni**. Ad esempio, l'Art. 70 della Costituzione ("La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere") è una norma costitutiva, ma è irrazionale pensare che non discendano da esso le tantissime norme prescrittive promulgate dalle Camere.
- Tale articolo è *prius* (precede nel tempo) rispetto alle prescrizioni, ma non *primum* (non è il primo nel *lógos* o nell'essenza).

Come nel Decalogo sinaitico, dopo la proclamazione della signoria di Jahvé ("*Ego sum Dominus Deus tuus*"), seguono immediatamente i comandi (*mandata*, *praecepta*, *iudicia*) che stabiliscono l'obbligo fondamentale per il popolo.

Inoltre, il **fervore e l'angoscia** di fronte al diritto (come nel *Processo* di Kafka) si spiegano solo se le leggi **pretendono qualcosa** dai destinatari, anziché rimanere inattive.

Non è scontato che le norme costitutive non abbiano anch'esse un senso prescrittivo, mettendo in discussione la distinzione basata sulla non-sanzionabilità.

L'assenza di sanzione per le norme costitutive è dovuta all'immediatezza della loro esecuzione (non essendoci adempimento, non c'è illecito). Lo schema kelseniano richiede la violazione di una prescrizione ("Se c'è l'illecito, ci dev'essere la sanzione").

- Una norma abrogativa (costitutiva) che sostituisce un divieto con un permesso determina un permesso. Tuttavia, un permesso **implica sempre il divieto di impedirne l'esercizio**.
- Se i destinatari si comportassero come se la norma non fosse abrogata (cioè, impedissero ciò che ora è permesso), sorgerebbe un **illecito sanzionabile**.
- Di conseguenza, una norma costitutiva, come una abrogativa, è **traducibile** nello schema che imputa a un fatto illecito la sanzione, collegando così la costitutività alla prescrittività, seppure in modo indiretto.

Nell'insieme delle conseguenze giuridiche esistono anche **sanzioni privative** (non solo punitive, come la detenzione).

- La **nullità degli atti** è una sanzione privativa: non manda il soggetto in prigione, ma limita la sua libertà privandolo della capacità di compiere validamente l'atto.
- Nelle norme di *status* (costitutive che fissano capacità come la maggiore età), la sanzione è la **privazione di un atto**. Se un soggetto ignora la condizione d'età prevista per un giuramento, l'atto è **nullo**. Questo rappresenta la privazione di una capacità o potere e rileva un **effetto prescrittivo** delle norme costitutive.

Le norme costitutive, anche se non sono prescrittive in senso primario, lo sono almeno **secondariamente**.

- **Esempio delle regole del gioco:** La regola costitutiva che definisce il "re" negli scacchi e le sue mosse **non stabilisce le singole mosse** del giocatore (non è prescrizione primaria), ma **delimita l'ambito massimo di possibilità** di movimento (la totalità dei *praxemi*). In tal modo, detta **indirettamente** cosa si deve e non si deve fare, acquisendo un ulteriore carattere di prescrittività.

Le tesi costitutiviste che postulano una norma costitutiva alla base di tutte le norme ("Si dispone che il sistema S contenga la determinazione D") non sono immuni da **eccezioni**.

- Sarebbe illogico l'enunciato "Si dispone che Op" se Op rappresentasse la **Grundnorm** di Kelsen (la norma fondamentale) o il dovere di comportarsi secondo la Costituzione effettivamente statuita ed efficace.

- Per un dovere implicito alla Costituzione, sono impensabili un atto di volontà o la sola forza costitutiva delle norme. Prevale, in questo caso, un **atto di ragione**.
- Osservando l'intero ordinamento da una prospettiva più alta, si scopre che esistono **doveri e prescrizioni che non possono originare dalla costitutività del potere**, ma che hanno origine nel **concetto di diritto** prima di ogni atto di disposizione.
- Ad esempio, è teoreticamente imbarazzante dichiarare: "Si dispone che l'Altro sia pari all'Io". L'**uguaglianza dell'Altro all'Io** (nella capacità di pretendere secondo una verità comune) è una regola fondamentale di riconoscimento (*Anerkennung*) che è **ben al di là di ogni atto di disposizione**. Il contrario implicherebbe la cessazione del diritto.

In conclusione, non tutto dipende dalla "forza costitutiva delle norme"; i principi fondamentali dell'ordinamento sono indipendenti da essa, eppure si traducono in obblighi, divieti e permessi.

Diritto e logica

Come non può esistere una scienza dei *principia mathematica* senza una logica della verità, allo stesso modo non può esserci conoscenza del dovere giuridico senza regole di **validità**.

Sorge la domanda se la verità possa sostituire la validità, ovvero se abbia senso predicare la **verità o la falsità** delle norme giuridiche. Sembra che la risposta sia negativa: delle norme si predica la **validità o invalidità**, ovvero la loro appartenenza o meno a un ordinamento, e non la verità o la falsità.

L'obiettivo di questa analisi non è metafisico, a differenza delle riflessioni sul valore della "verità pura e spregiudicata" nel diritto (come quelle di Friedrich C. von Savigny), ma è mirato a spiegare la **sintassi del linguaggio giuridico**.

La risposta a questa domanda deve necessariamente considerare la **performatività del linguaggio**. Sotto il profilo linguistico, le norme si presentano in due forme:

1. **Enunciati di enunciazioni performative**.
2. **Enunciati innestati in enunciazioni performative**.

Si consideri lo schema fondamentale che riproduce una norma giuridica: "**Si dispone che è obbligatorio p**".

- Questo schema contiene una **norma costitutiva** ("Si dispone che Op", dove Op sta per "È obbligatorio p").
- Contiene anche una **norma prescrittiva** (l'enunciato innestato "È obbligatorio p").

A questo punto, sorgono due questioni fondamentali:

1. Ha senso predicare la verità dell'enunciato che traduce un'enunciazione performativa, cioè: **È "Si dispone che Op" vero o falso?**
2. Ha senso parlare di verità dell'enunciato innestato in un'enunciazione performativa, cioè: **È "È obbligatorio p" vero o falso?**

La stessa questione sulla predicabilità della verità si ripete per il **discorso ordinario** (non necessariamente giuridico), che include affermazioni come "Ti prometto di venire alla tua festa", "Giuro che non mi vedrai più", "Buona notte", o saluti affettuosi in dialetto.

Si analizza la possibilità di predicare la verità degli enunciati che compongono le norme, riprendendo una tesi di **Amedeo G. Conte** esposta in *Aspetti della semantica del linguaggio deontico* (1977).

La tesi centrale di Conte è che la verità può essere predicata sia degli **enunciati che traducono un'enunciazione performativa** ("Si dispone che Op"), sia degli **enunciati innestati in enunciazioni performative** ("È obbligatorio p").

In sostanza, Conte sostiene che **anche delle norme è predicabile la verità**.

A seguire, saranno presentati gli argomenti di Conte a supporto di questa tesi e, successivamente, saranno esposti i dubbi e le riserve in merito.

Il discorso performativo mostra un isomorfismo (una corrispondenza di forma) con il discorso vero o falso (il discorso aristotelicamente **apofantico**).

In particolare, degli enunciati che traducono enunciazioni performative (come "Si dispone che Op"), non solo è possibile predicare la verità, ma risulta anche **impensabile la falsità**. Questi enunciati sono sempre veri in virtù della loro **"autoreferenzialità"** (*sui-référence, self-reference, Selbstbezug*).

- **Auto-Verificazione:** Nel momento in cui si enuncia "Si dispone che Op", viene immediatamente creata una disposizione che prima non esisteva. L'enunciato corrispondente si riferisce a sé stesso e si **autoverifica** (o si fa vero) a partire proprio da ciò che esprime. L'atto di decretare "Si dispone che Op" coincide con l'atto di disporre di Op.

Per questa ragione, gli enunciati performativi sono sempre veri. Al posto di performativi falsi, si trovano al limite dei **falsi performativi**.

Un falso performativo si verifica quando non vengono soddisfatte le **condizioni essenziali** per la riuscita dell'atto (le *felicity conditions*).

- **Esempio 1 (Battesimo):** Se un sacerdote pronuncia la formula rituale "Io ti battezzo...", ma non esegue l'azione cruciale di segnare il bambino con l'acqua benedetta, non soddisfa una condizione essenziale. In questo caso, l'enunciato "Io ti battezzo" non "fa ciò che dice", e non si è in presenza di un enunciato performativo falso, ma di un **falso performativo**.
- **Esempio 2 (Investitura):** Analogamente, se la formula d'investitura di un vassallo non è preceduta dalle necessarie cerimonie rituali (come il digiuno, la confessione e la "veglia delle armi"), si ha un falso performativo.

In conclusione, la *performance* di un enunciato riesce solo in presenza di determinate condizioni; in assenza di esse, non si può parlare di linguaggio performativo in senso proprio. Dunque, o l'enunciato performativo **riesce ed è necessariamente vero**, o **non si è in presenza di un enunciato performativo**.

Si pone la questione se sia possibile predicare la verità dell'enunciato normativo "**È obbligatorio p**", che è innestato nell'enunciazione performativa del legislatore ("Si dispone che è obbligatorio p").

La risposta a questa domanda è coerente con la distinzione precedentemente introdotta tra **θεσις (*thésis*)** e **ρησις (*rhesis*)**.

Le enunciazioni del legislatore sono **enunciazioni performative thetiche**.

- Grazie all'enunciazione "Si dispone che Op", il legislatore **costituisce un obbligo che prima non esisteva**: l'obbligo di p.
- L'obbligo di p è anche il tema dell'enunciato innestato "È obbligatorio p".
- Il **nesso necessario** tra la costituzione dell'obbligo e l'enunciazione performativa "Si dispone che Op" ha un duplice effetto:
    1. Pone in essere l'obbligo di p.
    2. Pone in essere la **verità dell'enunciato** "È obbligatorio p".
- Quest'ultimo enunciato (la prescrizione) descrive uno stato di cose che **risale alla stessa enunciazione** del legislatore.

- Infatti, ogni volta che il legislatore decreta "Si dispone che Op", **nasce l'obbligo di p**. In tal senso, l'enunciato innestato "È obbligatorio p" si **autoverifica** (diventa vero per il fatto di essere stato disposto).

La stessa cosa **non succede** con le enunciazioni performative rhetiche, che sono tipiche del giurista studioso.

- Quando il giurista fornisce notizie di obblighi o divieti vigenti, le sue affermazioni possono essere **eventualmente false**.
- Dicendo "Affermo che Op", non per questo nasce l'obbligo di p.
- In questo caso, l'enunciato innestato "È obbligatorio p," che è inserito nell'enunciazione performativa del giurista (il cui scopo è semplicemente descrivere l'ordinamento), **può essere falso** se l'obbligo non è effettivamente presente.

Vengono avanzate tre osservazioni alla tesi di Amedeo G. Conte

La tesi di Conte sostiene che gli enunciati performativi sono veri in quanto **si autoverificano**. Ciò accade perché non sono un semplice "dire su un fare", ma sono essi stessi **il fatto che descrivono** (un atto di disposizione del legislatore o un determinato *status deontico* come l'obbligo di p). Questi fatti esistono solo grazie all'enunciazione performativa che li pone.

Tuttavia, dei fatti (o delle *res*) in generale non si dice che sono veri o falsi, ma che **esistono oppure no**. Se se ne predica la verità, lo si fa in un'accezione specifica, diversa da quella semantica.

Si distinguono due concetti fondamentali di verità:

1. Verità Semantica (*Verum de dicto*)

- **Definizione:** Riguarda la relazione tra una **proposizione** (*dictum*) e lo **stato di cose** che essa descrive. È il predicato di un'entità linguistica (*semeion*).
- **Corrispondenza:** È l'**adeguazione** (*adaequatio*) tra il giudizio (intelletto) e il fatto (mondo o *res*). Se c'è corrispondenza, la proposizione è **vera**; altrimenti è **falsa**.
- **Esempio:** La proposizione "Il bosone di Higgs è stato osservato nel 2012" è vera perché corrisponde al fatto accaduto al CERN. Affermare che "il bosone di Higgs sia Dio stesso" è probabilmente falso in senso semantico.
- **Biunivocità:** La verità è vista come *adaequatio rei et intellectus* (San Tommaso): è una relazione biunivoca in cui non solo l'intelletto va verso il mondo, ma anche la realtà si dirige verso l'intelletto.

2. Verità Ontica (*Verum de re*)

- **Definizione:** Riguarda l'**esistenza** di un **fatto o di un oggetto** (*res*), non di una proposizione. È il predicato di un fatto, non di un giudizio logico.
- **Esistenza:** Il senso ontico di verità indica l'esistenza. Un "dente falso" o una "banconota falsa" sono concettualmente un non-oggetto o una non-banconota. "Falso" è equivalente a non-esistente, "vero" a esistente. Una "vera rivoluzione" è una rivoluzione riuscita.

Il diritto utilizza ampiamente questi concetti per l'individuazione di alcune fattispecie di reato (es. documenti con valore probatorio):

- **Falso Ideologico (Verità Semantica):** Il documento è genuino nella sua formazione (onticamente vero), ma **mendace nel contenuto**. La verità viziata è quella semantica, cioè la **corrispondenza tra la dichiarazione del documento e la realtà** che si intende provare.
- **Falso Materiale (Verità Ontica):** Il contenuto del documento corrisponde alla realtà, ma è **alterato rispetto alla sua provenienza**. La verità viziata è quella ontica, poiché il documento **non è originale o attendibile** (non è stato emesso dal reale prestatore d'opera, ma da un terzo).

La verità ontica e la verità semantica sono predicati non solo diversi, ma anche **irrelati** tra loro, salvo circostanze specifiche.

- **Esempio dell'Apparizione:** L'apparizione della Madonna a La Salette potrebbe essere onticamente falsa (non è mai avvenuta), ma ciò non toglie nulla all'eventuale verità semantica del giudizio "L'umanità nel 1846 era alla vigilia di tante rivoluzioni" (fatto confermato dalle rivoluzioni del 1848).
- **Esempio della Banconota (Entità Semiotica):** Si consideri una banconota americana con due enunciati stampati.
    - Per l'enunciato "In God we trust" (riferimento esterno), la falsità ontica della banconota **non è sufficiente a falsificare** la verità semantica dell'enunciato.
    - Per l'enunciato "This note is legal tender for all debts..." (riferimento alla banconota stessa), la falsità ontica della banconota **è sufficiente a falsificare** la verità semantica dell'enunciato.

Queste sono le **uniche circostanze** in cui la verità/falsità ontica è relata a quella semantica: quando l'enunciato si riferisce all'entità su cui ricorre ("*this note*") e ne predica l'esistenza in qualità di "mezzo legale di pagamento".

La questione della predicabilità del vero negli enunciati performativi si gioca sulla differenza tra le due verità.

- Gli enunciati deontici in *suppositione deontica* ("Si dispone che Op" e "È obbligatorio p") non sono un linguaggio su stati di cose (come dire "Vi vedo dormire a lezione"), ma sono essi stessi **un fatto, una *res*** (un atto di disposizione o uno *status deontico*). Essi **costituiscono il mondo**, anziché descriverlo.
- Non si può predicare la verità in senso logico o semantico, poiché manca la corrispondenza (*adaequatio*) tra proposizione e stato di cose.
- Ciò che si deve verificare sono solo dei **fatti**: se esistono oppure no (come per la verità della banconota).
- Perciò, una norma vera ha un senso **esclusivamente ontico**. Significa che **esiste validamente in un ordinamento**. La sua validità è la sua "esistenza specifica" (*spezifische Existenz*) all'interno e per l'ordinamento stesso.

Si solleva un ulteriore dubbio riguardo l'uso del predicato di verità quando tale verità è assoluta e priva di un possibile contraltare, come nel caso degli enunciati performativi.

- Si afferma che predicare la verità di un giudizio ha senso solo se è in gioco anche la possibilità della **falsità** (come accade per la proposizione "Fuori piove," che può essere vera o falsa).

- Se un enunciato non può che essere vero, come si verifica per gli enunciati performativi, l'uso del predicato di verità appare **anomalo**.
- Il vero e il falso sono interdipendenti, come i ballerini Fred Astaire e Ginger Rogers: l'uno non è pensabile senza l'altra.

Gli enunciati performativi si distinguono da quegli enunciati che sono **senz'altro veri**, come la proposizione "Ogni corpo è esteso".

- **Enunciato Necessariamente Vero:** "Ogni corpo è esteso" è necessariamente vero (non può essere falso) perché il predicato (l'estensione) riprende sostanzialmente l'idea già contenuta nel soggetto (il corpo). È un enunciato tautologico, come dire "A=A".
- **Funzione Descrittiva:** Nonostante ciò, la verità di "Ogni corpo è esteso" è legittimata dalla sua **funzione descrittiva**, poiché si mantiene la possibilità di indagare il rapporto di adeguazione (*adaequatio*) tra la proposizione e lo stato di cose che descrive (la natura di *res extensa* della realtà sensibile).

Con gli **enunciati performativi**, la situazione è diversa:

- Appartengono al tipo di enunciati di cui **non è neppure predicabile la falsità**, non perché siano tautologici o auto-evidenti, ma perché la loro funzione è **costituire il mondo, non descriverlo**.
- Sono un **fatto** (un'azione in sé) e non una **proposizione su un fatto**.
- Di conseguenza, la loro verità non è di tipo semantico, ma è la loro **stessa esistenza** (verità ontica).

Viene avanzata un'ultima osservazione: anche ammettendo la predicabilità della verità in senso logico o semantico, essa risulta **irrilevante** nel contesto del diritto pratico, in particolare nel sillogismo giudiziale.

Si considera lo schema del sillogismo giudiziale:

1. **Premessa Maggiore:** Tutti i ladri devono essere puniti.
2. **Premessa Minore:** Tizio è un ladro.
3. **Conclusione:** Tizio deve essere punito.

Contrasto con il Sillogismo Aristotelico

- **Se la verità fosse rilevante** (come nel sillogismo aristotelico), la conclusione "Tizio deve essere punito" sarebbe l'unica possibile.
- Nel sillogismo classico ("Tutti gli uomini sono mortali; Socrate è un uomo; quindi Socrate è mortale"), una conclusione negativa ("Socrate non è mortale") è **inconsistente** e logicamente assurda. La verità della conclusione è necessaria e indubitabile, tanto da far dubitare delle capacità logiche di chi la nega.

L'Autonomia Logica del Processo Giuridico

- **Nel processo giudiziale,** pur restando ferme le premesse ("Tutti i ladri devono essere puniti" e "Tizio è un ladro"), **nulla vieta che il giudice sentenzi in favore di Tizio, assolvendolo.**

- L'assoluzione sarebbe comunque **valida**, e il tribunale, pur emettendo una sentenza discutibile, non diventerebbe per questo "meno competente".

La **verità è un predicato irrilevante nel processo**, a meno che non sia intesa in senso **ontico** (esistenza/validità).

- In questo senso ontico, la conclusione "Tizio non deve essere punito" (la sentenza di assoluzione) è **vera** (nel senso di esistente e valido) e non è contraddittoria.
- Ciò accade perché la sentenza non deriva dalla verità logica delle due premesse, ma dalle **condizioni di validità**della sentenza stessa.
- Al processo non è richiesta l'immediata coerenza del discorso giudiziale.

Questo risultato permette di sostenere l'**autonomia logica del discorso giuridico** rispetto alla logica della verità, e porta alla discussione e confutazione di due tesi contrarie a tale asserto.

La prima tesi sostiene che la **grammatica** di un enunciato e la sua **funzione pragmatica** (il modo in cui viene usato) sono indipendenti tra loro.

- **Proposizione Multiuso:** La stessa proposizione può essere utilizzata in modi molto diversi senza che la sua forma grammaticale cambi. Ad esempio, la proposizione "**Tutti i ladri sono puniti**" può servire come:
    - Un'ipotesi statistica (su quanti ladri vengono effettivamente puniti).
    - Un'asserzione sulle conseguenze del furto (al furto segue una punizione).
    - Un **comando** (che prescrive di punire i ladri).
- In tutti questi casi, anche se l'atto varia radicalmente (da una mera ipotesi a un comando), la grammatica del discorso rimane invariata, utilizzando il verbo all'**indicativo presente**.

Secondo questa tesi, le norme sono, dal punto di vista grammaticale, **proposizioni indipendenti** dalle dimensioni performative del loro linguaggio.

- Si consideri l'enunciato "**È vietato fumare**". La sua grammatica è identica sia che esso sia una **norma** (*Soll-Norm*) — l'articolo del codice che vieta l'azione — sia che sia un **discorso su una norma** (*Soll-Satz*) — l'asserzione del giurista che informa dell'esistenza di tale divieto nel codice.

L'argomento centrale è che **la logica adopera regole di trasformazione delle proposizioni indipendentemente dalla loro funzione pragmatica**.

- Le relazioni logiche del discorso si basano sulla **grammatica** delle proposizioni e non sui termini pragmatici (l'uso, l'intenzione).
- Non ci sarebbe, dunque, motivo di trattare le norme in modo diverso dal resto del discorso cognitivo, che utilizza il verbo all'indicativo presente.

Di conseguenza, l'enunciato "Tutti i ladri **devono** essere puniti" si trasformerebbe in "Tutti i ladri **sono** puniti".

- Questa trasformazione permetterebbe di applicare la **logica dei giudizi veri o falsi** del sillogismo aristotelico al diritto.

- Il sillogismo giudiziale diventerebbe: "Tutti i ladri **sono** puniti", "Tizio è un ladro", dunque "Tizio **è** punito".

La seconda tesi, sostenuta dal filosofo del linguaggio normativo **Georges Kalinowski**, afferma l'esistenza di **status deontici precostituiti** all'enunciazione degli enunciati deontici da parte del legislatore.

- **Definizione di Enunciati Deontici:** Per Kalinowski, gli "enunciati deontici" sono le **norme** stesse (*normes, normes-énoncés, normes-propositions, propositions normatives*). Questi non devono essere confusi con i *Rechtssätze* (enunciati descrittivi di stati di cose) di Kelsen, né con i *normative statements* (anch'essi apofantici) di Georg H. von Wright.

Nelle sue opere (*Introduction à la logique juridique* e *Le problème de la vérité en morale et en droit*), Kalinowski fa coincidere la **validità delle norme** con la **corrispondenza tra gli enunciati normativi e la "réalité déontique"**.

- Questa "realtà deontica" è composta da **status deontici che non sono costituiti (creati) dal legislatore, ma sono precostituiti** (esistono prima) rispetto all'enunciazione delle norme.
- Da questo punto di vista, la validità di una norma è, in realtà, la sua **verità in senso logico**.
- Una norma valida è considerata un enunciato che **descrive uno status deontico già esistente**.

Secondo questa logica, se la posizione semantica che definisce una proposizione vera è "la proposizione 'p' è vera, se e solamente se p," non ci sarebbero difficoltà ad applicare la stessa formula alle norme giuridiche.

- **Esempio:** L'asserzione che la norma "**Non si devono commettere omicidi**" è vera, se e solo se sussiste realmente il **divieto di uccidere**, risulta logicamente irreprensibile.

Le due tesi critiche precedentemente esposte (l'indipendenza tra grammatica e pragmatica, e la precostituzione degli *status deontici*) condividono un tratto problematico: **astrazione del carattere normativo delle norme**.

Queste tesi falliscono perché:

1. **Riduzione:** Riducono la possibilità del calcolo logico alla sola parte non normativa degli enunciati, ignorando la funzione pragmatica delle proposizioni normative.
2. **Descrizione:** Inducono a considerare le norme come termini di un discorso meramente descrittivo del mondo.

Il discorso cognitivo si distingue da quello normativo proprio sotto l'aspetto **pragmatico**.

- **Differenza di Fatti:** Una norma è un fatto **diverso** da una semplice ipotesi statistica. Nel primo caso, si ha la **costituzione di uno stato di cose** (un obbligo); nel secondo, la **semplice descrizione** di uno stato di cose.
- **Non-Intercambiabilità:** Trattare i due tipi di discorso allo stesso modo è come cadere nell'"**oscurità hegeliana** in cui tutti i gatti appaiono grigi". Il legislatore che decreta un obbligo non è equivalente al sociologo che calcola quanti ladri finiscono in prigione.
- Una logica che è avulsa dalla funzione pragmatica del discorso risulta **sterile** e non è feconda se non tiene adeguatamente conto della differenza intrinseca nel linguaggio.

Una considerazione simile si applica alla seconda tesi (quella di Kalinowski sulla *réalité déontique* precostituita).

- **Linguaggio non Descrittivo:** Il linguaggio delle norme non è affatto descrittivo, e non è rappresentabile nella formula tarskiana di verità semantica ("La proposizione 'p' è vera se e solamente se p"). Non lo è neanche nei casi in cui la norma contiene doveri necessari (come il divieto di omicidio).
- **Senso Dichiarativo:** Il senso del linguaggio normativo è, al limite, "**dichiarativo**" (*deklarative Normsätze* di Theodor Geiger).

Consolidamento di Status Deontici Forti

- Anche quando si riconosce una **relazione necessaria tra mezzi e fini** (come nelle regole tecniche o nella *Natur der Sache*, che identificano uno *status deontico* in sé sussistente), è comunque **necessaria la norma** per rendere tale regola **valida in un ordinamento**.
- Le norme operano sempre una forma di **consolidamento** (*Verfestigung*) degli *status deontici*, anche se questi sono forti.
- **Esempio del Divieto di Uccidere:** L'esistenza dell'Art. 575 del Codice penale (che vieta l'omicidio) non è la stessa cosa della mera esistenza di un dovere morale.
- **Contro-Esempio della *Réalité Déontique*:** Non tutte le *réalité déontique* di Kalinowski sono in sé sussistenti. Ad esempio, i provvedimenti di contenimento della spesa pubblica ("tagli") non possono essere pensati indipendentemente da **interventi legislativi** inevitabili e dibattuti.

In conclusione, la logica deve considerare la funzione pragmatica e **costitutiva** del linguaggio giuridico, poiché le norme non si limitano a descrivere una realtà deontica preesistente, ma sono atti che la pongono in essere e la rendono valida nell'ordinamento.

La logica del linguaggio giuridico **non è la logica della verità**, almeno non nel senso semantico del termine. A determinare la vita e l'esistenza del dovere giuridico è piuttosto la **validità**.

Di conseguenza, la scienza del dovere giuridico coincide con lo studio delle **condizioni di validità** di due oggetti primari della costruzione giuridica:

1. **Gli Atti (*speech acts*):** La loro esistenza sarà analizzata attraverso la **validità pragmatica**.
2. **Le Norme:** Il loro studio sarà affrontato attraverso la **validità sintattica**.

Doveri pragmatici

Il diritto viene concepito come ***práxis***, ovvero un **movimento sconfinato di atti** che sono essenzialmente **atti linguistici** (*speech acts*). Gran parte dell'attività giuridica è costituita da azioni che il soggetto compie **"con parole"**, come decretare, sentenziare, fare testamento, acquistare, vendere, promettere e giurare.

La **pragmatica**, intesa come scienza, ha il compito di studiare le **condizioni di validità** di questi atti.

Questa validità pragmatica si articola in due concetti distinti:

1. **Validità pragmatica prima o praxeologica:**
    - Le sue condizioni risalgono all'**idea** [**ειδος** (*eidos*)] **stessa dell'atto** a cui si riferisce la validità.
    - Il concetto di "idea" qui utilizzato non è inteso in un senso qualsiasi, né si riferisce alle intenzioni particolari dell'individuo.
    - Al contrario, questa "idea" non è espressione di piccole controversie (come un dibattito politico su un programma elettorale o la discussione tra tifosi su uno schieramento), ma **tocca l'essenza delle cose**, costituendo l'oggetto di un **pensiero universale**.
2. **Validità pragmatica seconda o praxeonomica:**
    - Questa validità si colloca su un piano molto differente.
    - Le sue condizioni risalgono a **norme** [**νο΄μοι** (*nómoi*)] che sono ***ab extra*** (esterne) rispetto alla pura idea dell'atto[11].

La **validità pragmatica prima o praxeologica** è definita come quella che non dipende da mere norme, ma è radicata nell'**idea** [ειδος (*eidos*)] **stessa dell'atto**. Essa esprime **doveri necessari e universali**, la cui assenza comporterebbe l'impossibilità dell'atto o la sua trasformazione in una realtà differente. Tali doveri sono assimilabili alle **condizioni *a priori* di validità** nel senso kantiano, in quanto non originano dall'esperienza empirica dei fatti sociali, ma dal loro concetto originario.

Un esempio chiaro è la condizione per cui una **promessa non può avere ad oggetto una cosa passata**. Senza questo dovere, l'atto della promessa risulterebbe privo di senso e dunque impossibile. Al centro di questo requisito si trova l'**idea di promessa**—non un'opinione individuale e parziale, ma l'**essenza** o *quidditas* di ciò che universalmente si intende quando si parla di promettere.

L'idea della promessa, come sostenuto da John R. Searle e Jean-Louis Gardies, consiste essenzialmente nell'**assunzione di un'obbligazione** (*"The essential feature of a promise is the undertaking of an obligation"*). È concettualmente impossibile concepire il promettere senza un'obbligazione verso il promissario. Ne consegue immediatamente che non è possibile obbligarsi per una cosa già accaduta (passata o presente), ma ci si può obbligare solo per ciò che **deve ancora essere**. Affermazioni come "Prometto che ti sono stato fedele" o "Prometto di averti portato..." implicano un chiaro controsenso, al pari dell'espressione "Il mio amico morì dopodomani."

[11] Due definizioni di Conte: La validità praxeologica di un atto è quella specie di validità pragmatica che è relativa al concetto di quell'atto (...) L'altra delle due specie di validità pragmatica è la validità praxeonomica. Valigia praxeonomica è quella specie di validità pragmatica che è relativa non già alla struttura intrinseca dell'atto, ma a regola, a nomoi, ad estrinseche regole su esso e precisamente a regola le quali theticamente pongono, nei differenti ordinamenti normativi, differenziali condizioni di validità

Sotto l'apparenza di una promessa rivolta al passato, sono possibili al massimo delle **rassicurazioni**. Ad esempio, dichiarare "Prometto di aver fatto tutto il possibile" è in realtà un'espressione di rassicurazione che nulla sia stato omesso, e non costituisce una promessa effettiva. In definitiva, una promessa avente a oggetto una cosa passata sfocia nell'**impossibilità** dell'atto stesso o nella sua **trasformazione** in un atto totalmente diverso, come la rassicurazione.

Una promessa di cosa passata è un **paradosso pragmatico**, così come lo è la **promessa d'inadempimento** della promessa medesima ("Prometto di non mantenere la presente promessa"). Una promessa è infatti per sua natura un modo rigoroso di obbligarsi e, quindi, è sempre una promessa di adempimento.

Molti fenomeni giuridici riflettono la validità praxeologica. Tra questi vi è il vincolo, del tutto astratto, per cui oggetto di **abrogazione** deve essere sempre e solo una **norma valida** e mai una norma invalida; abrogare un atto invalido non è qualificabile come "abrogazione". Anche Adolf Reinach, in *I fondamenti a priori del diritto civile*, è in linea con la praxeologia quando osserva che una pretesa a una prestazione si estingue nel momento in cui tale prestazione è **compiuta**. In questo caso, si tratta di una condizione *a priori* non per l'esistenza dell'atto, ma per la sua **cessazione**.

Similmente, la critica mossa da Sergio Cotta alla tesi di Kelsen sulla validità degli effetti retroattivi della legislazione[12] si basa su premesse analitiche identiche. Poiché per Kelsen la norma è il "senso di un atto di volontà," non si può logicamente **volere un fatto passato**. Il volere, come il promettere, si rivolge esclusivamente al futuro, mentre una norma retroattiva è un'obbligazione diretta al passato. Infine, gli "**essentialia negotii**" descritti da Emilio Betti nella sua *Teoria generale del negozio giuridico* sono anch'essi espressione della praxeologia. Sono definiti come le **cause essenziali e gli elementi necessari** affinché un negozio di un certo tipo possa sussistere (ad esempio, le parti, il consenso, l'oggetto e il prezzo nella compravendita); la loro assenza impedisce l'esistenza del negozio stesso. Questo concetto era già presente nella dottrina del *ius commune* con i *substantialia contractus*, condizioni "sostanziali" necessarie per la nascita e la vita dei contratti in genere (*"Ea dicuntur substantialia, sine quibus contractus non potest in esse deduci..."*).

Eludere la praxeologia degli atti comporta l'insorgere di **paradossi e autentici controsensi del linguaggio**, che portano fino all'**inesistenza degli atti corrispondenti**. Questo principio non è limitato al campo giuridico, ma si manifesta in tutta la pragmatica della comunicazione, spesso in modo inconsapevole. Esempi comuni sono l'ordine "Voglio che tu mi domini!" (che costringe alla sottomissione per eseguire il comando di dominio) o l'esortazione "Non essere così obbediente!" (che il figlio, per obbedire, deve disobbedire).

---

[12] Cotta: Cotta riconosce che **Hans Kelsen** (soprattutto in *Dottrina pura del diritto* e *Teoria generale delle norme*) ammette la validità delle **norme retroattive**. Tuttavia, Cotta individua un **paralogismo** (errore logico) nella teoria kelseniana, basato sulla definizione di norma:

1. **Premessa di Kelsen:** La norma è il **"senso di un atto di volontà"**.
2. **Obiezione di Cotta:** L'atto di volontà è un evento legato al presente (*nunc temporis*) che può proiettarsi nel futuro (es. atto del legislatore o promessa), ma **non può riguardare il passato**.
3. **Conclusione:** Poiché nel passato non si è verificato l'atto di volontà che dovrebbe darle significato, una norma retroattiva **non ha nulla di cui essere il senso** e risulta quindi una **"norma insensata"**.

In sintesi, Cotta accusa Kelsen di contraddizione: se la norma richiede un atto di volontà presente, essa non può validamente estendere il suo senso a un passato privo di tale atto.

L'aneddoto del Piccolo Principe e del re che attende "che le condizioni siano favorevoli" prima di ordinare il tramonto illustra la necessità di attendere le condizioni adatte. Alcune di esse sono persino cause di un **incondizionato** che non ammette eccezioni. Tutto ciò si discosta nettamente dall'idea di sovranità, intesa come *politische Theologie* del potere, che presuma di poter decidere autonomamente con il nulla alle spalle.

La **validità pragmatica prima o praxeologica** racchiude in sé condizioni che, pur avendo la stessa natura (ossia, essere **condizioni necessarie e universali**), non appartengono alla medesima specie. Esistono almeno due tipologie di tali condizioni:

1. **Condizioni che risalgono alla struttura essenziale degli atti.**
2. **Condizioni che risalgono alla loro funzione essenziale.**

Struttura e funzione non sono termini equivalenti, e di conseguenza, le condizioni che ne derivano non sono della stessa specie.

Si può documentare questa differenza prendendo ad esempio la **promessa**:

- **Condizione legata alla Struttura:** È una condizione praxeologica di validità che le promesse debbano riguardare sempre **cose future e mai passate**.
- **Condizione legata alla Funzione:** È un'altra condizione prima di validità pragmatica che le promesse siano **veritiere**. Se le promesse fossero sistematicamente menzognere, l'atto stesso del promettere non sarebbe più possibile.

Queste regole, pur avendo la medesima natura poiché entrambe derivano dall'**idea di promessa** (ει~δος), producono risultati sensibilmente diversi:

- Il primo dovere (promessa sul futuro) non sembra esprimere il senso di un imperativo morale. Ad esempio, non si annovererebbe nel Decalogo morale il comando: "Agisci in modo che le tue promesse siano sempre di cosa futura e non di cosa passata".
- Il secondo dovere (promessa veritiera), al contrario, è quello che Kant utilizza per esemplificare la rilevanza dell'**imperativo categorico** nella vita morale del soggetto (il dovere di mantenere le promesse).

La questione successiva riguarda il **rapporto** tra questi due tipi di doveri e la **struttura** e la **funzione** di un atto.

Prima di rispondere, è necessario stabilire la differenza tra struttura e funzione e porsi le seguenti domande:

- Esiste una differenza tra struttura e funzione?
- La funzione è un elemento essenziale?
- Esistono funzioni essenziali?
- In caso affermativo, come è possibile conoscerle?

La differenza tra **struttura** e **funzione** viene dimostrata attraverso la logica dei segni e dei significati. In questa prospettiva, il **segno** corrisponde alla **struttura**, mentre il **significato** (o l'uso) corrisponde alla **funzione** di un'entità linguistica.

Molte delle idee a supporto di questa distinzione sono riscontrabili nelle *Ricerche filosofiche* di Wittgenstein.

Se il segno e il significato fossero identici, non vi sarebbe alcuna variazione tra di essi:

- Ogni volta che si presentasse un segno, ci sarebbe sempre e solo lo stesso significato.
- Uno stesso significato non potrebbe essere espresso se non da un unico segno.

Uno stesso **uso o significato** può invece essere veicolato da **segni differenti**.

Si considerino due segni distinti, **'x'** e **'y'**:

- Una doppia 'x' (xx) indica un'affermazione ("sì," o negazione della negazione: "no di no!").
- Una doppia 'y' (yy) indica una negazione rafforzata ("no" forte, o negazione incalzante: "no, no!").

Quando i due segni non sono ripetuti (singola 'x' o singola 'y'), entrambi veicolano il significato di una negazione semplice ("no").

Questo mostra che **segni diversi possono avere lo stesso significato**; ovvero, si può avere la **stessa funzione** veicolata da **strutture diverse**.

Al contrario, un **segno identico** può assumere **significati differenti**.

Si prenda il segno **'è'**:

1. Nell'enunciato "La rosa è rossa", l' 'è' ha un certo significato (predicazione).
2. Nell'enunciato "Due volte due è quattro", l' 'è' ha un significato molto diverso, in quanto può essere sostituito dal segno di uguaglianza (=). Non avrebbe senso, infatti, dire "La rosa uguale rossa".

Questo esempio dimostra che lo **stesso segno può avere significati diversi**, configurando una **struttura** che può svolgere **due funzioni** distinte.

Nonostante la distinzione precedentemente stabilita, non ne consegue che non esista una **relazione tra struttura e funzione**, né che certe funzioni non richiedano specifiche strutture.

Per chiarire questo legame:

- Sarebbe illogico, ad esempio, pensare di assegnare la funzione senatoriale a un cavallo (richiamo all'insania di Caligola).
- Non avrebbe senso affermare: "Questo pezzo di twill è il mio smoking alla prima della Scala." L'abito formale richiesto per quella funzione sociale è un oggetto **molto più strutturato** di un semplice insieme di pezzi di stoffa disposti casualmente.
- Allo stesso modo, è incomprensibile dire: "Questo tronco di rovere è la mia collezione di sedie in Jugendstil," poiché manca delle eleganti forme geometriche e rettilinee proprie del *Wiener Werkstätte*.

Nel campo del linguaggio, anche un'espressione che non rispetta le regole minime non è completamente priva di effetti, sebbene questi effetti siano diversi da quelli attesi. Ad esempio,

proferire l'espressione **"Lattemi zucchero!"** in una caffetteria causerà stupore nella cameriera. Tuttavia, nessuno interpretrerebbe tale espressione come l'ordine di fissare qualcuno.

Si intuisce che un **ordine** è qualcosa di diverso, e questo si desume dalla sua **grammatica**. L'espressione "Lattemi zucchero!" non possiede la grammatica necessaria per essere classificata come un ordine (e, specificamente, non è l'ordine di fissare qualcuno).

In conclusione, analizzando le cose in questo modo, il segno non è, come sosteneva Hegel, una "piramide" che contiene e preserva un'anima estranea.

Il senso o l'insensatezza di una proposizione dipende dalla sua **funzione o uso**. Una proposizione è definita non solo dalle sue regole di formazione (grammatica), ma anche dall'uso dei segni al suo interno. Sono gli usi a definire i segni, e non viceversa.

La Funzione nel Linguaggio e nei Giochi

- **Esempio degli scacchi:** Comprendere l'espressione "**dare scacco**" significa conoscerne l'uso all'interno del gioco degli scacchi. Senza il riferimento al ruolo del re, l'espressione sarebbe insensata, così come lo sarebbe se riferita a un pedone quando il giocatore non ne ha più.
- **Esempio di comprensione:** Afferrare il significato di "**seppia**" in una frase come "Questo si chiama 'seppia'" richiede la comprensione del suo uso come nome di un colore.
- **Esempio dell'implicito:** La scritta "Il cane sta dietro la porta" sull'uscio di casa di un amico, seguita da "So che hai paura dei cani," acquista il suo senso completo (funzione) di **minaccia implicita** ("Non azzardarti a venire a casa") solo comprendendo lo **scopo** di un simile cartello. Il significato si colloca "tra le due righe."

L'essenzialità della funzione emerge anche dalla **coscienza del tempo**.

Quando si ascolta una melodia, si percepiscono i singoli suoni, ma si ascolta, in primo luogo, l'intera **melodia**. I singoli suoni esistono in funzione della melodia; un singolo suono da solo non ha senso, né ha senso se incluso in una mera indistinta unità di suoni (che creerebbe solo frastuono). Un suono sussiste solo nelle "mutevoli orientazioni" della melodia.

A racchiudere questa verità è la **coscienza interna del tempo**, come descritto da Husserl:

- Nella percezione della melodia, si distingue il tono percepito nell'**istante "ora"** dai toni già passati, detti "non percepiti."
- Tuttavia, si percepisce l'intera melodia come un'unica entità.
- Ciò accade perché l'unità della **coscienza ritenzionale** "tiene saldi" in coscienza i suoni decorsi, producendo l'unità della coscienza relativa all'**oggetto temporale unitario** (la melodia).
- Una melodia, in quanto obiettività temporale, non può essere percepita originariamente se non in questa forma. L'atto di percezione è costituito dalla **coscienza d'ora** e dalla **coscienza ritenzionale**, ed è la percezione adeguata dell'oggetto temporale.

L'unità dell'oggetto (la melodia) non è un mero prodotto della fantasia, ma la coscienza interna del tempo rileva la temporalità dei singoli suoni, nell'unità della melodia, come un **dato oggettivo** e fondamentale. Percepire le note, quindi, significa percepire principalmente la melodia. Se le note vengono trasfigurate (come le note di una tarantella amalfitana nella composizione di Wagner, o le

Madonne di Lorenzo Lotto in un "urlo" espressionista di Munch), tutto cambia e la loro funzione originale viene meno.

Capovolgendo i termini, l'**identità astratta** di un suono o di un'immagine è definita semplicemente "identità." L'**identità concreta**, invece, è la loro **differenza**.

La **funzione** è quindi il **concreto dell'oggetto** poiché mette ogni elemento in relazione con "l'altro da sé," connettendolo al mondo e determinandone la vita.

Fuori dalla differenza e dalla funzione, l'oggetto è inutilizzabile (funzionalmente innominabile). Si pone il problema: **Fino a che punto sussiste la funzione senza struttura?**

In alcuni casi, la logica e gli affari non collimano. Un esempio estremo è il brevetto dell'**acido universale**: l'inventore, pur avendo concepito l'idea di un acido che dissolvesse qualsiasi cosa, si rese conto che era impossibile commercializzarlo. Aveva trascurato l'impossibilità di costruire un **contenitore** (la **struttura** necessaria) per l'acido universale. L'idea di tale contenitore non è mai esistita, e ciò che mancava, indubbiamente, era la struttura necessaria per contenere la funzione.

Sì, esistono **funzioni essenziali** [ωεσεντλιχ (*wesentlich*)].

Esempi di Funzioni Essenziali

- **La Lampada:** È essenziale per una lampada **illuminare**. Non è essenziale [υνωεσεντλιχ (*unwesentlich*)] che essa adorni la stanza.
    - Una lampada priva della capacità di illuminare non sarebbe una lampada reale, ma un oggetto inutile (che ha una struttura ma non una funzione).
    - Una lampada che non soddisfacesse il gusto estetico (non adornasse) resterebbe comunque una lampada e manterrebbe intatta la sua utilità principale. Dunque, la funzione di adornare non è essenziale.
- **Le Lancette dell'Orologio:** Alle lancette può capitare di rimuovere la polvere dal quadrante, ma questo è un uso improprio, non la loro funzione. La loro funzione essenziale è **segnare il tempo con puntualità**. Ci si chiede se possano ancora essere definite "lancette" se sono totalmente incapaci di marcare minuti e ore.

La funzione di un oggetto è intrinsecamente legata al suo contesto e al suo scopo essenziale, come illustrato dall'esempio del frigorifero in due contesti diversi:

1. **Frigorifero come macchina del tempo:** Un frigorifero, conservando i funghi porcini, mostra che il tempo "passa diversamente" per gli oggetti al suo interno rispetto a quelli all'esterno. La sua funzione è dunque quella di **mantenere l'oggetto "giovane"**.
2. **Frigorifero come opera d'arte (*ready-made*):** Se un frigorifero di uso quotidiano viene prelevato e collocato in un museo come opera concettuale (*ready-made*) di Marcel Duchamp, esso **cessa di essere un frigorifero funzionale**(che rinfresca le bevande) e assume la funzione di opera d'arte. L'osservatore che cerca di usarlo per refrigerare l'acqua commette un errore, in quanto non è possibile che l'oggetto sia *ad un tempo* un frigorifero (con la sua funzione essenziale di refrigerare) e un capolavoro d'arte contemporanea (con la sua funzione concettuale).

L'individuazione di queste funzioni essenziali conferma che **la funzione è, appunto, essenziale**. Una lampada che non illuminasse perderebbe la sua ragion d'essere.

Questa idea è poeticamente espressa nel dialogo del film *Al di là delle nuvole*: la ragazza che sta per entrare in Clausura spiega al ragazzo che una vita diversa, piena delle sue speranze, sarebbe per lei **totalmente inutile e priva di senso**, paragonandola all'azione di "**accendere una candela in una stanza illuminata dal sole**."

Questo paragone evidenzia l'**essenzialità della luce** e il suo rapporto ineluttabile con la causa che la produce.

Il problema centrale consiste nell'individuare ciò che è **essenziale** e distinguerlo da ciò che non lo è. Il riconoscimento dell'essenziale passa attraverso la conoscenza dell'oggetto stesso, come nel caso del **gioco**.

Si apprende quali siano gli elementi essenziali di un gioco per il fatto stesso di conoscerlo. Ad esempio, padroneggiando gli scacchi, si sa immediatamente che una regola che imponesse di capovolgere tre volte un pezzo prima di ogni mossa non è essenziale; anzi, è da considerarsi sciocca.

Si apprende quali siano gli elementi essenziali di un gioco per il fatto stesso di conoscerlo. Ad esempio, padroneggiando gli scacchi, si sa immediatamente che una regola che imponesse di capovolgere tre volte un pezzo prima di ogni mossa non è essenziale; anzi, è da considerarsi sciocca.

Sorgono tuttavia dubbi sulla possibilità di conoscere un gioco in modo esauriente, specialmente se si considera la capacità di comprendere l'intera classe dei suoi elementi. Vi è una duplice impossibilità:

1. **Difficoltà nel conoscere tutte le regole:** È arduo conoscere l'insieme completo delle regole del gioco. Ciò è dovuto all'eventuale **aggiunta o sostituzione** di regole che non sono note prima della loro introduzione. Il gioco include, per definizione, anche le regole che in un dato momento **non sono ancora vigenti**.
2. **Idea parziale per mancanza di regole su tutte le azioni:** Anche ammettendo che le regole non cambino, l'idea che si ha del gioco sarebbe comunque parziale. Non tutte le azioni che si verificano durante il gioco sono coperte da una regola. Ad esempio, non vi è una regola specifica che definisca l'altezza o la forza con cui la palla da tennis deve essere lanciata alla battuta. Eppure, queste sono azioni che caratterizzano il gioco. Di conseguenza, l'esistenza di situazioni rilevanti prive di regole impedisce una conoscenza completa del gioco.

A causa di questi fattori, sembra impossibile apprendere un gioco in modo esauriente, lasciando un **concetto sfumato**. Ciò solleva la questione se un concetto sfumato possa ancora essere definito un concetto, analogamente al problema di delimitare o segnalare distintamente un'area non ben definibile.

Sed contra, le obiezioni all'inconoscibilità dei giochi si scontrano con la facile evidenza della **chiarezza della nostra idea dei giochi**. Si conoscono bene gli scacchi o il tennis e si è in grado di praticarli senza agire "a mosca cieca."

La risoluzione di questo apparente paradosso (conoscere qualcosa senza la classe completa dei suoi elementi) è semplice: **possedere il concetto di qualcosa non implica la conoscenza di tutti i particolari**.

- Avere il concetto di "cavallo" non richiede di conoscere tutti i cavalli esistenti.

- Avere il concetto di "automobile" non necessita di informazioni su ogni singola vettura, inclusa la specifica "bianchina" di Roberta.

Lo stesso principio si applica al gioco. **Spiegare un gioco** consiste nel fornire esempi e nel volere che questi siano compresi in un senso specifico. Questo non comporta la necessità di conoscere tutte le regole possibili (anche quelle non attuali) del gioco, né implica la conoscenza di tutte le azioni che possono verificarsi durante il suo svolgimento.

Struttura e funzione, quindi, non sono identiche, e di conseguenza, le condizioni di validità degli atti che da esse derivano non sono della stessa specie.

È vero che **la funzione necessita della struttura**, e allo stesso modo, **la struttura richiede una funzione** per avere senso. Nonostante questa interdipendenza, la struttura e la funzione possiedono ciascuna le proprie specifiche regole.

La **validità pragmatica prima o praxeologica** si occupa esclusivamente dei **doveri** che risalgono alle **strutture** e alle **funzioni essenziali** degli atti.

Le **condizioni praxeologiche di struttura** riguardano l'intelaiatura essenziale dell'atto.

- **La Promessa:** La condizione che la promessa debba riguardare **cose future e non passate** è relativa alla sua struttura essenziale. La promessa è un *speech act* che istituisce un modo specifico di obbligarsi. Affermazioni come "Prometto di averti portato sopra Posillipo e che non ti volevo più bene" o "Il ladro rubò nell'anno che verrà tutti i miei sogni" mancano della **grammatica** e del **senso** (struttura) necessari all'atto linguistico, risultando in "parole a vuoto" o *nonsense*.
- **La Compravendita:** Le condizioni di validità strutturale della compravendita sono quelle che riguardano l'**esistenza del titolo negoziale**. Tali condizioni permettono la conclusione del contratto (es. Tizio compra qualcosa v al prezzo di x). Queste corrispondono al concetto tedesco di *Grundgeschäft* (negozio fondamentale) o, nella dottrina romanistica, ai requisiti della *stipulatio*, identificati come gli **elementi essenziali** del negozio: le parti, il consenso e il duplice oggetto (cosa e prezzo). Ad esempio, l'enunciazione "Vendo a me stesso una cosa di mia proprietà" è un *nonsense* che determina l'**insussistenza strutturale** del vendere qualcosa a qualcuno.

Le condizioni che risalgono alla struttura essenziale di un atto si basano su giudizi che presentano la stessa relazione tra soggetto e predicato dei **giudizi analitici** di Kant.

- **Esempi di Giudizi Analitici:** "Ogni corpo è esteso" o "Tutti gli scapoli sono celibi." In questi giudizi, il predicato si limita a **ripetere o chiarire il contenuto del soggetto**. Quando si pensa a un "corpo" si pensa a una *res extensa*, e non si può concepire un "corpo" senza l'idea di una realtà estesa. Similmente, uno "scapolo" implica l'idea di un "celibe" (non ammobiliato).
- **Caratteristiche:** Si tratta di giudizi **universali e necessari** la cui negazione è sempre falsa a causa della relazione intrinseca tra soggetto e predicato. Poiché il soggetto include già in sé il predicato, i giudizi analitici possono essere trasformati in giudizi tautologici del tipo "A e` A"; affermare "A e` non-A" risulterebbe contraddittorio.

La **praxeologia** presuppone l'esistenza di questi giudizi kantianamente analitici. Il giudizio "**Ogni promessa è un modo di sottoporsi a un'obbligazione**" non fa altro che confermare nel predicato

l'idea già contenuta nel soggetto, racchiudendo in sé tutto il senso delle regole di struttura relative all'esistenza pragmatica della promessa.

Ci si sposta ora dagli elementi costruttivi degli atti, che attengono alla grammatica elementare del linguaggio, allo **sfondo degli effetti essenziali dell'agire performativo**. L'interrogativo alla base delle **regole di funzione** non è "Come si fa una promessa?", ma "**Perché si fanno promesse?**".

Il **dovere di mantenere le promesse** è una condizione di validità funzionale. Viene citato come esempio di "dovere perfetto" (*vollkommene Pflichten*) nella dottrina kantiana degli imperativi categorici.

L'Esempio Kantiano: Si immagini una persona in difficoltà che desidera farsi prestare del denaro. La massima della sua azione è: "Quando credo di avere bisogno di denaro, ne prendo a prestito promettendo di restituirlo, benché sappia che non lo farò mai."

La Domanda di Universalizzazione: Può questa massima diventare una legge universale?

- **Risposta di Kant:** No. L'universalità di una legge che permetta a chiunque in stato di bisogno di promettere con l'intenzione di non adempiere, renderebbe **impossibile il promettere stesso** e il fine che con esso si intende perseguire. Nessuno crederebbe più alle promesse, e si riderebbe di tali dichiarazioni considerandole "inutili pretesti" (*eitles Vorgeben*).

L'Impossibilità Funzionale: Sebbene nelle circostanze concrete della vita sia possibile fare una promessa senza intenzione di mantenerla (sfruttando la "sincerità" implicita delle parole per ottenere fiducia), una situazione del genere non può essere elevata a legge universale. L'impossibilità di universalizzazione deriva dal fatto che **l'interesse e la fiducia del promissario sono la causa essenziale del promettere**. In assenza di fiducia non c'è più ragione d'essere per l'atto della promessa, poiché essa richiede sempre un "tu" o un "voi" come destinatario.

La menzogna non avrebbe storia in una società di esseri trasparenti. Un racconto ipotetico ambientato al Polo Nord, dove i pensieri si congelano nell'aria in nuvolette di ghiaccio , illustra il punto: se qualcuno facesse una promessa con l'intenzione di non mantenerla, tutti leggerebbero istantaneamente il suo vero pensiero (ad esempio, un tricheco che promette fedeltà mentre il suo pensiero rivela l'intenzione di non essere monogamo).

In una situazione del genere (in cui l'altro vede la menzogna), non nasce affatto una promessa. Allo stesso modo, è **impossibile promettere in assenza del promissario**, proprio come è impensabile il colore senza l'estensione spaziale.

La promessa ha un chiaro **significato sociale**. Per annullarla sono necessari fatti precisi (revoca, rinuncia, compimento). Sebbene le pretese e le obbligazioni non siano oggetti fisici, la loro realtà è innegabile. Si percepisce l'architettura di un chiostro, ma si ha bisogno di ulteriori informazioni per individuare la realtà immateriale di un Dipartimento giuridico o della proprietà; tuttavia, nessuno può negare che queste realtà esistano.

Lo studio delle condizioni di validità funzionale include l'argomento di Adolf Reinach sull'**estinzione della pretesa di prestazione impossibile**:

- **Il Problema:** Si può verificare che l'adempimento di una pretesa diventi impossibile (ad esempio, il portatore dell'obbligazione è incapace di realizzare il comportamento promesso, o sopraggiunge un evento che impedisce il risultato).
- **L'Antinomia:** Nonostante l'impossibilità fattuale, Reinach osserva che la pretesa e l'obbligazione non si estinguono immediatamente. Piuttosto, sorge una singolare **antinomia** tra la "tendenza al compimento della relazione obbligatoria" e l'"impossibilità fattuale di tale compimento." Questa situazione genera una "mancanza di senso del tutto particolare," rendendo pretesa e obbligazione "incurabilmente malate."

La Soluzione Funzionale: La pretesa non si estingue per la sua disposizione (la sua struttura di rapporto obbligatorio rimane, con la "tendenza al compimento"), ma per il **vanificarsi della funzione**. L'atto si dissolve perché viene meno la "possibilità fattuale del compimento della relazione obbligatoria," senza la quale il rapporto svanisce.

Il **valore giuridico dell'adempimento** costituisce una condizione generale di validità funzionale degli atti. Le condizioni di validità funzionale sono intrinsecamente connesse agli **effetti** o al valore giuridico prodotti dall'adempimento.

Come osservato da Angelo Falzea, l'effetto funge da "**principio d'individuazione della funzione specifica del negozio**".

- **Esempio (Compravendita):** Nel contratto di compravendita (che trasferisce la proprietà o un altro diritto in cambio di un prezzo, Art. 1470 C.c.), sono condizioni di validità funzionale il **pagamento del prezzo** (Art. 1498 C.c.) e la **consegna della cosa** (Art. 1476 C.c.).
- **Tradizioni Giuridiche:** Queste condizioni sono identificabili nella dottrina tedesca come il *Erfüllungsgeschäft* o *Leistungsgeschäft* (negozio d'adempimento) e, nella tradizione romanistica, come le cause relative alla *traditio*(consegna) successiva alla *stipulatio* (accordo).

Senza l'obbligo di pagare il prezzo e di consegnare la cosa, la compravendita non nasce effettivamente. Anche se si considerano i contratti finanziari complessi (*futures*), in cui beni e prezzi non sono immediatamente disponibili, gli obblighi di consegna e pagamento rimangono fondamentali. Un negozio giuridico privo di "causa" (funzione) può essere paragonato a un paio di scarpe inutilizzabili: non si possono chiamare "scarpe" se non sono adatte a essere calzate.

Lo studio delle condizioni di validità funzionale è essenziale per una logica rigorosa del diritto.

Un'obiezione a questa tesi potrebbe derivare dal **negozio simulato**, che è un accordo tra le parti (o con un terzo) volto a far apparire ciò che non è e a **neutralizzare gli effetti essenziali** del negozio. Le parti intendono conservare il contratto dal punto di vista strutturale, tenendolo separato dai suoi effetti funzionali.

Nel negozio simulato si verifica un'anomalia:

- **Elementi strutturali:** Sono presenti tutti gli elementi essenziali della struttura (es. parti, consenso, oggetto nella compravendita).
- **Conseguenze funzionali:** Vengono impedite le conseguenze interne alla funzione (es. il pagamento del prezzo e la consegna della cosa, che realizzano l'interesse).

Risoluzione dell'Anomalia

1. Validità/Efficacia per i Terzi: Se il negozio simulato non è nullo, è perché il codice lo considera valido **rispetto ai terzi in buona fede** che hanno acquistato diritti dal titolare apparente (Art. 1415 C.c.). Se non producesse questi effetti, il negozio sarebbe nullo. Come spiega Alberto Trabucchi, il negozio simulato è "in sostanza un atto nullo" che, tuttavia, "produce i suoi effetti" di fronte a certi soggetti (efficacia/inefficacia in senso relativo). L'accordo non vincolante tra le parti è considerato un'attività diversa da quella negoziale vera e propria.

2. La Causa (Funzione) come Necessità: Tutte le norme che prescrivono gli effetti tipici del fatto negoziale sono considerate necessarie, in quanto dettate dalla "**causa**" del negozio. La causa si identifica con la **funzione o ragione di essere** del negozio in generale (*causa finalis*), ovvero il tratto specifico del negozio d'adempimento in cui si realizza l'interesse del soggetto. L'esclusione della causa o degli effetti essenziali snatura il regolamento d'interessi, portando il negozio a: * Passare a un tipo diverso di negozio. * Risultare semplicemente **invalido** (*Quod nullum est nullum producit effectum* - Ciò che è nullo non produce alcun effetto).

La soppressione degli effetti impedisce anche di considerare il negozio come un "**bene**". La funzione, infatti, contribuisce a formare il bene di qualcosa. Platone, nel *Cratilo*, osserva che una spola è un bene solo finché è in grado, per sua natura (φυσις *physis*), di tessere. Altrimenti diventa inutile.

L'obbligo degli effetti essenziali implica:

1. La necessità che un fatto esista.
2. La necessità che possa essere definito "**bene giuridico**".

La funzione rappresenta questa **perfezione e questo bene** (α῾γαθο΄ν *agathón*).

Secondo **Aristotele**, "In generale, per tutte le cose che hanno una determinata funzione ed un determinato tipo di attività, si ritiene che il bene e la perfezione consistano appunto in questa funzione."

- **Valore in Relazione al Fatto:** Non si tratta di un valore isolato, ma di un valore in relazione al fatto giuridico. L'effetto giuridico è valore in quanto è **funzione del fatto giuridico**, cioè la funzione che il fatto svolge rispetto alla comunità di riferimento. L'effetto giuridico è funzione proprio perché è il valore attribuito al fatto.
- **Rilevanza Sociale:** Falzea sottolinea che il fatto giuridico non è un semplice fatto, ma uno che possiede una **rilevanza sociale e pratica ben definita**, capace di incidere sugli interessi della vita umana. La sua analisi deve superare il livello strutturale e fenomenologico per mettere in luce le categorie valutative del diritto.

La funzione di un atto stabilisce una vera **relazione eidetica** (essenziale) con la struttura:

- Se la struttura cede, anche la funzione viene meno.
- Se la funzione viene meno, perisce anche la struttura.

In entrambi i casi, negando la struttura o impedendo la funzione, l'atto **cessa di essere ciò che è**.

- Struttura e funzione, disgiuntamente, sono **condizioni necessarie ma non sufficienti** per l'esistenza dell'atto.

- Solo congiuntamente esse formano una **condizione necessaria e sufficiente di validità pragmatica**.

Eliminando l'una o l'altra, l'atto è **autocontraddittorio** (o **autocontraffattorio**), poiché ciò che viene messo in gioco è un *fare* (o un *dire* che coincide sostanzialmente col fare).

La relazione tra **regole di funzione** e **giudizi di verità** è generata da giudizi la cui struttura ricalca quella dei "**giudizi sintetici *a priori***" di Kant.

Si considerino due giudizi:

1. "La retta è la linea più breve tra due punti."
2. "Una retta è divisa in due parti uguali da due archi di circonferenza descritti dall'estremità della linea."

Questi giudizi presentano le seguenti caratteristiche:

- **Universali e Necessari:** La loro negazione è sempre falsa.
- ***A Priori*:** Precedono l'esperienza empirica e non ne dipendono (non sono formulati al termine dell'esperienza).
- **Kantianamente Sintetici:** Il predicato non ripete semplicemente il contenuto dell'idea del soggetto. Ad esempio, nel concetto di "retta" non è implicito che sia la linea più breve tra due punti, né che sia divisibile in parti uguali con l'uso di archi di circonferenza.

Basandosi sulla funzione essenziale degli atti, la validità pragmatica presuppone giudizi sintetici *a priori*.

L'enunciato chiave in questo contesto è: "**L'obbligazione del promittente è il medio della fiducia del promissario**."

Questo giudizio:

- **Determina l'oggettività** del dovere di mantenere le promesse.
- Indica che la promessa nasce simultaneamente alla fiducia del promissario.

L'enunciato è **sintetico** poiché mette in relazione il concetto di "**obbligazione**" (del promittente), che è un'idea strutturale della promessa, con il concetto, ad esso esterno, di "**fiducia**" (del promissario), che ne individua la **funzione specifica** (la promessa esiste per l'interesse del promissario).

Pur essendo concetti esterni tra loro ("obbligazione" non implica immediatamente la "fiducia del promissario"), la loro relazione è possibile perché la **sintesi** si compie nel concetto stesso di **promessa**.

La discussione si focalizza su fino a che punto le **condizioni *a priori* di validità** siano necessarie all'esistenza giuridica, in particolare quando il diritto positivo sembra contraddirle.

Il Caso di Studio (Reinach): L'esempio portato è quello della **promessa di un minore** (ventenne) nel Codice civile prussiano. Un soggetto di vent'anni è perfettamente in grado di compiere promesse di ogni genere e assumere obbligazioni (*Sein* - Essere); eppure, da esse non deriva un'obbligazione

giuridico-positiva pienamente valida, poiché la legge stabilisce una diversa età minima (*Sollen* - Dover Essere).

Altri esempi di apparente contrasto sono il trasferimento delle pretese dal detentore, l'acquisto da parte del creditore della proprietà di un bene mobile non trasferito dal proprietario, o l'esistenza di un'ipoteca del proprietario su cosa propria.

La Soluzione di Reinach (Essere vs. Dover Essere): Reinach ritiene che l'opposizione non sia una vera contraddizione, bensì un contrasto tra **relazioni d'essere** (*Sein*) e **condizioni speciali di dover essere** (*Sollen*).

- Le leggi *a priori* descrivono ciò che l'atto **è** (Essere).
- La disposizione giuridica stabilisce ciò che l'atto **deve essere** in quel sistema (Dover Essere).
- L'opposizione non è tra *essere* e *essere* (che sarebbe contraddittorio), ma tra **essere e dover essere**.

Il diritto positivo ha la "normale *Planung*" di modificare uno stato di cose con un *dover essere* di segno contrario. Ad esempio, la promessa può essere fatta prima dei 21 anni (Essere), ma la legge dispone che ciò sia possibile solo a 21 anni o oltre (Dover Essere).

Nonostante la spiegazione di Reinach, permane il dubbio: può una disposizione legislativa derogare alle **condizioni essenziali di validità pragmatica**, la cui modifica implicherebbe la nullità dell'atto o la sua sostituzione con un altro?

- **Capacità di Obbligarsi:** È un presupposto necessario di validità della promessa che il soggetto sia **capace di obbligarsi** (un pezzo di legno o un attore in scena non possono fare promesse).
- **Età vs. Capacità:** Dall'idea di promessa non si deduce un'età specifica (20 o 21 anni), ma si deduce la necessità della **capacità di intendere e volere**. La disposizione del *Reich* germanico non è quindi una deroga alle leggi essenziali, ma un **rafforzamento** di esse. Il legislatore fissa un'età specifica (21 anni) per assicurare l'oggettività della capacità del promittente, conferendo maggiore oggettività a una legge essenziale .

Promessa Semplice vs. Promessa Giuridica: La specificità degli atti giuridici è quella di integrare le cause naturali di esistenza con **condizioni formali o convenzionali** che mirano a rendere i rapporti meno incerti. La norma sull'età assicura l'oggettività dei rapporti, garantendo al promissario l'efficacia della promessa.

- Una cosa è la promessa *simpliciter* (informale),
- un'altra è la promessa da cui nasce una precisa **obbligazione giuridico-positiva**.

Il linguaggio giuridico genera termini e condizioni aggiuntive (es. accettazione mediante atto sociale per un prestito, estinzione approvata dall'ufficio giudiziario, consenso sulla cosa/prezzo in una promessa di vendita, acquisizione di diritti da parte di terzi), ma queste non alterano le leggi *a priori* della promessa in sé.

La contraddizione tra Essere e Dover Essere si potrebbe escludere solo se l'"Essere" fosse a sua volta un "Dover Essere." In tal caso, l'opposizione sarebbe tra *dover essere* e *dover essere*, rendendo insostenibile che una cosa sia identica alla sua negazione (*Simul et idem*).

Il diritto positivo non può porsi in contrapposizione alle **relazioni essenziali** (*Wesensbeziehungen*).

- **Fatto Mutevole:** Un comando che ordina di chiudere una porta (passaggio da un fatto "porta aperta" a "porta chiusa") modifica un mero stato di cose relativo.
- **Relazione Essenziale:** Quando si afferma che "la promessa è un modo di sottoporsi a un'obbligazione" o "presuppone la fiducia del promissario," si entra nella sfera della **necessità**. Si descrive una relazione essenziale che deve coesistere immutabilmente; non si può pensare la promessa negando contemporaneamente il modo di sottoporsi all'obbligazione.

Conclusione sulla Necessità: Di tutto ciò che è necessario, la negazione è impossibile.

- Rispetto a "2+2=4," è contraddittorio sia "2+2≠4," sia "2+2 non deve essere 4."
- Ordinare l'opposto sfocia nel *nonsense* e devia dalla "realtà stessa."

L'Onnipotenza di Dio e la Contraddizione: Secondo San Tommaso d'Aquino (*Summa Theologiae*), l'onnipotenza di Dio è tale da poter compiere assolutamente tutto ciò che è **possibile** fare.

- **Possibile:** Qualcosa è possibile se il predicato non contraddice il soggetto (es. Socrate che siede).
- **Impossibile:** È impossibile ciò che implica contraddizione (es. pensare a Socrate come un asino).
- **Il Limite:** Ciò che è **contraddittorio** implica in sé l'essere e il non essere simultaneamente. . La contraddizione non è soggetta all'onnipotenza divina non per difetto del potere di Dio, ma perché non ha la natura di cosa **fattibile o possibile**; non può essere concepita da nessun intelletto per diventare oggetto della potenza divina. L'Angelo ha ragione a proclamare che "non esiste parola che sia impossibile a Dio," poiché la contraddizione non è, di fatto, una "parola" (un concetto concepibile).

Il concetto di **validità pragmatica** si distingue in due livelli:

1. **Validità Pragmatica Prima (o Praxeologica):** Questa validità deriva direttamente dall'**idea stessa degli atti**(eɪ^dos). Essa è legata ai doveri universali e necessari impliciti nella natura dell'atto stesso.
2. **Validità Pragmatica Seconda (o Praxeonomica):** Questa validità è definita da **condizioni** che non risalgono all'idea intrinseca dell'atto, ma a **norme esterne** (no´moi) ad essa. Tali condizioni possono essere:
    - **Doveri universali e necessari** (già inclusi nella prima validità ma qui considerati nel loro rapporto con le norme esterne).
    - **Condizioni solo possibili** o doveri che dipendono da **norme solo possibili**.

Esempio: L'Articolo 32 del Codice Penale

Viene preso in considerazione l'**Articolo 32 del Codice Penale italiano**, nella sua formulazione **precedente** all'entrata in vigore della legge 689/1981.

- **Condizione Stabilita:** L'articolo prevedeva che il condannato all'ergastolo perdesse la **capacità di fare testamento**. Questa era una precisa **condizione pragmatica** che escludeva la validità degli atti di successione per l'ergastolano.

- **Natura della Regola:** Questa regola era **estranea all'idea intrinseca di testamento** (negli atti "mortis causa"). Essa derivava, invece, da una **norma *ab extra*** rispetto al concetto del negozio giuridico testamentario.
- **Funzione:** L'Articolo 32 fissava l'impossibilità di testare come una **pena accessoria** legata alla condanna all'ergastolo.
- **Carattere Non Necessario:** Si sottolinea che questa non era una regola inevitabile. La norma dell'Articolo 32, così come la funzione di pena accessoria associata al testamento, era considerata una **norma solo possibile e non necessaria**. Non era indispensabile che il testamento prevedesse tali effetti, né si trattava di una disposizione universalmente prevista in ogni ordinamento giuridico.

Evoluzione Normativa

- **Esito Finale:** In Italia, un **fatto** è prevalso sull'ipotesi normativa precedente.
- **Riforma del 1981:** La riforma introdotta dalla legge 689/1981 ha **eliminato** dal novero delle pene accessorie sia la perdita della capacità di fare testamento che l'annullabilità del testamento redatto prima della condanna.

Nel contesto dei grandi **"tractatus de contractibus"** (trattati sui contratti) che fiorirono tra il XVI e il XVII secolo, la **validità praxeonomica** viene riferita agli **"accidentalia contractus"**.

- **Cosa sono gli *accidentalia contractus*?** Sono gli elementi del contratto che **non preesistono** alla volontà delle parti, ma la cui presenza o assenza dipende **esclusivamente** dalla libera volontà dei contraenti.
- **Dipendenza dalla Volontà:** Essi dipendono dalla volontà delle parti sia per il loro inserimento nella forma del contratto, sia per la loro eventuale esclusione.

Francesco Mantica, nelle sue *Vaticanae lucubrationes* (1609-1610), fornisce una chiara identificazione degli *accidentalia contractus*.

- **Caratteristiche:** Mantica li definisce come quei fattori **indipendenti dalla natura intrinseca del contratto**. Sono elementi che possono essere considerati **estranei o separati** (rispetto all'essenza del contratto) poiché sono riconducibili alla **libera volontà** dei contraenti.
- **Effetto sull'Atto:** La loro eventuale **assenza** o il loro mancato sorgere **non impedisce** al contratto di mantenere la sua identità essenziale ("di essere ciò che è"). Inoltre, il contratto non viene trasformato nelle figure di **irregolarità contrattuale**.
- **Irregolarità Contrattuale:** Le figure di irregolarità contrattuale sono invece strettamente connesse alla deviazione da **condizioni che non originano dal solo concorso della volontà** (cioè, da elementi essenziali o naturali, non accidentali).
- **"Notissimi Termini":** Mantica chiama **"notissimi termini"** i limiti che derivano da uno **schema preordinato** alla struttura fondamentale del contratto (gli elementi non accidentali, come quelli essenziali o naturali).

Le condizioni che si riferiscono alla **funzione inessenziale degli atti** vengono messe in relazione con i **"giudizi sintetici a posteriori"** nella terminologia kantiana.

- **Definizione:** Un giudizio sintetico a posteriori è una proposizione la cui verità è **solo possibile e non necessaria**. La sua negazione non implica una contraddizione logica.

- **Esempio (Camicia di Ernesto):** Nel giudizio "La camicia di Ernesto è nera", il predicato ("è nera") non è contenuto nell'idea del soggetto ("La camicia di Ernesto"). La camicia potrebbe essere anche "di mille colori", senza che ciò sia logicamente assurdo.
- **Verificazione:** Per stabilire la verità di questo giudizio, è necessaria l'**esperienza** (*a posteriori*). Bisogna "vedere" la camicia, non basta una deduzione pura dell'intelletto.

La condizione che, prima della riforma del 1981, impediva il testamento del condannato all'ergastolo (Art. 32 c.p.) supponeva una proposizione analoga: **"La perdita della capacità di testare è una pena accessoria"**.

- **Sinteticità:** Questa proposizione è **sintetica** perché mette in relazione il concetto di **testamento** (negozio *mortis causa*) con il concetto, diverso, di **pena**.
- **Inessenzialità:** L'essere una pena accessoria non è incluso nel concetto essenziale di testamento. Di conseguenza, questa circostanza individua una **funzione solo inessenziale** del testamento.
- **A Posteriori:** Si tratta di una verità che si apprende **kantianamente *a posteriori***, cioè solo attraverso la **lettura diretta** (l'esperienza) della norma specifica contenuta nel Codice Penale italiano prima della modifica dell'Articolo 32.

Una questione specifica riguarda la struttura inessenziale degli atti, prendendo come esempio la forma del **testamento olografo** (Art. 602 c.c.).

- **Inessenzialità:** Affidare le proprie volontà a un documento interamente **autografo** non è una regola necessaria per la validità *generale* del testamento. L'olografia è una **facoltà** introdotta dal Codice Civile a partire da una struttura inessenziale delle disposizioni testamentarie, poiché esistono ordinamenti che non prevedono il testamento olografo senza che l'istituto delle successioni ne risenta.
- **Validità Praxeonomica:** L'esistenza stessa del testamento olografo dipende dall'Art. 602 del Codice Civile e, pertanto, appartiene alla **validità praxeonomica**.

All'interno dell'idea del testamento olografo, tuttavia, emerge una regola **necessaria**: la condizione che il documento sia **"sottoscritto di mano del testatore"** è tecnicamente indispensabile per l'esistenza del testamento olografo stesso.

- **Nuovo Giudizio:** Questa particolare conseguenza porta all'identificazione di una nuova tipologia di giudizio che non compare nella dottrina kantiana classica: il **"giudizio analitico a posteriori"**.
- **Esempio: "Ogni testamento olografo è sottoscritto di mano del testatore"**.
    - **Analiticità:** È un giudizio **necessario** (analitico) perché nel predicato ("è sottoscritto...") non si dice nulla di più di quanto è già contenuto nell'idea del soggetto ("Ogni testamento olografo..."). Un testamento interamente scritto dal testatore ma non sottoscritto non sarebbe logicamente pensabile come olografo.
    - **A Posteriori:** Tuttavia, il **soggetto** stesso ("testamento olografo") **non è un'idea originaria o necessaria**(come lo è l'idea di testamento *simpliciter*), ma è il **frutto di una produzione *a posteriori*** stabilita dal codice (Art. 602 c.c.).
- **Carattere Derivato:** L'idea di testamento olografo si colloca in una posizione derivata, in quanto **prodotta** da un'idea prima o originaria (quella di testamento *simpliciter*), e non è originale come le idee semplici di "intero" o "corpo". Il giudizio esprime una verità necessaria, ma il cui soggetto è prodotto *a posteriori*.

-
- **Oggetti Giuridici:** Molti oggetti giuridici nascono e finiscono grazie alle **regole costitutive** che ne fissano l'inizio.
- **Esempi:** Concetti come il "tennis" o il "mutuo bancario" sono fatti creati da regole, mentre le idee di "gioco" o di "credito" (*fides*) sono forse più originarie.
- **Conclusione sul Diritto:** Nel diritto, la maggior parte degli istituti giuridici è storicamente **costituita da regole**. In questo senso, il complesso dei rapporti giuridici previsti dall'ordinamento è generato prevalentemente da **verità analitiche a posteriori**.

Doveri sintattici

Nel suo saggio del 1946 intitolato *Signs, Language and Behaviour* (*Segni, linguaggio e comportamento*), **Charles W. Morris** definisce "**sintattica**" la branca della semiotica dedicata allo studio delle **relazioni tra i segni** che sono fondamentali per il loro significato.

Si evidenzia come i segni, se non sono interconnessi, risultino banali. Il termine stesso "sintattica" deriva dal greco *syn-táttein* (Συν-ταττειν), che letteralmente significa "**mettere insieme**".

Questa validità sintattica trova un'applicazione analoga e non dissimile anche nell'ambito delle **norme**, considerate dei "segni" molto particolari. Anche le norme, infatti, traggono la loro esistenza e il loro significato dal **rapporto reciproco** che instaurano all'interno di un **ordinamento**.

Si tratta di un argomento intrinsecamente plausibile: così come un albero è parte di una foresta, esiste non solo la singola norma, ma anche l'ordinamento normativo nel suo complesso. Tuttavia, il legame tra la singola norma e l'ordinamento è presentato come **ancora più stretto** rispetto a quello tra un albero e la foresta.

È ritenuto improbabile che le norme possano esistere isolatamente (come l'albero della vita di Klimt che rinasce continuamente). In conclusione, **l'ordinamento** è considerato **necessario** quanto l'esistenza stessa delle singole norme.

L'idea che le norme esistano all'interno di un **ordinamento** è supportata da un risultato consolidato della teoria generale del diritto: si fa riferimento costante a un "**corpo di norme**" e mai a singole norme isolate. Concetti come *Rechtsordnung*e *legal order/system* (usati rispettivamente da Kelsen e Hart), o *body of rules* (secondo Austin), sono ricorrenti in questo contesto.

In questa prospettiva, il problema della **validità delle singole norme** si inserisce e viene compreso all'interno del quadro più complesso dell'**organismo** che le aggrega in un ordinamento. L'ordinamento è definito proprio come quell'insieme in cui le parti – le singole norme – **esistono in virtù del loro legame reciproco**.

La **validità sintattica** va oltre il mero presupposto di un generico vincolo tra le norme; essa identifica anche il **nesso specifico** per cui l'esistenza delle une dipende da quella delle altre.

Affermare che una norma è valida costituisce, in realtà, un **giudizio ipotetico** e non categorico, formulato in termini come: *"Se questi sono i criteri di validità di quest'ordinamento, allora questa norma è valida in tale ordinamento."*

Una norma esiste, dunque, a partire da altre norme che ne stabiliscono i criteri di validità. **Hans Kelsen**, nella sua *Dottrina pura del diritto*, spiega che la validità in senso formale (*Geltung*) è l'**esistenza specifica di una norma**(*spezifische Existenz einer Norm*). L'aggettivo "specifica" indica che le norme non sono mai autonome, ma sono sempre in relazione con altre, risalendo fino alla *Grundnorm* (Norma fondamentale) dell'ordinamento.

Bisogna esplorare criticamente la possibilità che un ordinamento possa essere costituito da un'unica norma, analizzando tre ipotesi estreme:

1. **"Tutto è permesso."**
    - Questa massima è la traduzione in termini di "permesso" del motto studentesco del '68, "È vietato vietare."
    - Si solleva il dubbio sulla pensabilità di un ordinamento di questo tipo e su quale differenza esisterebbe tra lo **stato di natura** e il diritto, poiché il diritto nasce proprio per superare la situazione di libertà illimitata introducendo obblighi e divieti.
2. **"Tutto è proibito."**
    - In un contesto siffatto, vi sarebbe spazio unicamente per gli **eventi deterministici della natura**. Il *dovere per imputazione* (*Sollen*) si trasformerebbe in *dovere causalistico* (*Müssen*).
    - Ogni azione derivante dalla libertà umana sarebbe negata, e persino le semplici idee risulterebbero proibite. Una massima del genere sarebbe **inefficace**, poiché il diritto perirebbe senza le libertà e le passioni dell'uomo.
3. **"Tutto è obbligatorio."**
    - Questa ipotesi pone un problema di **conflitto tra azioni**, poiché se tutto è obbligatorio, devono essere compiute anche un'azione e la sua negazione (ad esempio, l'obbligo di "chiudere la porta" e, contemporaneamente, l'obbligo di "aprire la porta," in quanto opposto del comando).
    - Si giunge a una situazione di **indecidibilità** analoga al noto paradosso del barbiere che ha l'obbligo di radere tutti coloro che non si radono da soli.

Nonostante l'esplorazione di queste ipotesi, vi è un dubbio di fondo: anche ipotizzando l'esistenza di una sola norma, ad esempio **"È vietato vietare"**, essa presuppone sempre la **regola sul criterio di validità** delle norme stesse.

Di conseguenza, il sistema necessiterebbe almeno di due norme: la norma sostanziale ("È vietato vietare") e la norma che stabilisce la validità o la legittimità del potere costituente (ossia, la legittimità del divieto proclamato dagli studenti). Ciò significa che, in realtà, non vi sarebbe mai una sola norma, ma **già un ordinamento**. Questa considerazione è valida per tutte e tre le ipotesi formulate.

La **validità sintattica** è indipendente dall'ontologia specifica delle norme. Non è rilevante stabilire la loro natura intrinseca, ovvero se siano da considerare enunciazioni performative, proposizioni deontiche, *status* deontici, fatti sociali, consuetudini, principi o valori. L'attenzione si concentra, invece, sulla loro **funzione sintattica o ordinamentale**.

In questo contesto, alcune norme assumono una posizione di maggiore rilievo nella logica della validità sintattica: le **"norme di struttura"**. Queste norme hanno la funzione specifica di **fissare le condizioni di validità** all'interno dell'ordinamento.

Un esempio emblematico è l'articolo che istituisce gli organi preposti alla produzione delle altre norme. Si pensi all'**Articolo 70 della Costituzione italiana**, il quale attribuisce la funzione legislativa alle due Camere, ponendo così la base per l'approvazione delle leggi in Italia.

La preferenza accordata alle norme di struttura si basa su una duplice motivazione:

1. **Significato Ordinamentale:** Le norme di struttura possiedono un chiaro significato ordinamentale in quanto **stabiliscono le condizioni di esistenza delle altre norme**. Partendo dalla loro nozione, risulta più agevole concepire la **trama formale** che connette le norme tra loro; non è possibile, infatti, pensare le une senza le altre.

2. **Primato Scientifico:** Queste norme detengono il primato nella scienza della validità normativa. Chiedersi quale sia la validità di una norma implica, infatti, risalire all'esistenza di tale norma partendo dalle **regole o norme che disciplinano la vita dell'ordinamento** stesso.

Di conseguenza, la **validità normativa** è definita come **sintatticamente ordinamentale**.

Dall'insieme generico delle **norme di struttura** emergono diverse condizioni che definiscono la validità sintattica. Si rende necessaria una distinzione tra due categorie di norme:

1. **Norme prodotte:** Sono norme che scaturiscono da atti di **produzione** (poste, *gesetzt*) da parte di un legislatore.
2. **Norme presupposte (Metaregole):** Sono norme che figurano come **proposizioni logiche** dell'ordinamento; non sono poste (*gesetzt*) ma **presupposte** (*vorausgesetzt*) rispetto agli atti di posizione del legislatore.

Queste ultime, le norme presupposte, vengono definite più propriamente come **regole su norme** o **regole su regole**(**metaregole**).

Nella tradizione giuridica romana, i principi o *praesumptiones* erano chiamati **"regulae"** e avevano un significato prevalentemente **teoretico-cognitivo** anziché pratico-normativo, almeno fino all'epoca di Labeone (e includendo l'opera successiva dei glossatori e dei commentatori).

Due livelli distinti di validità sintattica in base alla loro origine:

- Dalle **norme del legislatore** (norme prodotte) deriva la **validità sintattica seconda**, o **sintasseonomica.**
- Dalle **regole non poste ma presupposte** discende la **validità sintattica prima**, o **sintasseologica**.

L'analisi successiva del testo sarà focalizzata sulla validità sintattica prima (sintasseologica).

Esistono almeno due categorie principali di norme che rientrano nel gruppo delle "norme di struttura":

1. **Norme Secondarie:**
    - Queste norme, considerate singolarmente (*uti singulae*), sono **non necessarie** e solo **possibili**.
    - Sebbene facciano parte di un ordinamento, la loro assenza non ne comprometterebbe l'esistenza in senso assoluto.
    - Un esempio è una norma specifica sulle fonti del diritto, come l'Articolo 70 della Costituzione.
2. **Regole o Metaregole (in senso stretto):**
    - Si tratta di tutti quei doveri che possiedono la forza di **condizioni essenziali di validità**, anche se considerati singolarmente (*uti singulae*).

La **validità sintattica prima**, o **validità sintasseologica**, è la disciplina che studia queste condizioni essenziali.

La **perentorietà** di tali doveri deriva dal fatto che essi non sono il semplice esito di atti di normazione **estrinseci** all'idea di ordinamento (atti *ab extra*). Al contrario, essi discendono direttamente **dall'idea stessa di ordinamento**.

Per tale motivo, la validità sintattica può essere definita anche "**validità sintasseologica**", in quanto la sua esistenza dipende da **principi necessari** – che in greco sono chiamati *lógoi* – i quali sono **intrinseci** (*ab intra*) all'idea di ordinamento.

Una **metaregola** essenziale dell'ordinamento è la **"norma di chiusura"**. Questa norma stabilisce che **sono valide solo ed esclusivamente** quelle norme che fanno parte dell'ordinamento, specificamente quelle che sono state:

1. **Validate** secondo le regole di **formazione** dell'ordinamento.
2. **Validabili** secondo le regole di **trasformazione** dello stesso ordinamento.

In sostanza, la norma di chiusura implica che, se l'ordinamento è definito come l'insieme delle norme valide e se la validità è l'esistenza specifica delle norme in esso, allora solo le norme che vi appartengono sono considerate norme.Possono essere norme nuove, prodotte da regole di formazione, oppure norme preesistenti (come le norme di costume) che vengono validate da regole di trasformazione, acquisendo così status giuridico.

Da questo punto di vista, l'ordinamento è un **sistema chiuso** per una necessità logica. L'esistenza di norme al di fuori di esso ha due conseguenze logiche: o l'ordinamento perde la sua definizione di insieme di norme valide, oppure le norme esterne sono considerate **invalide**. Di fatto, fuori dall'ordinamento non c'è validità, e una norma invalida non è realmente una norma. Questa idea richiama la proposizione di Wittgenstein secondo cui la totalità degli stati di cose sussistenti (il mondo) determina anche quali stati di cose non sussistono.

Da questo punto di vista, l'ordinamento è un **sistema chiuso** per una necessità logica. L'esistenza di norme al di fuori di esso ha due conseguenze logiche: o l'ordinamento perde la sua definizione di insieme di norme valide, oppure le norme esterne sono considerate **invalide**. Di fatto, fuori dall'ordinamento non c'è validità, e una norma invalida non è realmente una norma. Questa idea richiama la proposizione di Wittgenstein secondo cui la totalità degli stati di cose sussistenti (il mondo) determina anche quali stati di cose non sussistono.

Un altro esempio di metaregola è la **"norma fondamentale"** (*Grundnorm*) di **Kelsen**.

Secondo Kelsen, la **costruzione a gradi** (*Stufenbau*) dell'ordinamento richiede l'unità di tale sistema. Questa unità deriva dalla **concatenazione** delle norme: la produzione e quindi la validità di una norma risale a un'altra, in un regresso che termina nella **norma fondamentale**, la regola ipotetica che funge da **fondamento supremo di validità** e base dell'unità della concatenazione produttiva.

L'esistenza di una norma necessita di un **atto di produzione** che non è un atto naturale, ma acquisisce un **significato oggettivo di fatto giuridico** riconoscibile attraverso un'altra norma. Ad esempio, una sentenza giudiziaria risale alle norme sull'ordinamento giudiziario, le quali, a loro volta, fanno capo all'Articolo 102 della Costituzione sulla funzione giurisdizionale. Ogni norma e ogni atto richiedono un atto specifico di produzione o un'altra norma.

Una prima conseguenza di questa struttura è che la norma che ne produce un'altra è gerarchicamente **superiore**. Può esistere senza la norma prodotta, ma non viceversa. Per esempio, le norme sull'ordinamento giudiziario sono valide indipendentemente dalle singole sentenze, mentre la validità di una sentenza (ad esempio, in ambito civile) dipende da norme di grado superiore (come l'Art. 18

del Codice di procedura civile sul "foro generale delle persone fisiche"). Per questo motivo l'ordinamento si sviluppa tramite una **"costruzione a gradi"** (*Stufenbau*).

Una seconda e cruciale conseguenza è che il passaggio dalla norma di grado inferiore alla rispettiva norma di produzione (grado superiore) **non può essere un regresso all'infinito**. Un regresso illimitato porterebbe l'ordinamento a contraddirsi, lasciandolo senza fondamento e in balia di una serie inesauribile di condizioni potenzialmente in conflitto.

Da qui deriva la necessità della *Grundnorm*, o di una **regola apicale** al vertice, che è **non posta ma presupposta**, e la cui validità non dipende da una norma di grado superiore.

Questo ragionamento sulla necessità di un fondamento ultimo è accostato all'argomentazione di **San Tommaso** per dimostrare l'esistenza di Dio: partendo dalla premessa che "ogni cosa che si muove è mossa da altro" (*"Omne quod movetur ab alio movetur"*), si deduce che, per evitare un rinvio infinito di cause, deve esistere una **"causa prima"**incausata.

Un principio simile è applicabile anche al mondo degli oggetti intenzionali e dei significati: un linguaggio non avrebbe luogo se le parole prevedessero una successione illimitata di sensi, come dimostrato dall'esempio paradossale della discussione sul detto "Non puoi avere la botte piena e la moglie ubriaca."

Si conclude che, se esistono norme valide, deve esistere una **norma prima** (non c'è *regressus in infinitum*). Affermare la validità della *Grundnorm* è il risultato di un **giudizio ipotetico**: "Se c'è l'ordinamento, vige anche la norma: *'Ci si deve comportare secondo la Costituzione effettivamente statuita ed efficace'*" (la *Grundnorm*).

È evidente che una norma invalida non è una norma. Meno ovvia, ma necessaria, è l'affermazione che una norma è valida solo se esiste in un ordinamento. La *Grundnorm* implica l'obbligo di comportarsi secondo le norme effettivamente statuite ed efficaci, stabilendo che pensare a una norma significa sempre alludere a una norma in un ordinamento. Dunque, esistono almeno due norme: la norma statuita e la norma che ne prescrive l'adempimento.

La *Grundnorm* consolida l'idea di ordinamento ed è ciò che Kelsen intende affermando che la validità è **"l'esistenza specifica di una norma"**; il termine "specifico" indica la validità normativa come **validità ordinamentale**.

La **Norma Fondamentale è una metaregola** perché la sua esistenza dipende dall'**oggettività del suo contenuto** e non da atti estrinseci di normazione. Il suo contenuto coincide con l'idea stessa di ordinamento: l'ordinamento comanda il proprio adempimento. L'ordinamento, se non includesse il principio di obbedienza al sistema vigente, si vanificherebbe nella contraddizione (come un ordine che intimasse anche di non essere eseguito). Sarebbe una **tautologia** ("un ordinamento è un ordinamento", o "un ordinamento deve essere un ordinamento"). Un ordinamento che stabilisse doveri e poi disponesse, in chiusura, una norma permissiva fondamentale come "Tutto è permesso" ("A non deve essere A") risulterebbe contraddittorio.

Sia la norma generale di chiusura sia la *Grundnorm* kelseniana operano come **condizioni di validità strutturale**, presupponendo che l'ordinamento giuridico sia concepito come un insieme o sistema di norme.

Si pone la questione se anche la validità sintattica, analogamente a quanto accade per la validità pragmatica, includa principi generati dalla **funzione** dell'ordinamento. La conclusione che le regole di funzione siano alla base degli atti giuridici è particolarmente rilevante per la validità sintattica e per la teoria generale del diritto (anche in relazione alla tesi della pluralità degli ordinamenti).

Norberto Bobbio, nell'opera *Dalla struttura alla funzione* (1977), individuava la differenza tra **Hart** e **Kelsen** proprio nel diverso peso attribuito alla "funzione" nel concetto di diritto:

- **Hart:** Ritiene che l'ordinamento giuridico possa essere compreso appieno solo individuando la sua **funzione** oltre alla sua **struttura** (l'insieme delle norme). La struttura è l'insieme delle norme, mentre la funzione riguarda soprattutto la sua **efficacia**.
- **Kelsen (*Rechtslehre*):** Adotta una prospettiva più ristretta, considerando l'ordinamento solo per la sua **struttura**, teorizzandolo come un "**meccanismo coattivo**" basato principalmente su prescrizioni sanzionatorie. Kelsen afferma che la dottrina pura del diritto considera l'ordinamento nella sua **autonomia normativa strutturale** e non in relazione al suo scopo o come possibile causa di un effetto determinato.

Il punto di vista funzionale della validità sintattica contribuisce comunque a una "**dottrina pura**" del diritto in senso kelseniano, in quanto la sua "purezza" (*Reinheit*) risiede nel suo posizionarsi al di sopra di ogni dato puramente empirico e ideologico. Gli elementi necessari alla validità funzionale sono essenziali per elaborare una nozione astratta e scientifica del diritto e per cogliere la peculiarità dei singoli ordinamenti.

Un argomento particolarmente interessante, tratto dal diritto penale canonico, riguarda il ruolo della **misericordia**.

L'**inesigibilità** (*Nichtzumutbarkeit*, *Unzumutbarkeit*) di un comportamento conforme alle norme è una regola fondamentale dell'ordinamento della Chiesa, il cui scopo primario è la **salvezza delle anime**. Nel diritto canonico, l'obbedienza non è necessariamente il fulcro centrale della legge. È necessario confrontare la pena con l'istanza salvifica del messaggio evangelico. Il Canone 1752 del *Corpus iuris canonici* stabilisce che "la salvezza delle anime [...] deve sempre essere nella Chiesa la **legge suprema**".

Ciò comporta un **limite sostanziale** alla maestà della legge e un **antiformalismo** raro in altre esperienze giuridiche.

Il legame tra inesigibilità e salvezza si spiega così:

- La conservazione e l'incremento della salvezza richiedono spesso di **relegare in secondo piano l'efficacia delle leggi**.
- Si può compiere un'azione contraria alla legge e ottenere il perdono basandosi sulla **retta coscienza**, poiché per la salvezza è cruciale la **rettitudine interiore** piuttosto che l'azione esterna.
- Si può ottenere il perdono anche in assenza di buone intenzioni, in quanto agisce la **carità**, che è precedente alla legge. Senza carità, la legge non salva, analogamente alla fede che, secondo Sant'Agostino, se priva di amore, *est ma non prodest* (esiste ma non giova a nulla).

Il concetto è sintetizzato nell'idea che **l'inferno esiste ma (forse) è vuoto** (tesi di **Hans Urs von Balthasar** in *Was dürfen wir hoffen?* del 1986). La Chiesa non ha l'autorità di proclamare

direttamente la dannazione di alcuno. La misericordia non è una superficiale "pappa del cuore" (*Brey des Herzens*), ma un legame profondo con la giustizia.

Anselmo d'Aosta in *Cur Deus homo?* (1098) spiega il legame tra giustizia e misericordia: Dio non rinuncia alla giustizia a causa del peccato, ma la soddisfa sacrificando sulla croce il Figlio incarnato. La forza che richiede il rispetto della legge dialoga incessantemente con la misericordia per la vita eterna dell'uomo.

Questo criterio di inesigibilità non è valido, invece, per il **diritto statuale**, come dimostrato da diversi elementi:

1. **Principio di Esigibilità Inderogabile:** Il sistema penale dello Stato si basa su un principio rigoroso e inderogabile di **esigibilità** rispetto alla responsabilità personale.
2. **Responsabilità Oggettiva:** Questo principio è esteso anche alla **responsabilità oggettiva**, dove si risponde di un evento anche in assenza di un legame psichico (attuale o potenziale) tra il soggetto e l'evento stesso. Il soggetto è chiamato a rispondere per un'azione che normalmente non si poteva pretendere da lui, sebbene vi fosse la possibilità eccezionale di agire per evitare l'evento. L'esigibilità nel diritto statuale, quindi, è una regola così fondamentale da **scavalcare i limiti normali** della responsabilità personale.

Le fattispecie che costituiscono basi normative per il principio d'inesigibilità (come il caso fortuito, la forza maggiore, lo stato di necessità e il conflitto di coscienza descritto dall'Art. 384 del Codice penale) sono tutt'altro che generali. Esse **non formano una norma fondamentale** dell'ordinamento e non possono essere estese oltre le ipotesi previste dagli articoli (ad esempio, gli Art. 45, 54 e 384 del Codice penale). L'inesigibilità, così circoscritta, non può essere utilizzata come categoria generale in grado di condizionare l'imputazione e la responsabilità.

Sotto altri profili, la legge penale statuale manifesta un carattere di esasperazione esigendo obbedienza persino da **animali e cose inanimate**.

- Il **Libro dell'Esodo** (21, 28-32) contiene la norma secondo cui un bue che cozza contro un uomo o una donna uccidendoli deve essere **lapidato**, e la sua carne non deve essere mangiata (esteso anche al caso in cui colpisca uno schiavo o una schiava).
- **Platone** nelle *Leggi* descrive un **processo contro cose**: se un oggetto inanimato provoca la morte di un uomo (eccetto i fulmini di origine divina), il parente più prossimo deve prendere un giudice, compiere l'espiazione, e l'oggetto condannato dev'essere gettato fuori dai confini.

Infine, le **Universitates** (persone giuridiche) spesso prendono il posto delle persone fisiche. Il principio generale di responsabilità delle *Universitates*, di origine germanica e dominante nel Medioevo, è oggi riscontrabile nella **responsabilità amministrativa degli enti giuridici** (incluse società e associazioni prive di personalità giuridica), come previsto dal D.Lgs. 231/2001 (Art. 8), che stabilisce la responsabilità dell'ente anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile.

Sono fatti molto diversi da quelli che accadono nel Paese delle Meraviglie. **Alice si mostra completamente indifferente e insubordinata** ai comandi della Regina di Cuori in *Wonderland*, evidenziando che per lei tali minacce non hanno alcun peso.

Quando il corteo della Regina si ferma di fronte ad Alice, la Regina la interroga in modo severo chiedendole il suo nome. Alice risponde educatamente ma, pensando tra sé, si rassicura che i suoi interlocutori sono **soltanto un mazzo di carte**, e per questo non deve avere paura di loro.

La Regina poi chiede ad Alice l'identità dei tre giardinieri distesi attorno al rosaio. Alice risponde **con inaspettato coraggio** che non spetta a lei saperlo ("Non sono affari miei"). La Regina, infuriata, diventa paonazza e comincia a urlare la sua tipica condanna: "Mozzatele il capo!". Alice, in risposta, **replica con forza e decisione "Sciocchezze!"**, mettendo immediatamente a tacere la Regina.

L'analisi successiva spiega il motivo di questa audacia: Alice non si cura degli ordini della Regina poiché **sa di non appartenere al mondo di un mazzo di carte**. La vera questione non riguarda l'obbligatorietà o la non-obbligatorietà dei comandi, ma la loro **validità**. L'esigibilità di una legge presuppone sempre che essa sia valida ed efficace, ma Alice è **estranea** al mondo delle carte e della Regina di Cuori.

Si sottolinea l'impossibilità intrinseca della situazione: un mazzo di carte non può dare ordini a una bambina del genere umano. Questa situazione è paragonata ad eventi che non possono accadere nelle fiabe (come una tegola che cade sulla testa del principe azzurro) e alla dinamica del potere tra **Gulliver e il Re di Lilliput**: nonostante Gulliver si impegni a non danneggiare la città, la sua forza è enormemente superiore a quella degli abitanti alti sei pollici. In entrambi i casi (Alice e Gulliver), il potere o l'autorità esercitati sono **sospesi o invalidati** dalla forza e dalla natura straordinariamente diverse e superiori dell'ospite.

L'importanza della **funzione** nella validità sintattica è cruciale, non solo per sostenere la tesi della **pluralità degli ordinamenti** (come la differenza tra lo Stato e la Chiesa), ma anche per comprendere il concetto astratto di diritto. La **Norma fondamentale** di Kelsen si limita a presupporre che il diritto sia una mera struttura normativa, ignorando la funzione. Tuttavia, la funzione rappresenta un **nucleo decisivo della validità ordinamentale**, tanto da poter fondare un senso di *Grundnorm* alternativo a quello kelseniano.

Oltre alla **validità sintattica prima o sintasseologica**, ne esiste una seconda, chiamata **validità sintattica seconda o sintasseonomica**. Questa validità fa capo a un tipo specifico di **norme di struttura** definite in senso stretto **"norme secondarie"**.

- **Norme Secondarie:** Sono norme *su* norme ("doveri su doveri") che stabiliscono le condizioni di validità di altre norme.
- **Caratteristica:** Non sono necessarie, ma sono **poste** (*gesetzt*) attraverso specifici atti di normazione, e quindi sono atti *ab extra* rispetto alla semplice idea di ordinamento. L'espressione "sintasseonomica" rimanda proprio a queste norme poste dal legislatore (dal greco *nómoi*).

Esempi di Norme Secondarie

1. **Norme sulla Legislazione:** L'Articolo 70 della Costituzione ("La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere") è una norma secondaria. Essa stabilisce gli organi legislativi, ma non è necessaria; la funzione legislativa potrebbe essere esercitata in modi diversi, come nel modello platonico in cui governano i filosofi.
2. **Norme sulla Gerarchia delle Fonti:** L'Articolo 15 delle Preleggi, che stabilisce il principio **"Lex posterior derogat priori"** (la norma successiva abroga la precedente in caso di

incompatibilità), è una norma che condiziona la validità di altre norme in base a un criterio temporale.

- **Non Necessità:** Anche questa norma non è necessariamente universale. Il diritto della Chiesa, per esempio, applica il primato della norma successiva con maggiore cautela per il valore attribuito alla sua **tradizione**(come stabilito dalla *Dei Verbum*).
- **Inversione Temporale:** Nel caso dei diritti soggettivi, vige invece il principio opposto: **"Prior tempore potior iure"** (chi acquista il diritto prima nel tempo è più forte in diritto).

Un posto particolare è occupato dalle **norme iterate**.

- A differenza di altre norme secondarie (come l'Art. 15 delle Preleggi) che pongono limiti formali (come il tempo), le norme iterate partono dal **contenuto** delle norme.
- **Schema:** Sono norme che "proibiscono di comandare" (es. Art. 27 Cost. che non ammette la pena di morte) o che "comandano di proibire" (es. Art. 18 Cost. che vieta le associazioni segrete).
- **Validità:** In questo caso, la validità non dipende dalla forma (se la legge è prima o dopo), ma da **ciò che le leggi dicono**, in base a una "iterazione" di modi deontici. Lo slogan "È vietato vietare" del '68 ne è un esempio.
- **Funzione Inessenziale:** Alcune norme iterate emergono da funzioni inessenziali dell'ordinamento. L'abolizione della pena di morte, per esempio, è il risultato del superamento di una **funzione meramente retributivista** (*ius talionis* - "occhio per occhio, dente per dente"), riflettendo un progresso storico definito, con Hegel, come una "scienza dell'esperienza della coscienza". L'assenza di un divieto costituzionale sulla pena di morte esprimerebbe quindi una condizione di validità sintattica solo possibile e non necessaria.

Un'ipotesi cruciale per la validità sintasseonomica è data dalle **leggi sulla revisione della Costituzione**.

- **Tesi di Alf Ross:** Ross considera queste leggi la **"norma fondamentale"** (*basic norm*) dell'ordinamento, attribuendole il primato del potere costituente. Egli cita l'Articolo 88 della Costituzione danese come esempio.
- **Gerarchia e Paradosso:** La norma di revisione è gerarchicamente superiore alla stessa Costituzione, ponendosi al vertice (e per questo Ross la chiama fondamentale). Tuttavia, essendo essa stessa parte del linguaggio costituzionale e una **norma posta** (non presupposta), sorgono quesiti:
  - **Problema della Riforma:** Come può la norma suprema di revisione essere revisionata? L'eventuale modifica dell'Art. 88 (o equivalente) implicherebbe una norma capace di emendare se stessa, generando un **paradosso**simile a quello del **"mentitore"** ("Questo enunciato è falso"). Sul piano deontico, la modifica implicherebbe un comando paradossale: "Questo enunciato deve essere inefficace", che necessita al contempo di essere efficace.
  - **Critica a Ross:** Si pone la questione se una norma posta (non presupposta) possa davvero essere definita "fondamentale", dato che le sue condizioni di validità sembrano dipendere da principi ultimi dell'ordinamento che la precedono. Il paradosso si risolverebbe reintegrando la *Grundnorm* kelseniana al di sopra della norma di revisione.

Le leggi di revisione costituzionale **non sono universali**; non esistono nelle Costituzioni "flessibili" (come lo Statuto Albertino del 1848) che non prevedono un procedimento aggravato per la modifica. L'Articolo 88 danese o l'Articolo 138 italiano sono norme **solo possibili e non necessarie**, che scaturiscono dalla **struttura rigida** e inessenziale (non universale) delle rispettive carte costituzionali.

Tutte queste analisi conducono alla necessità di introdurre ciò che è **ultimamente universale e incondizionato**, secondo il principio che "deve necessariamente esservi per ogni serie di condizioni qualcosa d'incondizionato".

Norma fondamentale

Il ragionamento parte dalla constatazione che l'esistenza della **Grundnorm** (Norma fondamentale) al vertice dell'ordinamento è accertata, ma distinguere la sua esistenza dal fondamento della sua validità è cruciale. L'esistenza di qualcosa (come il dubbio stesso o la Norma fondamentale) può essere intuita senza che se ne conosca la base esplicativa.Si sa che la Norma fondamentale esiste, ma non si è ancora chiarito su cosa poggi la sua validità.

Il processo giuridico (*Rechtsverfahren*) per accertare la validità delle norme è di tipo **sillogistico** ed è strettamente collegato allo schema di **produzione normativa** (*Rechtserzeugung*):

1. **Produzione (Creazione):** Affinché una norma sia valida, richiede un atto di creazione che deve essere qualificato da una **norma di competenza di grado superiore**. Questa norma superiore oggettiva il significato giuridico dell'atto e conferisce il potere di produrre la norma inferiore. La norma inferiore non può esistere senza quella superiore.
2. **Accertamento (Riconoscimento della Validità):** Il percorso per riconoscere la validità è inverso, seguendo un modello sillogistico:
    - **Premessa Maggiore:** Contiene la norma di grado superiore. (Es.: "Sono valide tutte le sentenze conformi all'art. 102 della Costituzione").
    - **Premessa Minore:** Afferma la conformità della norma inferiore alla superiore. (Es.: "La sentenza x è conforme all'art. 102 della Costituzione").
    - **Conclusione:** Afferma la validità della norma inferiore. (Es.: "La sentenza x è valida").

Regredendo in questo modo da norma a norma, e da premessa a premessa, si giunge alla **Norma fondamentale**. Essa presenta **condizioni particolari** di accertamento della validità che la distinguono dalle altre norme dell'ordinamento:

1. È **impossibile** che figuri, senza contraddirsi, come conclusione del sillogismo di accertamento della validità (non è prodotta da una norma superiore).
2. È **necessario** che sia affermata come **premessa maggiore** al vertice del sillogismo che accerta la validità di tutte le altre norme.
3. La sua validità è **presupposta** (*vorausgesetzt*) e non posta (*gesetzt*) oggettivamente.

Queste condizioni consentono di conoscere l'**esistenza** della Norma fondamentale, ma non risolvono ancora il problema del fondamento della sua validità. Per rispondere a tale problema e definire un nuovo significato della *Grundnorm*, verranno introdotti i criteri essenziali di **effettività** e **teoreticità**. Si osserva infine che il passaggio dalla definizione dell'esistenza di qualcosa alla sua definizione *simpliciter* è breve.

Il punto di partenza è un argomento paradossale: si sostiene che la **Norma fondamentale** (*Grundnorm*) **non sia né valida né invalida**. Questo deriva dalla necessità di affermare la sua validità al vertice dell'ordinamento, unita all'impossibilità di predicare di essa la validità come per le altre norme. La validità risulterebbe quindi contemporaneamente necessaria e impossibile.

Questa tesi si basa sulla **"theory of types"** di Whitehead e Russell (dai *Principia Mathematica*):

> *Qualunque cosa implichi tutti gli elementi di una collezione non deve essere, a sua volta, un elemento di quella collezione.*

Applicando questo principio: la Norma fondamentale, implicando tutti gli elementi (le norme) della collezione di cui predica la validità, **non può essere a sua volta un elemento** di quella collezione, cioè non può essere una norma di cui si predica la validità.

Viene utilizzato l'esempio del **metro campione** per illustrare il concetto:

- Il metro campione implica tutte le barre che hanno la misura di un metro.
- Per questo, **non è un elemento dell'insieme** delle barre *che hanno* la misura di un metro.
- Esso **è** (e non *ha*) la lunghezza di un metro. Se si accorciasse o allungasse, resterebbe comunque lungo un metro perché resterebbe uguale a se stesso, a differenza delle cose che *hanno* quella misura.
- Allo stesso modo, la Norma fondamentale non può essere detta né valida né invalida, poiché **non esiste un'altra norma** che ne stabilisca la validità.

In caso di rivoluzione, ad esempio, molte leggi cambiano, ma la Norma fondamentale rimane invariata, esprimendo sempre la regola che "ci si deve comportare secondo l'ordinamento effettivamente statuito ed efficace". La sua validità non si accresce né diminuisce.

Si solleva una critica: il fatto che qualcosa sia al principio di qualcos'altro non significa che sia totalmente privo di una **condizione specifica (*secundum quid*) di esistenza**. Una validità diversa da quella che si predica *grazie* a essa può comunque esserle attribuita. "Valido" è ciò che esiste specificamente in base a un criterio di oggettività. La domanda non è se la Norma fondamentale esista, ma **che tipo di esistenza** essa abbia.

Tornando all'esempio del metro campione:

- Ha **esistenza *simpliciter*** rispetto a ogni ordine metrico-decimale di misura (per questo "è" un metro).
- Ha **esistenza *secundum quid*** in quanto è specificamente un criterio di misurazione, e non un altro oggetto (ad esempio, una mazza da baseball).

Citando Wittgenstein sull'Urmeter di Parigi: non si può affermare né negare che sia lungo un metro; questa è la caratterizzazione della sua **funzione particolare nel "gioco del misurare"**. Non esiste un'unità che lo misuri dall'esterno, ma esiste una **regola** che determina oggettivamente la sua funzione specifica come criterio di misurazione. Questa è la base dei fatti istituzionali, che nascono con regole valide solo all'interno del sistema a cui appartengono.

La stessa considerazione si applica alla validità della Norma fondamentale:

- Possiede **esistenza *simpliciter*** rispetto a ogni ordine di validità interno (non è valida in virtù di una norma superiore).
- Mantiene la sua **esistenza *secundum quid*** ed è sottoposta a una **precisa condizione di verifica**.

Proprio come per il metro campione esiste una regola per distinguerlo da altri oggetti, anche per la *Grundnorm* occorre identificare **che cosa la distingua** dagli altri oggetti e la renda un dovere giuridicamente fondato. La questione della sua validità ruota attorno a queste domande e richiede

l'identificazione di **criteri ulteriori** per identificarla, che verranno discussi come il **criterio di effettività** e quello di **teoreticità**.

L'analisi si concentra sul criterio di **effettività** per la Norma fondamentale (*Grundnorm*).

Nel caso dell'unità di misura metrico-decimale, l'elemento decisivo è il **comportamento convenzionale** di coloro che accettano di seguire l'unità di misura rappresentata dalla barra di platino-iridio depositata a Sèvres.

Per la Norma fondamentale di un particolare ordinamento giuridico (ad esempio, quello italiano), l'elemento determinante è l'**effettivo comportamento delle donne e degli uomini (i cittadini) ai quali l'ordinamento si riferisce**. Questo effettivo comportamento deve essere considerato un **fenomeno originario**, e si può semplicemente affermare che "Si gioca questo gioco linguistico".

Se un certo ordinamento è effettivo, la norma che impone di obbedire alla Costituzione effettivamente statuita ed efficace acquisisce **senso giuridico**.

Si riconosce la complessità dei dati da osservare, in quanto i comportamenti (obbedienza e disobbedienza) dei destinatari dell'ordinamento sono motivati e non sono sempre osservabili come semplici eventi naturali.

Viene citato un esempio: in caso di occupazione temporanea di un territorio da parte di un nemico, la perdita di effettività del potere costituito non determina immediatamente l'invalidità della Norma fondamentale sottostante.

Tuttavia, il focus non è su quale sia il fatto decisivo per la validità in sé, ma sulla **stretta relazione di dipendenza** tra la **validità** di un ordinamento giuridico e l'**esistenza di un fatto determinato**, cioè "l'effettivo comportamento delle donne e degli uomini ai quali si riferisce l'ordinamento giuridico".

Viene ribadito che:

> *La validità di un ordinamento giuridico, il quale regola il comportamento di determinati uomini, si trova pertanto in un sicuro rapporto di dipendenza con il fatto che il comportamento reale di questi uomini corrisponde all'ordinamento giuridico o (come si suole anche dire) con l'efficacia dell'ordinamento stesso.*

In conclusione, anche della Norma fondamentale si può affermare che è **valida o invalida**. La validità della *Grundnorm* è il risultato di un **fatto particolare**: l'effettivo comportamento dei destinatari della norma, che è l'efficacia dell'ordinamento stesso di cui essa è la Norma fondamentale.

L'altra prospettiva sulla validità della Norma fondamentale (*Grundnorm*) ha **implicazioni prevalentemente teoriche** ed è basata sul principio di **teoreticità**.

La Norma fondamentale è considerata valida per l'**oggettività** di ciò che stabilisce. Si passa dal suo significato storico-concreto, limitato a un particolare ordinamento, a un **principio generale e astratto** che non si limita a imporre l'obbedienza a uno specifico ordinamento, ma stabilisce che **"ci si deve comportare secondo la Costituzione effettivamente statuita ed efficace"**, qualunque essa sia.

La **teoreticità** di questo principio risiede nella sua **deducibilità dall'idea stessa di ogni Costituzione o ordinamento**.

- Un comando impone sempre il proprio adempimento.
- Allo stesso modo, un ordinamento impone sempre il proprio adempimento.
- Un comando che imponesse la propria inosservanza risulterebbe nullo perché **contraddittorio**.
- Un ordinamento che non includesse l'obbligo fondamentale di obbedienza **non sarebbe realmente un ordinamento** a causa di una contraddizione interna.

Il senso profondo è quello di una vera e propria **tautologia**: un ordinamento vigente è un ordinamento vigente, indipendentemente dal nome del particolare sistema. Si può anche formulare come: "un ordinamento vigente deve essere un ordinamento vigente", seguendo l'idea che affermare "A è uguale ad A" è come affermare "A deve essere uguale ad A".

Lo stesso significato oggettivo si riflette nella **norma di chiusura dell'ordinamento**: "Sono valide tutte e sole le norme dell'ordinamento, nessun'altra norma è valida".

La necessità di questa chiusura è legata al **principio di identità e non-contraddizione**:

1. Non esistono norme al di fuori dell'ordinamento; l'ordinamento è la totalità delle norme valide.
2. Dichiarare il contrario equivarrebbe ad ammettere in modo contraddittorio che l'ordinamento non è l'ordinamento.

Si stabiliscono due uniche possibilità (*tertium non datur*): o l'ordinamento è effettivamente tale (e quindi non vi sono norme esterne valide), oppure le norme esterne non sono valide (e quindi non sono norme). La totalità delle norme determina, per conseguenza, ciò che norma non è.

In ultima analisi, anche della Norma fondamentale **è predicabile la validità**. Tale validità consiste nel significato di una **proposizione logica** la cui negazione sfocia fatalmente in un discorso **contraddittorio**.

Si tratterebbe della medesima contraddizione che si avrebbe affermando che l'ordinamento non è l'ordinamento, o che l'ordinamento vigente, in quanto tale, non è vigente. Non si tratta, inoltre, di un inutile raddoppiamento di una norma che imponga di obbedire all'ordinamento vigente (ossia a quello al quale si deve già obbedire). In gioco c'è la **questione della validità dell'ordinamento**.

Se non fosse così, rimarrebbero solo dei semplici fatti, privi di ogni fondamento di dovere. Risulterebbe alquanto anomalo che un giudice, interrogato sulla ragione per cui segua la Costituzione, rispondesse affermando che non la segue perché giuridicamente valida, ma esclusivamente perché lui e i suoi colleghi la accettano e la praticano come mero fatto, senza ulteriori implicazioni.

Il punto di partenza è un apparente paradosso generato dall'unione delle due soluzioni proposte per la validità della Norma fondamentale (*Grundnorm*):

1. **Effettività:** La validità è il risultato di un **fatto particolare o semplicemente possibile** (comportamento effettivo dei destinatari).
2. **Teoreticità:** La validità è il **significato necessario** di una proposizione logica (tautologia).

Sembra esserci una contraddizione: se la validità è solo possibile, non può essere necessaria; se è necessaria, non può essere solo possibile. Inoltre, se fosse possibilmente valida, sarebbe anche possibilmente invalida, cosa esclusa dalla natura logica necessaria della sua validità.

In realtà, possibilità e necessità sono interconnesse. Viene fatto l'esempio del gioco degli scacchi:

- La regola che l'alfiere muova solo in diagonale fissa un **giudizio ipotetico necessario** ("Se il giocatore muove l'alfiere, lo farà **necessariamente** in diagonale").
- La **necessità** è il contenuto astratto della regola.
- La **possibilità** è il suo effettivo realizzarsi nella pratica del gioco.
- In questo senso, ciò che è necessario è anche possibile. La necessità attende la possibilità, come uno stretto attende il passaggio delle navi.

Tuttavia, il problema non è solo derivare i fatti possibili dal necessario, ma anche il contrario: **derivare la necessità dai fatti solo possibili**.

Se si considera la validità della Costituzione effettivamente statuita ed efficace (la prima norma), il dovere di obbedire al potere costituente non può derivare semplicemente dal fatto che il decreto luogotenenziale del 25 giugno 1944 sia stato realmente effettivo in Italia (la seconda norma, particolare).

Al contrario, la prima norma (quella che prescrive di obbedire alla Costituzione effettivamente statuita ed efficace) **è valida in sé necessariamente**, ed è per questo motivo che la seconda norma (il decreto luogotenenziale specifico) è risultata valida.

- La norma corrispondente al decreto del '44 è valida, ma **non è in sé necessaria** (poteva anche non esserlo, o la Costituzione poteva avere un'origine diversa).
- La norma che fissa il dovere di comportarsi secondo la Costituzione effettivamente statuita ed efficace è **in sé necessaria**.

Questa differenza tra la validità necessaria e quella solo possibile (o contingente) deve essere considerata nel discutere la validità della Norma fondamentale. È contraddittorio sostenere che la validità della Norma fondamentale sia necessaria e solo possibile **contemporaneamente e secondo il medesimo aspetto**.

Le due soluzioni (effettività e teoreticità) non sono in opposizione. La validità della Norma fondamentale presenta predicati tra loro opposti (**necessario vs. possibile**, **universale vs. particolare**), ma si riferiscono a **significati differenti**della Norma fondamentale stessa. I predicati non si riferiscono allo stesso soggetto.

La validità della Norma fondamentale è, dunque, **necessaria e non necessaria (solo possibile) ma non secondo il medesimo rispetto**. Esistono, infatti, **almeno due significati** della Norma fondamentale.

Il primo significato della Norma fondamentale si riferisce alla norma di un **ordinamento giuridico particolare** (ad esempio, l'ordinamento italiano) e si enuncia:

> "Ci si deve comportare secondo R- la Costituzione effettivamente statuita ed efficace".

In questa formulazione, la lettera 'R' sta per la Costituzione di uno specifico ordinamento giuridico.

Questo significato corrisponde, nell'esempio dei giochi, all'**attuarsi storico-concreto** delle regole astratte del gioco attraverso le singole mosse dei giocatori.

Il movimento in diagonale dell'alfiere, per esempio, è un **fatto solo possibile** (il giocatore non è obbligato a muovere l'alfiere) che si fonda sulla regola tecnica **necessaria**: "Se vuoi muovere l'alfiere, devi farlo in diagonale". Di conseguenza, se il giocatore decide di muovere l'alfiere, è obbligato a farlo solo in diagonale.

Il secondo significato introduce la Norma fondamentale come **schema o forma logico-giuridica** che condiziona la validità di **ogni** ordinamento giuridico, enunciandosi:

> "Ci si deve comportare secondo la Costituzione effettivamente statuita ed efficace".

Questa Norma fondamentale **non è più la norma di un particolare ordinamento** (come quello italiano), ma ha un'esistenza **astratta**, simile alle regole del gioco che sussistono indipendentemente dalle azioni concrete dei giocatori.

Per tale motivo, la sua esistenza **non dipende dall'attuarsi storico-concreto** di un ordinamento specifico. Essa è **sempre valida**, analogamente all'idea stessa di ordinamento.

I criteri di effettività e teoreticità stabiliscono i due significati della validità della Norma fondamentale (*Grundnorm*):

L'**effettività** è il criterio di validità per la Norma fondamentale di un **determinato ordinamento** (ad esempio, l'ordinamento italiano).

Non è possibile dedurre l'ordinamento italiano dalla semplice idea astratta di ordinamento, così come non si può dedurre la circostanza di avere cento euro in tasca dalla sola idea di cento euro. È necessaria l'**esistenza di un fatto** accertabile tramite l'esperienza.

La Norma fondamentale di un ordinamento specifico è la conseguenza diretta di questo fatto e si basa sul **giudizio ipotetico**: "Se c'è l'ordinamento x, ci deve essere anche la relativa norma fondamentale".

A decidere la validità della Norma fondamentale di un particolare ordinamento è, pertanto, l'**effettività dell'ordinamento stesso**, vale a dire il fatto che i destinatari vi **obbediscano realmente**. Senza questa effettività (ossia senza l'esistenza concreta di tutte le norme e i comportamenti), non esisterebbe la Norma fondamentale specifica dell'ordinamento in questione.

L'idea di **teoreticità** riveste la Norma fondamentale come **schema o forma logico-giuridica** che condiziona la validità di **ogni** ordinamento giuridico.

In questo caso, l'esistenza della *Grundnorm* non è determinata da fatti esterni e concreti, ma è sufficiente il **concetto astratto di ordinamento**. Posta su questo piano logico e concettuale, la *Grundnorm* è **sempre valida**.

Regole ed eide[13]

La soluzione al problema della validità ha reso necessario **disambiguare il significato di "norma fondamentale"**. L'approfondimento del concetto procederà ora attraverso la lente della **teoria delle "regole costitutive"**. In particolare, si analizzerà il significato della *Grundnorm* come **"regola eidetico-costitutiva"**.

Le regole **"eidetico-costitutive"** sono definite come quelle che operano da **condizioni necessarie** sia per la **pensabilità**sia per la **possibilità** di ciò a cui si riferiscono.

Un esempio paradigmatico è costituito dalle regole di un gioco, in particolare il gioco degli scacchi e le sue unità (*praxemi*, che includono pezzi, *pragmemi* e *status iudici*).

Il gioco degli scacchi, insieme ai suoi *praxemi*, **non è nemmeno pensabile senza le sue regole**. L'idea del gioco, infatti, non preesiste alle regole, né sussiste indipendentemente da esse. Allo stesso modo, il gioco non può esistere se è totalmente privo di regole.

A conferma di ciò, nelle *Ricerche filosofiche* di Wittgenstein si afferma che:

> *Il gioco degli scacchi è il gioco che è in virtù di tutte le sue regole.*

Il gioco esiste grazie alle sue regole. Attraverso una domanda retorica, Wittgenstein conferma che le regole del gioco sono ciò che **definisce** il gioco degli scacchi, sottolineando che il gioco non è pensabile senza di esse.

La Norma fondamentale è considerata una **regola eidetico-costitutiva** in quanto funge da causa necessaria sia della pensabilità, sia dell'esistenza di due oggetti principali: **l'ordinamento** e l'**insieme dei fenomeni giuridici in generale**.

Riferendosi a un argomento di Amedeo G. Conte, si osserva che se la **"norma generale esclusiva"** (quella che qualifica deonticamente indifferente ogni comportamento non qualificato da norme imperative) viene reinterpretata e ridotta alla Norma fondamentale, essa cessa di essere una norma tra le altre. Secondo questa rilettura (*Umdeutung*), la Norma fondamentale diventa la **condizione di possibilità e pensabilità dell'ordinamento in quanto tale**.

Sebbene la norma generale esclusiva non sia strettamente necessaria (si potrebbe concepire un ordinamento in cui una regola non si limiti a connotare come indifferente un comportamento non proibito), in un contesto come lo **"Stato di diritto"**, principi come la tassatività della fattispecie penale e la sottomissione del potere alla legge sono decisivi senza eccezioni.

Ciò che vale per la norma generale esclusiva vale, a maggior ragione, per la *Grundnorm* di Kelsen, in quanto essa non è un principio valido solo per un diritto specifico, ma per l'**ordinamento giuridico in sé**.

[13] Eide Costitutive di Regole ⊦ Regole Eide Costitutive (⊦ derivanti da)

Il secondo oggetto su cui verte la Norma fondamentale sono i **fenomeni giuridici *lato sensu***, ossia l'intera esperienza giuridica, che non è immediatamente riducibile alle sole norme.

Citando Felix Kaufmann, si sostiene che non esistono **"fenomeni giuridici"** (*Rechtsgeschehen, rechtssoziologische Tatsachen*) pre-costituiti e percepibili indipendentemente dalla Norma fondamentale.

- I fenomeni di cui si parla sono i tantissimi **rapporti giuridici** che costituiscono l'esperienza complessiva del diritto, non strettamente traducibili nel codice.
- L'idea che i fatti siano "espressamente previsti" dal Codice penale (come nell'Art. 1) implicherebbe la loro deducibilità dal codice ancor prima di essere compiuti, cosa difficilmente pensabile.

Ogni fatto, anche se inteso nel senso più ampio, possiede una causa più o meno latente nel diritto. Per questo motivo, la Norma fondamentale è **sempre costitutiva sia dell'ordinamento che di tutti i fenomeni giuridici in generale**.

La relazione costitutiva è gerarchica:

- La *Grundnorm* è **costitutiva** rispetto alle singole norme di un ordinamento.
- A loro volta, le singole norme dell'ordinamento sono **costitutive** rispetto ai fenomeni da esso qualificati, in quanto fungono da **schemi trascendentali di interpretazione** (*Deutungsschemata*, termine usato dallo stesso Kelsen).

Il ragionamento propone un'inversione prospettica, partendo dai **due significati della Norma fondamentale**(*Grundnorm*) precedentemente stabiliti, per analizzare come essi reagiscono alla **teoria delle regole eidetico-costitutive**, e se tale teoria sia capace di coprire completamente la nozione di *Grundnorm*.

I due significati della Norma fondamentale sono:

1. **Norma fondamentale particolare:** Principio di validità di uno specifico ordinamento giuridico ("Ci si deve comportare secondo R- la Costituzione effettivamente statuita ed efficace", dove 'R' è la Costituzione particolare).
2. **Norma fondamentale astratta:** Schema o forma logico-giuridica che condiziona la validità di **ogni** ordinamento giuridico ("Ci si deve comportare secondo la Costituzione effettivamente statuita ed efficace", qualunque essa sia).

Si afferma che la Norma fondamentale, intesa come **causa di validità di un determinato ordinamento** (il significato 1), **è senza dubbio una regola eidetico-costitutiva**.

Essa è effettivamente la **condizione necessaria** sia della pensabilità, sia della possibilità:

- delle norme dell'ordinamento di cui 'R' è la Costituzione statuita ed efficace;
- dei fenomeni qualificati dalle norme dello stesso ordinamento.

Si pone la domanda se lo stesso valga per la *Grundnorm* come **schema o forma logico-giuridica** alla base di ogni ordinamento (il significato 2).

Prima di rispondere, si introducono alcune precisazioni sulle regole costitutive in generale:

- **Possibilità vs. Necessità:** Le regole costitutive sono un **fatto solo possibile** e non l'idea in sé necessaria alla base di una serie di fatti possibili. Ad esempio, le regole degli scacchi costituiscono solo uno dei giochi possibili, ma **non l'idea in sé di ludicità** (il "gioco" in generale). Se il gioco degli scacchi non esistesse, l'idea di gioco esisterebbe comunque. L'idea di gioco non dipende dall'esistenza o meno di un gioco specifico e dalle sue regole costitutive.
- **Non sono Proposizioni Logiche Universali:** Le regole costitutive non hanno il significato di proposizioni logiche alla base di ogni entità ludica, né si identificano con le regole che definiscono ciò che è universalmente **"gioco"** e comune a ogni gioco possibile (come la regola che ogni gioco mira a proclamare un vincitore e un vinto, salvo i casi di stallo).
- **Implicazioni Possibili:** Le regole costitutive traducono invece le **implicazioni solo possibili** di regole universali. Il gioco degli scacchi è un'implicazione meramente possibile delle proposizioni logiche del "gioco in quanto tale". Si può affermare che il gioco degli scacchi sia un gioco, ma non il contrario, ossia che il concetto di "gioco in sé" si identifichi semplicemente con un gioco possibile come gli scacchi.

Le considerazioni fatte portano a negare che la Norma fondamentale, intesa come **schema o forma logico-giuridica astratta**, possa essere considerata una regola eidetico-costitutiva *stricto sensu*:

1. La Norma fondamentale come schema logico-giuridico astratto **non è la norma di un determinato ordinamento**; al contrario, è il **presupposto logico** delle norme di ogni ordinamento possibile.
2. La Norma fondamentale come schema logico-giuridico astratto esprime il **significato necessario di una proposizione logica**, la medesima proposizione che definisce l'ordinamento giuridico in sé.

La teoria delle regole eidetico-costitutive **non è in grado di spiegare l'intero fenomeno della Norma fondamentale**:

- Se la Norma fondamentale è vista come **causa di validità di un particolare ordinamento giuridico** (il primo significato), essa è effettivamente una regola eidetico-costitutiva.
- Ma se è vista dalla prospettiva di una **proposizione logica che definisce ogni tipo di ordine giuridico** (il secondo significato), essa cambia ruolo e diventa il **principio da cui tali regole costitutive traggono origine**.

L'esempio dei giochi chiarisce questa distinzione:

- Le regole degli scacchi sono costitutive di un gioco determinato.
- L'idea in sé di gioco non è costituita dalle regole di un gioco particolare; semmai, è l'idea di gioco a **costituire**quelle regole nella forma di un presupposto fondamentale.

Si introduce una terminologia più precisa: le une (le regole degli scacchi) sono **regole eideticamente costitutive**, mentre l'altra (l'idea di gioco) è più propriamente un **"eidos costitutivo" di regole**.

Il discorso per la Norma fondamentale è identico:

1. Come **principio di validità di un ordinamento particolare**, essa esprime il senso di una **regola eidetico-costitutiva**.
2. In veste di **schema o forma logico-giuridica astratta**, essa rappresenta, invece, l'**idea stessa di diritto come ordinamento**.

La prima di queste due regole (quella particolare) **presuppone l'altra** (quella astratta), e la natura del dovere che ne consegue è anch'essa diversa.

I doveri che derivano dalle regole eidetico-costitutive sono doveri propri di un *nómos* (legge o norma) che **dà forma a un *eidos*** (idea).

Questo è esemplificato dalle regole degli scacchi, che conferiscono forma all'idea (*eidos*) specifica del gioco degli scacchi. Tali doveri possono essere chiamati **"doveri eidonomici"** in virtù della forza costitutiva che un *nómos* possiede nel definire un'idea.

Vengono poi i **"doveri eidologici"**, che risalgono direttamente a *eide* (idee) primi e originari, come l'idea in sé di gioco o di ordinamento. Questi doveri sono dettati essenzialmente dal *lógos* (ragione), piuttosto che da un qualche potere costitutivo di regole specifiche.

Tali doveri si manifestano non negli innumerevoli giochi e ordinamenti creati da individui o piccole società, ma soprattutto nei **sentimenti universali** del giocare e del costruire la realtà sociale del diritto, sentimenti connaturati all'essere umano. Tutte le condizioni di *praxeologia* e *sintasseologia* (indagate nei capitoli precedenti) rientrano in questa categoria.

Un esempio che traduce in modo esemplare i doveri eidologici è l'idea hegeliana dei **"giudizi del concetto"** (*Urteile des Begriffs*), sviluppata nella *Scienza della logica*.

- Hegel individua in questi giudizi quelli che hanno per base il **concetto** (*Begriff*). Solo un tale giudizio costituisce un vero e proprio atto giudicativo.
- Predicati come "buono", "cattivo", "vero", "bello" o "giusto" esprimono il confronto tra la cosa e il suo **concetto universale** come un **dover essere assolutamente presupposto**, verificando se la cosa corrisponda o meno a tale concetto.

Un esempio interessante si trova nelle *Ricerche logiche* di Husserl: oltre ai doveri che dipendono dalla volontà, dal desiderio o da un ordine ("Devi obbedirmi!"), esistono **doveri totalmente indipendenti** la cui unica origine è il **concetto**stesso.

Si prenda la proposizione **"Un soldato deve essere valoroso"**:

- Il dovere del soldato di essere valoroso non è il semplice frutto della disposizione del sovrano.
- Appartiene invece all'**idea stessa di soldato**.
- Una prova *ad absurdum* è sufficiente: un sovrano pacifista che cercasse imperativamente di avere un esercito vile rinuncerebbe *de facto* a possedere un esercito.

Anche il concetto di **"legge naturale"** (*loi naturelle*) di Jacques Maritain (*L'uomo e lo Stato*) ha il senso del dovere eidologico. Maritain intende la legge naturale come **"il modo normale in cui una cosa [...] 'deve essere usata', o merita di essere trattata, in accordo con la sua essenza specifica"** (sia che si tratti di un artefatto, una pianta o un uomo).

Maritain cita l'esempio del **genocidio**, che si pone come un fatto incompatibile con l'**idea (*eidos*[14]) stessa di umanità**. Non è pensabile l'umanità senza il divieto del genocidio.

[14] **Eidetico εἶδος:** significa forma o immagine. In psicologia, si riferisce alla capacità di richiamare immagini mentali con un livello di dettaglio straordinariamente nitido e preciso come se si vedesse ancora l'oggetto

Ius publicum

L'ordinamento giuridico è intrinsecamente dotato di un **significato normativo**, fondato sull'esistenza di **norme** (di condotta e di struttura) o **principi** (logici o metaregole, come la norma fondamentale).

La *Grundnorm* è centrale e comporta una **doppia evidenza**:

1. **Esistenza dell'ordinamento:** Ogni singola norma giuridica deve avere almeno un'altra norma di grado superiore che la fonda, culminando nella **Norma Fondamentale**.
2. **Identificazione del senso:** L'ordinamento giuridico è identificabile con un nucleo di senso che è necessariamente **normativo**. Ammettendo l'esistenza stessa di un ordinamento giuridico, ne discende che esista almeno una norma, che è la Norma Fondamentale.

Questa concezione è l'**idea nodale della dottrina normativistica del diritto**, la quale stabilisce che la struttura dell'ordinamento giuridico risiede nell'**elemento della norma**.

Anche adottando una visione **dinamica** che ponesse la **decisione giuridica** al centro anziché la norma, la dimensione normativa dell'ordinamento resterebbe inalterata:

- La decisione, o avrebbe come **risultato** la produzione di norme, oppure non potrebbe che **presupporre** l'esistenza delle norme stesse.
- Il processo decisionale non elimina del tutto la dimensione normativa, la quale è essenziale per salvare l'**oggettività**dell'esistenza dell'ordinamento.
- Senza **norme di competenza** che stabiliscano *chi*, *come* e *quando* si possa decidere, l'attività che ne risulta perderebbe il suo carattere strettamente giuridico.

In sintesi, anche se l'ordinamento è visto come un sistema di decisioni, le norme si trovano sempre o **al termine** o **al principio** di tali decisioni. Nel secondo caso, l'ordinamento implica non solo la Norma Fondamentale ma, verosimilmente, anche altre **norme di struttura** che regolano la validità degli atti di decisione.

Viene utilizzata l'**analogia del gioco** per chiarire il concetto:

- Si afferma che un gioco, ad esempio gli scacchi, esiste ed è definito **in virtù delle sue regole**.
- Similmente, un pezzo del gioco (come il pedone) è "la somma delle regole sulle sue mosse".
- Ogni mossa nel gioco presuppone sempre l'esistenza delle **regole** stesse.

Il testo solleva la questione della **funzione** in rapporto alla **struttura** (che è la norma). L'interrogativo sull'esistenza di "regole di funzione" è però **assente** nella maggior parte della dottrina normativistica, in particolare in Kelsen.

Per **Kelsen**, l'interesse è focalizzato **esclusivamente sulla struttura** dell'ordinamento, mentre le considerazioni sulla funzione sono **deliberatamente omesse**.

A supporto di ciò, viene citato un passaggio dalla prima edizione (1934) della *Dottrina pura del diritto*, dove Kelsen afferma che questa dottrina:

> non prende in considerazione lo scopo che viene perseguito e raggiunto per mezzo dell'ordinamento giuridico, ma considera unicamente l'ordinamento giuridico stesso, e lo fa nell'autonomia intrinseca della sua struttura normativa, senza riferimento al suo scopo e, di conseguenza, senza considerarlo come possibile causa di un determinato effetto.

La questione centrale riguarda l'esistenza di una **funzione essenziale** in relazione alle norme di un **ordinamento giuridico astrattamente considerato**, non di singole norme o specifici ordinamenti.

Il riferimento in questo contesto è il confronto, operato ad esempio da Bobbio, tra la dottrina di Hart e quella di Kelsen riguardo alla **funzione del diritto**:

- **Secondo Hart:** La comprensione dell'ordinamento è possibile solo se non si separa la **struttura** dalla **funzione**.
    - La **struttura** è quella di un sistema di norme, composto da norme primarie e secondarie.
    - La **funzione** consiste principalmente nell'**efficacia** di tale sistema, cioè nella sua capacità di produrre effetti a partire dal **riconoscimento** da parte dei suoi destinatari.
- **Secondo Kelsen:** La sua analisi strutturale è nettamente **separata** da quella funzionale, e anzi, la prima tende a **escludere** la seconda. Il diritto è considerato solamente per la sua struttura, identificato come un **"meccanismo coattivo"** formato essenzialmente da norme prescrittivo-sanzionatorie.

La rilevanza della funzione porta a interrogarsi anche sul suo carattere più o meno **variabile**.

In certi casi, una **stessa funzione** può generare **meccanismi normativi differenti**, chiamati **"equifunzionali"**. Ciò significa che la funzione rimane invariata, ma mutano i mezzi per attuarla, a seconda di presupposti sociali diversi.

- **Esempio:** La funzione della **certezza del diritto** può essere realizzata in modi diversi:
    - Nel sistema di *civil law*, tramite il principio "*Nullum crimen sine lege*" (che presuppone l'affidabilità del legislatore).
    - Nel sistema di *common law* anglosassone, tramite l'istituto della **giuria** (che presuppone l'omogeneità della giuria stessa).

In molti altri casi, è la **funzione** stessa ad apparire come un **elemento mutevole** del sistema, come si osserva nei cambiamenti profondi di istituti giuridici fondamentali.

- **Esempio della Proprietà:** Lo sviluppo delle società per azioni ha in parte separato la **proprietà** dal **controllo della ricchezza**. Gli amministratori sono distinti dai proprietari di capitale; chi detiene la ricchezza non la gestisce e viceversa.
- Questo ha portato all'inaugurazione della **funzione sociale della proprietà** con il principio dell'impresa in sé (*Unternehmen an sich*).
- L'**interesse privatistico** del singolo capitalista viene superato dall'**interesse generale** a migliorare beni e servizi (come nell'esempio di una società di navigazione che opera per far navigare i battelli, e non primariamente per dividere gli utili tra gli azionisti).

Nonostante la variabilità, rimane la domanda su quale sia la **funzione essenziale**.

Il testo si conclude citando un passo del dialogo *Cratilo* di **Platone**, che pone una domanda sulla finalità intrinseca:

> Si osservi a cosa guarda il legislatore, quando attribuisce i nomi alle cose. E si rifletta su questo: a cosa guarda il falegname, quando costruisce la spola? Non forse a **qualcosa di siffatto che sia per natura atto a tessere**?

Questo paragone suggerisce che, come ogni artefice, anche il legislatore (colui che crea le norme) agisce guardando a una **finalità** o **funzione** intrinseca.

Si afferma che il concetto di **Norma Fondamentale** (Grundnorm) elaborato da Kelsen non è sufficiente a fornire una spiegazione della **funzione** dell'ordinamento giuridico.

Si propone, invece, che un significato diverso e più promettente possa essere trovato nella **"formula trascendentale del diritto pubblico"** (*transzendentale Formel des öffentlichen Rechts*) di Immanuel Kant, contenuta nell'opera *Per la pace perpetua* (*Zum ewigen Frieden*, 1796).

Il principio fondamentale di questa formula è che tutte le azioni che riguardano il **diritto degli altri uomini** devono presupporre **doveri** che siano compatibili con la **forma della pubblicità** (*Öffentlichkeit*).

L'obiettivo è quindi quello di ricostruire il contenuto di questa formula kantiana, adottando come chiave di lettura il criterio della **validità sintattica**.

Prima alcune premesse

Si concorda con Hart nell'identificare la **funzione essenziale** dell'ordinamento giuridico nella sua **efficacia**, che consiste nell'essere **riconosciuto e obbedito** dai suoi destinatari.

La legge svolge la sua funzione unicamente quando viene **applicata**; in caso contrario, essa rischia di confondersi con un qualsiasi altro tipo di discorso.

- I discorsi comuni mirano solo ad essere **compresi**.
- Le leggi, al contrario, necessitano di essere **osservate** (eseguite).

Viene posta una domanda retorica sul senso di una regola che non fosse mai eseguibile o che fosse completamente indifferente ai suoi effetti: una tale norma finirebbe per **disfarsi** (annullarsi).

Per comprendere lo "spirito della legge" e il suo scopo (a cosa mira), è necessario soffermarsi sul **punto di vista dei destinatari**.

Si evidenzia che una legge è tanto più osservata quanto maggiore è il suo livello di **giustizia**.

Sulla base di queste considerazioni (efficacia e giustizia dal punto di vista dei destinatari), si intende procedere con la ricostruzione del discorso kantiano sulla **Pubblicità** (*Öffentlichkeit*).

Prima di analizzare la tesi di Kant, è necessaria un'ulteriore premessa sul ruolo estremamente ampio della **pubblicità** nel diritto.

La pubblicità ottiene un effetto **costitutivo di fatti giuridici** in senso lato, agendo su tre distinti livelli:

1. **L'esistenza stessa dei fatti** (efficacia costitutiva).
2. **La prova della loro esistenza** (efficacia probatoria).
3. **L'accertamento del loro valore** (giudizi di valore).

Il passaggio che porta alla terza relazione (giudizi di valore) è particolarmente significativo per il metodo della scienza giuridica e per l'idea di Norma Fondamentale.

Alcuni fatti giuridici, per poter esistere ed avere effetti, necessitano della pubblicità.

- **Esempio 1: Testamenti.** Senza la sua **pubblicazione** (artt. 620 e 621 del Codice civile), un testamento olografo o segreto è *tamquam non esset* (come se non esistesse), ovvero privo di effetti giuridici.
- **Esempio 2: Leggi e Sentenze.** La **pubblicazione delle leggi** le rende normativamente operanti (art. 73 Cost. e art. 10 Preleggi). Similmente, la **pubblicazione delle sentenze** le perfeziona, rendendole irretrattabili (art. 472 c.p.p.; artt. 133, 429, 430 c.p.c.).
- **Esempio 3: Stato Civile.** Sebbene in genere la pubblicità non sia costitutiva della personalità giuridica, l'**iscrizione dell'atto di matrimonio** nei pubblici registri è ciò che determina effettivamente lo *status* di coniuge.

Altri fatti utilizzano la pubblicità per essere **provati**, rafforzando così la loro oggettività. In questo caso, la pubblicità è costitutiva non tanto dei fatti in sé, quanto dei **giudizi di fatto** che ne attestano l'accadimento.

- **Esempio:** La **registrazione dell'atto di nascita** non è la causa della nascita, ma ha efficacia probatoria relativa all'avvenuta nascita e, di conseguenza, all'acquisizione della personalità giuridica.
- La pubblicità in questo senso rende possibile affermare che "il fatto è realmente accaduto" (costitutiva di giudizi).
- **Esempio storico:** Nel diritto romano, il ruolo dei **testimoni** nella *mancipatio* (compravendita reale) o la presenza del **magistrato** nella *in iure cessio* servivano non a far sorgere il rapporto sinallagmatico in sé, ma ad **assicurarne l'evidenza** e creare certezza dei fatti per i privati terzi.

Infine, la pubblicità, oltre ad essere costitutiva di fatti o di giudizi di fatto, è anche all'origine di **giudizi di valore**. Questo è il passaggio ritenuto il più importante, in quanto condurrà all'analisi della formula kantiana contenuta nella seconda appendice di *Per la pace perpetua*.

La formula kantiana è: *"Alle auf das Recht anderer Menschen bezogene Handlungen, deren Maxime sich nicht mit der Publizität verträgt, sind unrecht."* (Tutte le azioni concernenti il diritto di altri uomini, la cui massima non sia compatibile con la pubblicità, sono ingiuste).

Questo principio è definito da Kant come **"trascendentale del diritto pubblico"**. Dal punto di vista della validità sintattica, esso rappresenta una **metaregola fondamentale** sulla funzione essenziale del diritto.

La formula comprende tre caratteri essenziali:

1. Le norme devono possedere il requisito della **pubblicità** (*Öffentlichkeit*) per raggiungere il loro significato giuridico più oggettivo.
2. La forma della pubblicità è valida solo se mantiene inalterata la funzione di **efficacia** del diritto; altrimenti, degenera in un mero fenomeno di forza.
3. Possono possedere la forma della *Öffentlichkeit* solo le norme dotate di **giustizia**.

Il valore **"trascendentale"** del principio deriva dal fatto che esso è ottenuto prescindendo da qualsiasi situazione empirica particolare, basandosi unicamente su un'**idea *a priori*** della ragione: **non ci può essere legalità senza pubblicità.**

- La pubblicità è una condizione minima di validità: è alle leggi come l'estensione ad una figura geometrica o come le forme di spazio e tempo alla percezione degli oggetti.
- Perché le leggi abbiano vita, devono essere **note ai destinatari**. La ragione, indipendentemente dall'esperienza, fissa rigorosamente il nesso tra pubblicità e leggi.

Kant afferma che ogni pretesa giuridica deve avere questo carattere di pubblicità; essa funge da criterio rintracciabile *a priori* nella ragione, un **"esperimento della ragion pura"** per riconoscere immediatamente la falsità[15] (contro-giuridicità[16]) di una pretesa. Una pretesa del tutto incapace di essere pubblica è considerata "falsa", nel senso che non sarebbe nemmeno in grado di nascere.

Le leggi esistono se si rivestono immediatamente di un **fatto pubblico**. Ciò significa che non basta che siano note ai legislatori, ma devono **uscire allo scoperto** e giungere ai destinatari, in modo che la loro validità sia anche **"validità da parte dei destinatari"** (*Existentialgeltung auf Seiten der Adressaten*).

Non è sufficiente trasmettere obblighi e divieti (cosa che fa anche il tiranno); è necessario che tali obblighi siano **accettati da tutti**, sebbene con diversi gradi. È più preciso dire che le leggi devono essere **pubblicizzabili**, affinché i destinatari, una volta a conoscenza, le **facciano proprie** e non le respingano.

La pubblicità delle leggi non avrebbe senso se scatenasse l'opposizione radicale, né se non mirasse a conservare ciò che intende rendere pubblico. La prima funzione delle norme è che i destinatari le **riconoscano**. Il concetto kantiano di una ragione pubblica del diritto è affine al principio habermasiano della "verifica di un pubblico riscatto" del discorso comunicativo.

A riprova di ciò, il testo evidenzia l'incongruenza di atti legislativi contrari al criterio della *Öffentlichkeit*, anche per motivi di sicurezza nazionale (come l'approvazione segreta delle "regole di ingaggio" per la difesa aerea in Italia nel 2004 o il *Luftsicherheitsgesetz* tedesco del 2005).

Il fatto che la Corte Costituzionale tedesca abbia dichiarato incostituzionale il *Luftsicherheitsgesetz* nel 2006 (basandosi sulla dignità umana e la tutela dell'innocente) dimostra come la **giustizia costituzionale** sia cruciale per comprendere il senso pubblico del diritto.

Le leggi non richiedono solo di essere notificate, ma di verificare tramite la ragione il grado di **riconoscimento**(*Anerkennung*) da parte dei destinatari. Il segreto non è l'opposto del pubblico, ma se la sicurezza dello Stato impone il segreto, il legislatore deve comunque chiedersi internamente quale possibilità avrebbero le sue disposizioni di essere accettate se fossero rese pubbliche.

[15] **falsch:** falsità ontica
[16] **rechtswidrigkeit:** antigiuridicità o illiceità

La pubblicità è al contempo il **risultato di un processo di astrazione** e la **regola** che svela la funzione delle norme, determinando quali norme avranno efficacia e quale sarà il loro grado effettivo di operare.

Kant afferma che: *"Alle Maximen, die der Publizität bedürfen (um ihren Zweck nicht zu verfehlen), stimmen mit Recht und Politik vereingt zusammen."* (Tutte le massime che, per non fallire nel loro scopo, hanno bisogno di pubblicità, si accordano con il diritto e con la politica uniti).

- Una legge destinata all'inevitabile fallimento non sarebbe davvero una legge, né avrebbe carattere giuridico.
- Il principio di **pubblicizzabilità** accerta tale risultato *a priori*, senza attendere l'esperienza.
- La ragione risponde alla domanda sull'efficacia di una norma chiedendosi: "Che cosa accadrebbe se la stessa norma fosse resa pubblica?".

La pubblicità è necessaria affinché le leggi realizzino la loro funzione. Posto che la funzione sia accessibile solo mediante la pubblicità, ne consegue che solo le leggi che si accordano con il **"diritto del pubblico"** (*Recht des Publikums*) potranno rispondere al loro fine.

In definitiva, al diritto corrispondono solo le leggi conformi alla pubblicità. La *Öffentlichkeit* funge da **mezzo** tra il diritto e il suo scopo.

L'ultimo aspetto cruciale è il nesso fondamentale tra **pubblicità e moralità/giustizia** delle leggi, che congiunge la pubblicità a un principio sia giuridico che etico.

Kant spiega che una massima che non si possa rendere pubblica senza al contempo vanificare il proprio scopo (perché provocherebbe l'inevitabile resistenza universale) può generare una reazione di tutti solo a causa dell'**ingiustizia**(*Ungerechtigkeit*) di cui li minaccia.

- Questa reazione, essendo necessaria e universale, è comprensibile *a priori*.
- La forma della pubblicità è implicita in ogni pretesa che voglia essere giuridica, così come le è implicito un carattere essenziale di **giustizia**.
- **Senza la forma della pubblicità non ci sarebbe giustizia** (che può essere concepita solo come pubblicamente conoscibile), e di conseguenza neanche il diritto.

Ogni pretesa è giusta se è **pubblicizzabile**; viceversa, le pretese non pubblicizzabili sono tali proprio a causa della loro ingiustizia. La pubblicità è efficace nel rendere inefficace un progetto illegittimo che provocherebbe la resistenza di tutti.

- L'ingiustizia, quindi, rende impossibile la pubblicità e impedisce al diritto di manifestarsi.
- Al contrario, **"una legge pubblica che determini per tutti cosa sia loro permesso o vietato è l'atto di una volontà pubblica dal quale proviene ogni diritto, e che perciò non può recare ingiustizia a nessuno."**

Esempi Internazionali

Kant fornisce esempi nel dominio delle relazioni internazionali per illustrare il concetto:

1. Una norma che ammetta per uno Stato di non rispettare la parola data agli altri Stati (venir meno ai patti) è **ingiusta** (*unrecht*). Se uno Stato la rendesse pubblica, gli altri Stati lo

isolerebbero o si unirebbero per resistere, dimostrando che la politica in base a questo principio vanificherebbe il proprio scopo.
    - Negare il dovere di stare ai patti è impossibile anche per un popolo di diavoli dotati di ragione, poiché ciò contraddice l'idea stessa di accordo per ogni essere razionale.
2. Non sarebbe concepibile la norma che autorizzi uno Stato ad attaccarne un altro senza aver subito offesa.
3. La pubblicità renderebbe inattuabile la massima che permetta a uno Stato più grande di assoggettarne e annetterne senza ragione uno più piccolo.

Questi presupposti kantiani mettono in luce il problema giuridico fondamentale di azioni militari come quelle contro l'Iraq nel 2003 (senza autorizzazione ONU e basate su presunte violazioni prive di fondamento) o l'intervento NATO in Jugoslavia nel 1999 (anch'esso privo di approvazione del Consiglio di Sicurezza). L'idea kantiana della pace dimostra che non è possibile attuare la pace fra i popoli adottando soluzioni precarie o iniziative parziali al di fuori di una **cornice pubblica del diritto**. La *Öffentlichkeit* è la **linfa vitale del diritto** in quanto ne assicura la **giustizia**.

L'esempio della lealtà tra Stati funge da richiamo a un caso di **"dovere perfetto"** (*vollkommene Pflicht*) discusso nella *Fondazione della metafisica dei costumi*, che riguarda la figura di un uomo bisognoso che prende in prestito denaro promettendo la restituzione, pur sapendo che non lo farà mai.

La massima di questa azione (*"Quando credo di aver bisogno di denaro, ne prendo a prestito promettendo di restituirlo, benché sappia che non lo farò mai"*) non può diventare **legge universale** (*Verallgemeinerung*).

- Per Kant, tale universalizzazione è impossibile, poiché annullerebbe l'esistenza stessa della promessa.
- L'universalizzabilità delle massime è lo schema attraverso cui l'**Imperativo Categorico** (che comanda di agire secondo massime che possano valere come legge universale) esprime l'idea di **giustizia**.
- Le massime che non sono universalizzabili sono **ingiuste**, e lo sono proprio a causa della loro non universalizzabilità.

Esiste una chiara differenza tra il caso della *Pace perpetua* (basato sulla **pubblicizzabilità** - *Publizität*) e quello della *Fondazione* (basato sull'**universalizzabilità** - *Allgemeinheit*).

Questa discrepanza investe le due dottrine kantiane del **"diritto"** (*Rechtslehre*) e della **"virtù"** (*Tugendlehre*), le quali si distinguono non tanto per il contenuto dei doveri, ma per il modo in cui il soggetto si relaziona alla legge:

Dottrina	Carattere Primario	Oggetto Principale
Dovere Morale (Virtù)	**Interno**	L'intenzione o la forza della legge in sé.
Dovere Giuridico (Diritto)	**Esterno**	L'azione esterna o la condotta.

- Un dovere, come quello di adempiere un contratto, è sia giuridico che etico. Tuttavia, il dovere di compiere quell'azione in forza del **valore intrinseco della legge** è un presupposto primariamente **morale** (interno).
- Per l'agire giuridico, al contrario, conta l'**azione esterna**.
- L'agire giuridico è quindi doverosamente **esterno** (o solo in parte interno), mentre l'agire morale è doverosamente **interno** (o solo in parte esterno).

Ciò spiega perché la **pubblicità** delle massime sia la **forma ideale della legislazione**: essa traduce in pratica un tratto specifico del diritto, ossia la **natura esterna dei fatti giuridici**.

Vi è, inoltre, l'ineludibile impronta **bilaterale-attributiva** delle norme giuridiche:

- A ogni dovere (obbligo) corrisponde l'**autorizzazione** di un terzo a esercitare i propri diritti (pretesa). **Non c'è obbligo senza pretesa.**
- La pubblicità conferma questa dimensione del diritto: **bilaterale** e non unilaterale, **aperta** e non chiusa, **sociale** e non individuale.
- Le leggi non mirano a realizzare il bene dei soli singoli, ma di **tutta la società**, motivo per cui non possono risiedere unicamente nelle menti dei legislatori.

Viene spiegata l'origine della **Pubblicità** (*Öffentlichkeit*) nel diritto, stabilendo un nesso tra essa e la **giustizia** nel senso kantiano. Questo nesso rivela che la pubblicità è intrinsecamente legata all'**universalità**.

- La distinzione precedente tra i due principi è superata: le leggi sono **pubblicizzabili perché sono anche universalizzabili**.
- I due principi conducono agli **stessi doveri**. La pubblicità è semplicemente la **forma esteriore** dell'universalità.
- La pubblicità implica sempre l'agire secondo massime che possano valere come leggi universali. Ciò che vale per la morale (*universalizzabilità*) vale anche per il diritto (*pubblicizzabilità*).

Si considera l'esempio di una legge "impossibile" (come quella di Fuller che autorizza i membri del Parlamento a commettere crimini senza sanzioni).

- Se considerata come legge universale, essa **negerebbe l'idea stessa di ordinamento** (un sistema totale di soprusi).
- L'impossibilità di elevare una massima del genere a legge universale ne dimostra pienamente l'**ingiustizia**.
- Il fatto che non sia nemmeno pubblicizzabile conferma ulteriormente tale risultato.

Il dato interessante è che da un principio puramente **formale** (la pubblicizzabilità, che non guarda al contenuto), si arriva direttamente alla **giustizia** (la sostanza). Per Kant, questo passaggio dalla forma alla sostanza è una **necessità**.

Affrontando la questione del dovere morale, Kant stabilisce la priorità della **forma** sull'obiettivo o sul fine (*principio materiale*):

- La domanda è se si debba partire dal **fine** (oggetto dell'arbitrio e interesse parziale del soggetto) o da regole che badino alla **forma dell'agire** (il precetto di non cadere in contraddizione).

Kant afferma che la precedenza spetta alla **forma**. Meno l'idea del diritto dipende da un fine prefissato, più si accorda con la verità.

La morale, in particolare per quanto riguarda i principi fondamentali del diritto pubblico, ha la peculiarità che **quanto meno** essa fa dipendere il comportamento da un fine prefissato (vantaggio fisico o morale), **tanto più** essa si accorda con tale fine in generale.

- Ciò accade perché la **volontà universale data *a priori*** è l'unica a determinare ciò che è giusto tra gli uomini.
- Questa unione delle volontà, se coerentemente attuata, può essere, anche secondo il meccanismo della natura, la causa che **produce l'effetto desiderato** (assicurando l'efficacia del concetto di diritto).

Questo concetto è riassunto dal detto parafrasato del Vangelo (Matteo 6, 33) in chiave razionale: **"Abbiate di mira innanzi tutto il regno della ragion pratica pura e la sua giustizia, e otterrete automaticamente il vostro fine (il beneficio della pace perpetua)."**

Esistono, tuttavia, dei rischi, in particolare quello di confondere l'**universale vero** con l'**universale falso**.

- L'universale falso propone istanze assolute solo in apparenza, ma è in realtà legato a interessi molto particolari (es. etnocentrismo culturale o forme raffinate di imperialismo).
- Tali rischi si manifestano nel diritto internazionale, ad esempio nel conflitto tra la tutela universale dei diritti umani (come *nomos* della terra) e l'ordine tradizionale fondato sulla sovranità degli Stati.
- Le cosiddette "guerre umanitarie" nascondono spesso la difesa di forti **interessi economici** da parte delle grandi potenze.

Il rimedio, nel campo della ragione, è l'irrinunciabile priorità di un **principio formale o procedurale** nelle scelte di diritto internazionale. Questo non esclude le finalità politiche, ma serve ad assicurare che ogni traguardo sia percepito come **disinteressato**.

Per chiarire ulteriormente l'universalità dello *ius publicum*, si introduce una distinzione tra due tipi di doveri universali:

1. **Doveri Perfetti (*vollkommene Pflichten*)**

- Sono doveri la cui negazione è **impensabile** (es. mantenere le promesse, stare ai patti).
- Non dipendono dall'inclinazione soggettiva, ma da una causa **esclusivamente interna alla ragione**.
- La negazione di un dovere perfetto implica una **contraddizione interna alla ragione** (un'impossibilità teoretica).

2. Doveri Imperfetti *(unvollkommene Pflichten)*

- Sono doveri la cui negazione è **pensabile** (*gedacht werden kann*), ma **non desiderabile** (*unmöglich, zu wollen*), se elevata a legge universale.
- L'universalità è guadagnata dalla **volontà** (non dalla ragione).
- La negazione di un dovere imperfetto implica una **contraddizione per la volontà** (un'impossibilità pratica).

Si cita un passo di Kant: in alcuni casi, la massima non può essere pensata come legge universale senza contraddizione (doveri perfetti); in altri, l'impossibilità non è interna (sono pensabili), ma è impossibile **volere** che la massima diventi universale perché la volontà entrerebbe in contraddizione con sé stessa (doveri imperfetti).

L'esempio kantiano del non-aiuto (riguardante una persona benestante che decide *"A me non importa in alcun modo di aiutare gli altri!"*) illustra il dovere imperfetto:

- Se questa massima divenisse legge universale di natura, il genere umano **potrebbe esistere** (e forse anche in condizioni migliori, se si evitassero gli inganni ipocriti). L'universalizzazione è, dunque, **pensabile** in astratto.
- Ma la questione è: **È possibile volerlo?** La risposta è negativa. Una volontà che decidesse un tale principio cadrebbe in **contraddizione con sé stessa**.
- La persona che lo desiderasse si priverebbe, in virtù di quella stessa legge, di **ogni speranza di ricevere aiuto** in quei casi futuri in cui potrebbe aver bisogno dell'amore e della simpatia altrui.

L'**universalità** è quindi di due specie (fondata sulla ragione o sulla volontà). Lo *ius publicum* e il principio di universalizzabilità mettono in gioco entrambe le soluzioni. Soprattutto badando ai doveri della volontà che tendono all'universale, il diritto aspira ad avere una **ragione pubblica di consenso**, in cui il contenuto delle leggi è formato da azioni che tutti (o la maggioranza) **vorrebbero**.

La formula kantiana possiede pienamente il carattere di un **principio logico fondamentale**.

Analogamente alla *Grundnorm* di Kelsen, essa si pone come il **presupposto di ogni ordinamento giuridico**: non può esistere **legalità** (intesa secondo la sua stessa idea) senza la **Pubblicità** (*Öffentlichkeit*).

Il principio kantiano della Pubblicità (*Öffentlichkeit*) si distingue dalla *Grundnorm* di Kelsen per un elemento cruciale:

- Attraverso la formula di Kant, non si afferma semplicemente che il diritto è **norma** (come fa Kelsen, focalizzato sulla struttura), ma si affronta la questione decisiva della sua **funzione**.
- Il risultato è che si accordano con il diritto (e con la politica congiuntamente) **tutte le norme** che necessitano di essere pubbliche per non fallire nel loro scopo.
- Il diritto, spiegato da questa prospettiva, è lo **ius publicum**.

Esiste un altro aspetto significativo che riguarda la **corrispondenza tra diritto e morale**.

La **Pubblicità** (*Öffentlichkeit*[17]) è **implicita in ogni pretesa giuridica** e ha lo scopo di accertare la sua **giustificazione**.

L'esistenza stessa del diritto non sarebbe necessaria se non fosse altrettanto essenziale la sua **validità da parte dei destinatari**.

Da ciò scaturisce anche un **criterio fondamentale di valutazione morale**: qualora non fosse possibile rendere pubbliche le leggi, non esisterebbe alcuna **giustizia** (la quale è concepibile solo come pubblicamente conoscibile), e di conseguenza verrebbe meno anche il **diritto**, che è conferito unicamente dalla giustizia stessa.

La formula kantiana, in virtù del suo significato intrinsecamente **giuridico ed etico**, è più propriamente considerata un **"valore fondamentale"** (*Grundwert*), piuttosto che una mera **"norma fondamentale"** (*Grundnorm*) di matrice kelseniana.

A questa *Grundnorm* si affianca, quindi, un *Grundwert* essenziale. Questi due principi, agendo congiuntamente, fondano l'idea che il diritto contenga in sé non solo:

1. L'obbligo di obbedire all'ordinamento vigente (il principio basilare della validità giuridica).
2. Ma anche il presupposto primario di **vincolare le leggi alla giustizia**.

Questo secondo punto rappresenta un **ulteriore principio della validità giuridica**.

Di conseguenza, se una Costituzione è effettivamente statuita ed efficace, si deve obbedire ad essa solo nella misura in cui **rispetti il valore universale delle leggi**.

Esempio, il principio razziale contenuto nel commentario del 1936 di Wilhelm Stuckart e Hans Globke (*Kommentare zur deutschen Rassengesetzgebung*) è incompatibile con tale presupposto. L'affermazione, infatti, che la razza determini le idee del singolo **non ha alcuna possibilità di essere fondata universalmente** e, di conseguenza, di essere **giusta**.

Diritto cosmopolitico: giustizia sociale tra i popoli, principio della Pubblicità

[17] **ÖFFENTLICHKEIT:** Tutte le massime che aspirano ad essere norme si devono sottoporre alla forma della pubblicità, sennò diventano ingiuste (forma trascendentale del diritto pubblico) -Kant
Rendere pubblico per essere riconosciuto

La Coscienza Infelice

(Das Bewußtsein ist die absolute Unruhe - G.W.F. Hegel) = La coscienza è definita come **assoluta inquietudine** (*absolute Unruhe*).

L'universale può porsi come **negativo** della coscienza, costringendola a diventare la **"coscienza infelice"** (*unglückliches Bewußtsein*). Questo **malessere** (*malheur*, come lo chiama Jean Wahl) è prefigurato dalle figure hegeliane dello Stoicismo e dello Scetticismo nella *Fenomenologia dello spirito* (1807). Tale malessere nasce dal sostenere l'inutilità del mondo e della vita e dal negare loro un fondamento assoluto (l'universale).

Lo Stoicismo rappresenta la coscienza che cerca di raggiungere la **libertà** affermando che l'unico valore risiede nel fatto che essa è **essenza pensante**. Tutto ciò che è vero o buono per la coscienza deriva dal suo **interno**, non dall'esterno. La coscienza si eleva così al di sopra della confusione dell'alterità della vita, godendo profondamente di sé.

- **Movimento Interno:** Tutto si riduce essenzialmente a un movimento interno alla coscienza. Il fine non è l'oggetto esterno di un appetito (*Begierde*) o di un desiderio (*désir*), ma l'**uguaglianza del pensiero con sé stesso**. Non importa la condizione esterna (sul trono o in catene), come dimostrano Epitteto e Marco Aurelio.
- **Lotta Insostenibile:** Nonostante si proclami indipendente e assolutamente sufficiente a sé, la coscienza stoica, emergendo immediatamente, entra in una **lotta insostenibile con la vita**. Più si dichiara indipendente, tanto più la vita lo è **in sé**.
- **Libertà Astratta:** La sua è una **libertà astratta**. La libertà nel pensiero ha come sua verità solo il **pensiero puro**, che è privo del "riempimento della vita" ed è dunque solo il **concetto di libertà**, non la **libertà vitale** (*lebendige Freiheit selbst*).
- **Tedio:** Comportandosi come se la vita non esistesse, la coscienza stoica genera solo **tedio**.
- **Contrasto con la Signoria:** A prima vista, la coscienza stoica sembra agire come il Signore (descritto in precedenza da Hegel), che può godere delle cose e negarle sentendosi affermato. Per entrambi, non esiste l'indipendenza dell'essere della vita o la sua resistenza al desiderio. Tuttavia, il godimento del Signore è solo apparente e dipende dalla situazione opposta del Servo; la sua certezza acquista verità solo grazie al lavoro del Servo, che trasformerà la servitù in padronanza. Senza questo lavoro, la coscienza resta immersa nella vita e il suo senso proprio è solo un **"vacuo senso proprio"** o **"pervicacia"** (*Eigensinn*).
- **Ritiro Utópico:** Lo Stoicismo è un esempio di come, in epoche di grandi utopie (come quelle politiche e giuridiche del Cinquecento/Seicento, da More a Campanella), la coscienza tenda a ritrarsi in sé, allontanandosi dalla vita esterna.

Lo Scetticismo radicalizza l'atteggiamento negativo dello Stoicismo verso l'alterità dei fatti della vita, portandolo a compimento.

- **Annientamento:** Il pensiero scettico non si accontenta di distaccarsi, ma dichiara l'**assoluto dileguare di ogni cosa**(*Omnis determinatio est negatio*).
- **Contenuti Infondati:** Le differenze della vita sono ridotte a mere determinazioni della coscienza stessa. I contenuti solidi del pensiero vengono costantemente annientati da una **dialettica** che ne manifesta l'infondatezza.

- **Fuga Incessante e Inquietudine:** Lo Scetticismo esprime una fuga incessante della coscienza di fronte all'essere. Ogni determinazione, situazione concreta e, a maggior ragione, ogni universale sono rifiutati. Questo si traduce nell'**assoluta inquietudine** (*absolute Unruhe*).
- **Contraddizione Intrinseca:** La coscienza scettica fa **scomparire** nel pensiero il contenuto inessenziale, ma così facendo è essa stessa la **coscienza di un inessenziale**. Proferisce l'assoluto dileguare, ma il proferire **è**. Proferisce la nullità del vedere e dell'udire, ma è lei stessa che vede e ode. Proferisce la nullità delle essenze etiche, ma ne fa le potenze del suo agire.
- **Doppia Consapevolezza:** Le sue azioni e le sue parole sono in costante **contraddizione**. Possiede una duplice e contraddittoria consapevolezza: dell'**immutabilità e eguaglianza** con sé e, al contempo, della **piena accidentalità e ineguaglianza** con sé stessa.
- **Disordine e Litigio:** La coscienza scettica si risolve in un **generale arruffio** (*Verwirrung*) e in un **disordine**(*Unordnung*) che si riproducono continuamente, vivendo in una contraddizione interna. Il suo "chiacchierare" è un "litigio da ragazzi testardi", in cui ci si paga la soddisfazione di restare in contraddizione con gli altri attraverso l'autoriferimento contraddittorio (dire A quando l'altro dice B, e viceversa).
- **Epoca del Giuspositivismo:** Sul piano giuridico, lo Scetticismo rappresenta l'epoca simbolica in cui si nega ogni universale nel diritto. Conta solo il **potere nudo**, tipico dei **giuspositivismi radicali** (nella dottrina) e dei **totalitarismi violenti** (nella prassi).

La **verità** della coscienza scettica è la **coscienza infelice**. Lo Scetticismo ha distrutto l'universalità (uno dei due termini della coscienza), ma così facendo ha rivelato un'ambiguità sconcertante nel termine restante (la singolarità), da cui deriva il malessere.

- **Contraddizione dell'Immutabile:** La coscienza scettica percepisce tutto, inclusa sé stessa, come mutevole, eppure ha come essenza l'**immutabile**. Quando riconosce l'immutabile come sua essenza, diventa la coscienza di un mutevole.
- **Inquietudine Irrisolta:** È la coscienza dell'**inquietudine** che non riesce a concepire la sua quiete, impigliata in una profonda contraddizione. È la certezza assoluta di sé e, contemporaneamente, il **nulla di questa certezza**. Dichiara "Io sono colui che non è" e "Io sono colui che è", o viceversa.
- **Dolore della Perdita:** Questa coscienza infelice è la consapevolezza della **perdita di ogni essenzialità** nella certezza di sé e della **perdita del sapere di sé**, sia della sostanza che del Sé. È il **dolore** espresso nella "dura parola: **Dio è morto**".
- **Moto Perpetuo:** L'infelicità si manifesta nello smarrimento in un **moto perpetuo** tra idee opposte, nell'opposizione tra l'Io e il non-Io, in un passaggio infinito tra essere e non-essere.

Per la coscienza è necessaria la **riconciliazione** tra la sua singolarità e l'universale. La coscienza può giungere alla consapevolezza della sua **unità con l'intrasmutabile** (*Unwandelbar*) proprio a partire dal sentimento della sua infelicità e miseria.

- **Abbandono del Volere Singolare:** Il primo compito è **abbandonare il mero volere** proprio (*eignen Willens*). Questo abbandono è negativo solo in modo unilaterale; in sé è **positivo**, poiché significa il **porre del volere come Altro**; in modo determinato, è il porre il volere come **universale** e non più come singolo.
- **Il Punto di Vista Universale:** La riconciliazione è possibile solo se la coscienza si pone dal **punto di vista dell'universale**. Deve smettere di vedere il mondo e la vita come un semplice

al di qua evanescente su cui trionfa unilateralmente. Mondo e vita sono invece **pregni di universale**, ed è quest'ultimo ad avere il dominio.

- **Scoperta della Grandezza:** Similmente a Giobbe e Qoèlet, la coscienza, scorgendo la propria debolezza, scopre la propria grandezza. In questo modo, la coscienza **supera** il crepuscolo serale rappresentato dalla coscienza infelice.

Explicit o dell’equilibrio eterno del diritto visioni mesofattuali di scienza giuridica

Il concetto di **diritto** rimane una *Grundfrage* (questione fondamentale) di natura filosofica, un interrogativo tanto valido oggi quanto lo era alle origini. Parafrasando T. S. Eliot, si afferma che **alla fine è come al principio**, riportando al centro la domanda fondamentale: "Che cos'è il diritto?".

Nonostante siano trascorsi circa sessant'anni dalla pubblicazione della seconda edizione della *Reine Rechtslehre* (1964) di Kelsen e della prima edizione di *The Concept of Law* (1961) di Hart, le questioni più urgenti non riguardano la definizione di singoli istituti giuridici, ma piuttosto il **concetto stesso di diritto** e le regole fondamentali che supportano l'intera esistenza giuridica.

Il diritto sta subendo profonde modifiche che precedono i cambiamenti nei codici e nelle leggi. Si utilizza una **metafora climatica** per illustrare questo fenomeno: l'attenzione non deve essere posta sulla temperatura quotidiana (i cambiamenti specifici e superficiali), ma sui **grandi mutamenti climatici** (i cambiamenti fondamentali e strutturali). Tuttavia, si tende a percepire e a farsi distrarre dalla temperatura del giorno, ignorando i mutamenti più significativi, e lo stesso accade per il diritto.

La validità giuridica viene identificata da almeno **tre elementi** (*Tres vidit et unum adoravit*). Il punto di partenza teorico è l'idea kelseniana di **validità** (*Geltung*) intesa come **"esistenza specifica di una norma"** (*spezifische Existenz einer Norm*).

Affinché una norma, o qualsiasi fatto che aspiri all'esistenza giuridica, esista, deve trovarsi all'interno di/per un **ordinamento**. Gli elementi essenziali della validità sono:

1. **(i) L'ordinamento:** La struttura normativa di riferimento.
2. **(ii) Lo spazio di efficacia:** L'ambito in cui l'ordinamento è **"effettivamente statuito ed efficace"**.
3. **(iii) La norma:** L'elemento che conferisce la qualificazione giuridica ai fatti, trasformandoli in fatti giuridici.

Questi tre elementi fondamentali si confrontano oggi con **altrettanti fenomeni** (e potenziali *Erscheinungen der Erscheinungen* - fenomeni di fenomeni) che ne mettono in discussione la formulazione originaria, le cui caratteristiche verranno esaminate successivamente.

L'ordinamento ha attraversato grandi trasformazioni nel Novecento. Il **codice**, la sua manifestazione più visibile, ne ha risentito profondamente, portando all'epoca della **decodificazione**, come teorizzato da Natalino Irti. La fase iniziale dei codici, caratterizzata da una promessa di unità delle leggi, è stata superata, e si sono persi sia il significato che la logica costruttiva del codice stesso. Questo fenomeno, dove la realtà non conserva il suo significato unitario, è stato anticipato dalla **dodecafonia** in musica (teorizzata da Arnold Schönberg nel 1923), che simboleggia la perdita di unità dell'armonia tonale.

Un esempio è l'irruzione improvvisa di una rondine in un'aula universitaria: la lezione non è un'adunata di rondini, eppure l'evento aggiunge un elemento che interrompe in parte il significato originario della lezione. La musica contemporanea,con la dodecafonia, tenta analogamente di aggiungere "eventi" alla realtà astratta, rendendola meno generica e più vicina all'esperienza vissuta.

La decodificazione è avvenuta attraverso il passaggio da una posizione che privilegia la **realtà astratta** all'enfasi sull'**accadere dei fatti particolari**. Ciò è evidente nel **moltiplicarsi delle leggi speciali**, che contrappongono la loro specialità alla generalità delle norme codicistiche, introducendo eccezioni inedite rispetto alle figure tipiche dei codici in un continuo processo di aggiunta e sottrazione di significati.

Si citano anche le **leggi "contenitore"** (soprattutto quelle finanziarie) che hanno effetti distorsivi, poiché includono disposizioni eterogenee (dall'economia alla sanità, scuola, difesa) in un unico testo, confondendo il linguaggio e disperdendo la matrice semantica unitaria dei codici.

Il fenomeno più importante non riguarda solo i codici, ma l'**ordinamento stesso**. In questa fase, non sono solo le forme esterne del normativo (i codici) a essere in crisi, ma l'ordinamento come insieme o sistema di norme è divenuto un **concetto sfumato**. Un ordinamento i cui confini non sono chiaramente identificabili, dove non si sa dove inizi e dove finisca, non è più tale, e con esso perdono validità tutti gli elementi che da esso dipendevano.

La teoria generale ha sempre postulato che le norme esistano in relazione ad altre, all'interno di un sistema. La condizione più importante per l'ordinamento è l'esistenza di una **regola di chiusura** che stabilisca la validità solo delle norme che ne fanno parte. Se una norma è esterna, o non è valida (non è una norma), oppure l'ordinamento non è più la totalità delle norme valide. Nel diritto contemporaneo, è proprio questa regola di chiusura ad andare in crisi.

Ci si trova di fronte a un ordine giuridico i cui **confini sono difficilmente rappresentabili**.

Il Contesto Globale e la Titolarità Ignorata L'autonomia dell'ordinamento statale è erosa dalla presenza di circa **duemila organizzazioni internazionali**, oltre cento tribunali internazionali, organi quasi-giurisdizionali e numerose norme a vocazione universale. Queste entità producono effetti sulle amministrazioni nazionali e sui privati in campi eterogenei (dalla difesa a Internet, alla sanità).

Il movimento del diritto contemporaneo non è più quello del **ragno** (che tesse una ragnatela con geometrie fisse e confini circoscritti, tipica del diritto continentale europeo), ma quello dell'**ape** (che si muove in modo spasmodico, attingendo dall'esterno per nutrirsi prima di ricomporsi nell'alveare). Il diritto attuale si muove in modo non facilmente tracciabile.

Governance e Struttura Organizzativa In questo quadro, mancano **norme di struttura adeguate** (le *secondary rules* di Hart) per organizzare l'intero ordinamento. Manca un organo sovrano e una gerarchia di poteri pubblici paragonabile a quella statale. Non esiste un corpo di regole e organi capaci di indirizzare uniformemente questo ordine. Prevale la **governance sul governo**, con i poteri pubblici organizzati in rete e meccanismi fluidi basati su **scambi negoziali** e sistemi di trattativa, al posto di una rigida trasmissione gerarchica.

Il Costituzionalismo Multilivello e il *Judge-Made Law* All'idea di un unico sistema ordinato si sostituisce l'**interazione di sistemi giuridici diversi**. Si osserva una discontinuità tra il *judge made law* delle corti europee e il modello costruttivista del diritto continentale (basato sul *civil law*), risultando in un **costituzionalismo multilivello**.

L'ordinamento delle fonti è difficile da inquadrare. L'attuazione delle direttive e delle decisioni delle corti europee è **filtrata dalle categorie giuridiche nazionali** e dall'impianto codicistico, generando effetti distorsivi (ad esempio, nel passaggio dal generale al particolare). I ritardi nei meccanismi di

adempimento interno agli Stati vanificano la portata giuridica delle norme europee, minando il vincolo gerarchico. Di fatto, le supreme corti europee, pur essendo l'ultimo grado di giudizio, finiscono al penultimo posto poiché non riescono a scavalcare completamente l'amministrazione dei singoli Stati.

Il Caso del Crocifisso La **laicità dello Stato** è un tema controverso, con posizioni distanti tra le giurisdizioni nazionali e quelle europee.

- In Italia, il TAR del Veneto (2005) e il Consiglio di Stato (2006) hanno interpretato la laicità non come principio univoco, ma come concetto da declinare nel contesto storico-culturale nazionale. Per loro, il crocifisso nelle aule scolastiche non è visto come simbolo di fede, ma come **"principio di sostentamento"** (*erhaltendes Prinzip*) dei valori alla base della Costituzione.
- La Corte europea dei diritti dell'uomo (Affaire Lautsi c. Italie, 2009) sostenne inizialmente un'idea di laicità **astratta** da ogni *ethos* particolare, ritenendo la presenza del crocifisso una violazione.
- Il giudizio mutò completamente in appello (Grand Chambre, 2011), riconoscendo il potere discrezionale degli Stati in materia di educazione e il **valore delle tradizioni culturali**, concludendo che l'esposizione del crocifisso non costituiva violazione.

Paradossalmente, mentre ci si aspetterebbe una maggiore capacità di interpretare i casi nel loro contesto specifico da parte di un diritto di *common law* (le corti europee), si osserva invece una maggiore vicinanza ai casi da parte delle corti interne (con un impianto deduttivistico di *civil law*), e una maggiore lontananza da parte della giurisprudenza europea.

Il Principio di Sussidiarietà Anche il **principio di sussidiarietà** (che affida la soluzione dei problemi a enti e soggetti più prossimi), soprattutto nella sua interpretazione privatistica, ha effetti decostruttivi sull'ordinamento, spesso traducendosi in un'affermazione di autonomia (*"Nessuno venga a mettere il naso in casa nostra"*). L'estensione di questa logica (dallo Stato alle Regioni, Province, Comuni) può portare a un *regressus in infinitum* in antitesi con il bene comune.

La partecipazione degli *stakeholders* nei processi decisionali pubblici rischia di alterare il principio di eguaglianza formale. La distanza sempre minore tra rappresentante e rappresentato può associare al primo il ruolo di *Vertretung*(rappresentanza) di interessi solo privati o corporativi, come accade con l'affidamento di servizi essenziali e poteri costitutivi dello Stato a soggetti privati.

Il modello delle fonti non è più a gradi o **gerarchico** (come teorizzato da Kelsen), ma **orizzontale e internamente bipolare**. Le norme interne sono in competizione con fonti esterne all'ordinamento.

La **regola di chiusura** deve essere continuamente ricalcolata nel suo significato, bilanciando interno ed esterno tra differenti sistemi giuridici. Non si possono ignorare le procedure di composizione dei conflitti previste da trattati internazionali, con una netta prevalenza di meccanismi di **negoziazione, mediazione, conciliazione, arbitrato** (modi pacifici di risoluzione basati sulla parità delle parti, noti come **"transactionalism"**).

Le decisioni possono essere adottate a maggioranza semplice (come per le regole di procedura dell'UNHCR), rendendo flessibile il campo delle decisioni e l'effettività delle regole.

Infine, l'ordinamento è limitato dai **compliance committees** che sovrintendono all'attuazione di specifiche convenzioni. Ad esempio, se un'autorità statale nega l'accesso a informazioni (es. studi di fattibilità), un Comitato di accertamento della conformità può stabilire se lo Stato (es. Kazakistan) si è attenuto agli obblighi di trasparenza, potendo imporre provvedimenti cautelari o sospendere i diritti pattuiti.

Si introduce una seconda questione fondamentale: il rapporto tra il **nomos** (il diritto) e la **terra** (lo spazio). La validità di una norma è tradizionalmente legata a un territorio specifico ("qui e non altrove"). Tuttavia, l'avvento della **nuova *lex mercatoria***, il diritto generato dai commerci, aspira a uno **spazio illimitato**, espandendosi oltre l'ultimo confine conosciuto. Si osserva che l'illimitato acquisisce maggiore potenza se costruito sul limite.

Le Imprese Globali e la Ricchezza Senza Nazione Le grandi società operano come **imprese multinazionali**,distribuendo i loro servizi a livello globale con elevata efficienza, ricercando costantemente la massima convenienza.Sono in grado di scegliere il mercato del lavoro più economico (anche in contesti con scarse tutele per i lavoratori), le sedi amministrative più efficienti, il sistema fiscale più vantaggioso e il mercato più redditizio per gli investimenti.

Questa dinamica è volta alla crescita della ricchezza aziendale, anche a costo di sacrificare la ricchezza degli Stati. Ciò contraddice la formula smithiana che localizzava la ricchezza esclusivamente all'interno della nazione, portando alla constatazione che **"la ricchezza non ha più nazione; le nazioni non hanno più ricchezza"**.

L'Autonomia della Lex Mercatoria Il diritto segue la stessa tendenza. La Cassazione italiana (sentenza n. 722/1982) ha riconosciuto la *lex mercatoria* come un **"ordinamento giuridico"** separato dagli ordinamenti statali, espressione della *societas mercantile*. La nuova *lex mercatoria* mira a creare un ordine giuridicamente autonomo e a spingere i confini della *business community* oltre quelli degli Stati. Mentre gli Stati sono definiti dai loro confini, i mercati (soprattutto quello finanziario) tendono ad annullarli.

Gli effetti di questa realtà sconvolgono gli assetti politici e giuridici statali, piegando i principali provvedimenti finanziari alla nuova realtà e neutralizzando le applicazioni ordinarie dei codici in molte aree economiche. Il **contratto** assume un ruolo preminente, quasi a significare una nuova origine dell'ordine giuridico, distinta dal *contrat social* rousseauiano.

Il contratto non è più una semplice applicazione del diritto, secondo le concezioni classiche, ma una **straordinaria fonte** da cui il diritto rinasce nei mutamenti attuali. Ad esempio, il contratto si sostituisce alla legge nella regolazione del mercato finanziario. Il regolamento di borsa, predisposto da una società privata di gestione, è di fatto un **contratto di adesione** a cui rispondono gli operatori ammessi.

Contratti Atipici e Diritto Uniforme Il contratto primeggia come strumento dell'economia globale. Le multinazionali utilizzano **modelli contrattuali uniformi** per operare negli spazi sconfinati del commercio, opponendosi alla rigidità e alla circoscrizione territoriale dei codici nazionali.

Questi sono spesso **contratti atipici**, creati non dai legislatori nazionali, ma dagli uffici legali delle grandi multinazionali, da grosse *law firms* e da associazioni internazionali di categoria (esempi citati: *leasing, franchising*).

Mentre il diritto commerciale nazionale mira a seguire l'attività economica nei confini territoriali, i contratti delle multinazionali hanno il compito di **estendersi ad ogni punto della terra**, in un'ottica **meta-statuale** che mira a un diritto uniforme oltre i confini. L'uniformità di questi modelli è un valore che prescinde dai sistemi legislativi nazionali: le case madri impongono alle società-figlie l'uso di modelli contrattuali con la raccomandazione di limitarsi alla mera trasposizione linguistica, ignorando il diritto interno dei singoli Stati.

A sostegno dell'autonomia delle imprese globali e del sistema finanziario (i cui effetti superano i limiti territoriali del diritto statale), si consolidano organismi di **governo mondiale dell'economia** (es. FMI, WTO) con l'obiettivo di colmare il divario tra gli interessi della *societas mercatorum* e le regole costitutive delle società nazionali.

Il Ruolo del Giudice Il giudice, che secondo Hegel è più un organo della società civile che dello Stato, è chiamato a confrontarsi con questi modelli contrattuali universalmente riconosciuti pur dovendo giudicare in base all'ordinamento statuale. Subentra il **giudizio di "meritevolezza"** (art. 1322 c.c.) che pone in primo piano l'interesse generale dello Stato. Questo porta al corollario che ciò che è valido nelle nazioni affini non può essere meno valido in Italia, consacrando così l'uniformità dei modelli contrattuali.

Un caso emblematico è quello del **performance bond** (*Garantie Vertrag*), un contratto autonomo di garanzia. Nonostante il principio di sussidiarietà alla base della fideiussione (che richiederebbe la nullità di un contratto che elide il vincolo essenziale del rapporto garantito), la Cassazione ha subito riconosciuto la sua atipicità rispetto alla fideiussione, sottraendolo alla disciplina diretta del codice. In alcune sentenze (es. n. 7341/1987), l'esigenza del commercio internazionale viene esplicitamente citata come **"ratio decidendi"**.

Nella società globale si consolida il primato delle **autorità tecnocratiche** sui governi eletti democraticamente. Le crisi finanziarie portano alla creazione di *board* di controllo dei mercati indipendenti (come il Sarbanes-Oxley Act negli USA, o l'attribuzione dei regolamenti attuativi a Banca d'Italia e Consob in Italia), dove il governo fissa solo i principi generali.

Questa è l'età della **tecnodemocrazia**. Mentre si sperimentano nuove forme di partecipazione diretta dei cittadini via Internet, cresce in modo preponderante il **potere degli esperti** a discapito dei rappresentanti eletti.

Il Diritto dei Sapienti (Unidroit) Il diritto delle grandi tradizioni (dal romano alle codificazioni) ha sempre visto in primo piano i **sapienti** a discapito della politica. Un esempio contemporaneo è dato dalla *lex mercatoria* (come analizzato da Francesco Galgano), dove la compilazione di regole comuni per le transazioni economiche è affidata a istituti internazionali come **Unidroit**.

Unidroit, con i **"Principi dei contratti commerciali internazionali"**, unifica il diritto privato e commerciale attraverso la comparazione e la mediazione culturale dei giuristi. Queste regole acquisiscono la veste di **principi generali del diritto** con un raggio d'influenza illimitato, regolando la vita del commercio globale. Tali principi si fanno carico di rimediare alla disparità contrattuale (originaria o sopravvenuta) con interventi di **giustizia pareggiatrice** (Gross Disparity e Hardship), dimostrando un'equità che talvolta supera quella dei codici statali, in un quadro di "tecnodemocrazia illuminata".

Il Versante Problematico delle Agenzie di Rating Esiste un versante problematico della tecnodemocrazia: le *élites* decisionali non sempre perseguono l'interesse pubblico. Si fa l'esempio delle **agenzie private di rating** (con interessi privati) che valutano il debito pubblico degli Stati, influenzando le politiche di bilancio di intere nazioni. La crisi finanziaria del 2007 (mutui *subprime*) fu aggravata non solo dal fallimento di banche come Lehman Brothers, ma anche dal fallimento del sistema di valutazione del mercato fornito da queste agenzie. Si evidenzia il rischio che il **diritto privato prevalga su quello pubblico** a scapito delle misure sociali degli Stati.

Il diritto contemporaneo si confronta con la **crisi dei codici** e, in senso più ampio, con quella dell'ordinamento. L'aggiunta di nuove norme, spesso in conflitto o in concorrenza con quelle originarie, e le diverse interpretazioni che si accumulano nel tempo (legate all'intenzione del legislatore o all'applicazione attuale) alterano il senso unitario e la capacità unificante dei codici. Nonostante ciò, i codici continuano a esistere e a produrre effetti, pur avendo perso il loro significato **dogmaticamente unitario** iniziale.

In questa prospettiva, il diritto viene definito **"decodificato"** (secondo l'espressione di Irti), sottraendosi all'idea del codice, ma non al concetto stesso di giuridicità. Il diritto può esistere senza il codice, ma non senza l'ordinamento.

La vera questione oggi è l'**ordinamento**, inteso come la totalità delle norme valide. Un fatto è giuridico solo in relazione a questa totalità, la quale determina anche l'insieme delle norme non valide.

Il diritto odierno non riesce a darsi un luogo preciso, un inizio e una fine puntuali, a causa della **molteplicità di fonti eterogenee**, molte delle quali in contrasto con i poteri tradizionali dello Stato o legate agli autonomi spazi dei commerci globali.

Allo **Stufenbau kelseniano** (la costruzione gerarchica delle norme) si contrappone un **modello orizzontale di fonti** che raramente risale a una **Grundnorm** (norma fondamentale) o a una regola di chiusura. Questo scenario lascia dietro di sé le "rovine della realtà giuridica sorta un tempo con la modernità".

Attualmente, si dispone solo di una "mappa" che potrebbe non coincidere con il "territorio" giuridico reale e non portare necessariamente a una soluzione. Tuttavia, non ci sono altri strumenti per evitare uno **stato pre-giuridico** in cui tutto è permesso.

Vengono fatte due osservazioni metodologiche:

1. I fenomeni più significativi sono quelli a **formazione spontanea**, non generati da istituzioni storiche puntuali, che si sviluppano lentamente dominando intere epoche, come i **mutamenti climatici**.
2. Tra i fenomeni giuridici odierni, i **diritti dell'uomo** meritano maggiore attenzione. Essi non hanno natura meramente legalistica e sono in grado di fondare un **nuovo costituzionalismo senza Costituente**, gettando le basi per un **ordine giuridico globale**.

Per comprendere la natura speciale dei diritti umani, si analizzano i **fatti istituzionali** (come le banconote) attraverso la regola costitutiva di Searle: **"X conta come Y in C"**.

- **X (sostrato materiale):** Ad esempio, un pezzo di carta.
- **Y (funzione assegnata):** Ad esempio, "banconota".

- **C (intenzionalità collettiva):** L'accettazione da parte di tutti, regolata dal potere delle Banche Centrali (o agenzie potenti nel caso delle criptovalute). L'enunciato "This note is legal tender..." non descrive ma **costituisce** X come mezzo di pagamento.

I **diritti umani** sono diversi. Non ammettono fonti di grado superiore né si formano semplicemente in forza di un potere accettato. La loro genesi richiede un **tempo lunghissimo**, paragonabile ai cambiamenti climatici. Per questo sono definiti **"mesofatti"**, ponendosi tra i fatti permanenti e i fatti in continuo e rapido divenire.

I Mesofatti

- **Fatti Permanenti:** Realtà aritmo-geometriche (es. 5+7=12, assiomi euclidei), il cui significato è invariabile e non è prodotto di un'evoluzione storica.
- **Fatti in Continuo e Rapido Divenire:** Il risultato di una partita di calcio o il valore volatile dei **futures** e dei **derivati** sui mercati finanziari. Il loro valore (valore di mercato) non è intrinseco ma dipende dalla domanda e dall'estrema relatività. I derivati, in particolare, sono prodotti la cui vacuità è spesso nascosta da una "hybris di principi" (Deleuze), come dimostra il rapporto 1 a 10 tra barili di petrolio reali ("wet barrels") e barili di carta ("paper barrels") speculativi.

I **mesofatti** sono il terzo tipo di fatti: non sono né permanenti né di breve durata, ma sono il risultato finale di **inesauribili traiettorie di tempo** e costituiscono i "continenti della storia".

I diritti sono mesofatti, assimilabili alle **città** o agli istituti giuridici come la **"vendita"** (art. 1470 c.c.), che non sono mere invenzioni legislative ma il risultato di una **tradizione sapienziale immemore** e di secoli di evoluzione (dal baratto ai trattati sul diritto comune).

La teoria dei mesofatti ha due implicazioni:

1. **Esclude la completa prevedibilità** degli stadi successivi.
2. Riconosce ad alcuni fatti il **significato ideale di risultati irretrattabili** dell'esperienza umana.

La maturazione della coscienza di molti diritti ha portato a considerare la schiavitù, il razzismo, le discriminazioni e il colonialismo come **"veri errori della ragione"**. I diritti si stanno trasformando in **diritto "cogente"** (*ius cogens*), non posto ma presupposto alle leggi, in continuità con il passaggio dalla validità della *Grundnorm* alla validità dei **valori fondamentali (*Grundwerte*)** dell'ordinamento (come nello *Stufenbau* kelseniano rivisitato).

Il modello mesofattuale, pur non essendo una scienza geometrica della storia, può contribuire al dibattito su temi come la pena di morte. Sebbene l'abolizione non sia universale (citando USA, Giappone, Cina e Stati arabi) e la ragione astratta non sia giunta a una sola conclusione, l'esperienza, analizzata con l'approccio dei cambiamenti climatici (guardando ai "big data" come i report di Amnesty International), indica che:

- Il numero di Stati che la contemplano e il numero di crimini che la prevedono sono in costante **diminuzione**.
- Molti Stati non l'applicano (*abolizione de facto*) o ne sospendono l'esecuzione (*sine die*).

- L'approvazione della **risoluzione ONU per la moratoria universale** (2007) è un fatto significativo.

Secondo la teoria dei mesofatti, la coscienza che la pena di morte è un non-senso scaturisce proprio da questi fatti, che regolano l'esperienza umana e portano a riconoscere il **valore incondizionato della vita umana**.

I diritti non sono il frutto di una dimostrazione logica (come i teoremi di Gödel) o di una delibera, ma assomigliano alle **grandi cattedrali** medievali, costruite nel tempo attraverso l'accumulo di elementi e l'esperienza.

- I diritti sono **punti di approdo** che rendono insensato tornare indietro (es. il progresso dal ricorso all'ordalia al **diritto al giusto processo** e al principio di **terzietà** del giudizio, che smentisce la tesi di Trasimaco sulla giustizia come "utile del più forte").
- I diritti sono il risultato della **coscienza** (l'*Erfahrung des Bewußtsein* di Hegel) maturata attraverso la storia, dove **la ragione è vuota senza l'esperienza, e l'esperienza è cieca senza la ragione**. Essi sono "formazioni stalattitiche o stalagmitiche", il cui risultato (come la Dichiarazione dei *droits de l'homme* del 1789, preparata anche dalla letteratura come *Julie ou la Nouvelle Héloïse* di Rousseau) è il prodotto di un lavoro inesausto, goccia dopo goccia, attraverso i millenni.

Con i diritti, l'assegnazione di *status* non avviene tramite un semplice potere o atti performativi linguistici (come nel caso della banconota, X conta come Y in C). Invece, la regola "Ogni persona umana (A) vale come bene indisponibile (Y) per tutti gli uomini (C)" si basa sulla **relazione essenziale di una verità teoretica sull'uomo**. Il **cognitivo non è estraneo al normativo**, smentendo il positivismo giuridico ingenuo. Più il potere difende i diritti, più è forte, e i diritti, a differenza delle ere climatiche, **difficilmente tornano indietro**.